



ACTO JURÍDICO

Apunte realizado en base al texto "Teoría General del Acto Jurídico", del profesor Víctor Vial del Río, más textos complementarios.
Material en revisión.

INTRODUCCIÓN

El estudio de la Teoría del Acto Jurídico constituye, sin duda alguna, uno de los pilares fundamentales para el estudio del derecho en general y del derecho civil en particular. Su importancia radica en el hecho de que el acto jurídico es la “célula básica” en torno a la cual se estructura la actividad jurídica. Es el instrumento por medio del cual se materializa la autonomía privada, que permite a las personas regular sus propias relaciones jurídicas.

Podríamos decir, en términos generales, que el estudio del acto jurídico es el estudio de las reglas comunes y generales de la voluntad jurídica. Es el estudio de los requisitos que deben verificarse para que la voluntad jurídica produzca sus efectos, y de las consecuencias que se generan en caso de que dichos requisitos no se cumplan. En ese sentido, las reglas del acto jurídico son las reglas generales sobre las cuales se estructura prácticamente todo el derecho privado.

Ahora bien, esto supone una dificultad para el estudiante que se enfrenta a estos temas por primera vez. En particular, sucederá en diversos puntos del apunte que los ejemplos citados remiten a materias cuyo estudio detenido aún no se ha realizado. En ese sentido, sólo podemos recomendarles paciencia y perseverancia. Muchos de los temas que en una primera aproximación puedan parecer oscuros, se aclararán notablemente en los sucesivos repasos que contempla el proceso de preparación para el examen de grado.

Índice

1. La teoría del Acto Jurídico	4
1.1 Generalidades	4
1.2 Noción del Acto Jurídico	7
2. La voluntad Jurídica	13
2.1 Generalidades	13
2.2 El principio de la autonomía de la voluntad	15
2.3 La voluntad en los Actos Jurídicos bilaterales	17
2.4 Los vicios de la voluntad	23
2.4.1 El error	23
2.4.2 La fuerza	30
2.4.3 El dolo	33
2.4.4 La lesión	39
2.5 Indemnización de perjuicios por vicios del consentimiento	42
2.6 Desacuerdo entre voluntad y declaración	43
2.7 La simulación	45
3. El objeto	52
3.1 Generalidades	52
3.2 El objeto para el Código Civil	53
3.3 El objeto ilícito	55
4. La causa	63
4.1 Generalidades	63
4.2 Evolución histórica de la noción de causa	63
4.3 La teoría de la causa en el Código Civil chileno	65
4.4 El rol jurídico de la causa	67
4.5 El acto en fraude a la ley	69
5. Las formalidades	71
5.1 Generalidades	71
5.2 Clasificación de las formalidades	71
6. Efectos de los Actos Jurídicos	75
7. Ineficacia de los Actos Jurídicos	78
7.1 Generalidades	78
7.2 Clases o especies de ineficacia	78
7.3 La ineficacia por inexistencia en el Código Civil	79
7.4 La ineficacia por nulidad en el Código Civil	82
7.4.1 La nulidad absoluta	82
7.4.2 La nulidad relativa	84
7.4.3 Nulidad total y parcial	89
7.4.4 Efectos de la nulidad	90
7.4.5 Conversión del acto nulo	94
7.4.6 El error común acerca de la causa de invalidez	94
7.5 La ineficacia por inoponibilidad	96
8. La representación en los Actos Jurídicos	98
8.1 Conceptos generales sobre la representación	98
8.2 Poder de representación	98
8.3 Clases de representación	99

8.4 Mandato y representación voluntaria	99
8.5 Naturaleza jurídica de la representación	100
8.6 Influencia de las circunstancias personales del representante o representado en el Acto Jurídico	102
8.7 Requisitos de la representación	103
8.8 Causales de extinción del poder de representación	104
8.9 Exceso o defecto de poder de representación	104
8.10 La ratificación	104
9. Anexos	106

TEORÍA GENERAL DEL ACTO JURÍDICO

CAPÍTULO 1. LA TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO.

1.1 GENERALIDADES

1. Conceptos generales.

Elementos comunes de las instituciones de Derecho Privado:

- Surgen como consecuencia de la voluntad de la persona.
- La manifestación de voluntad tiene un propósito determinado.
- Producen efectos jurídicos.

Actos que tienen estas características: actos jurídicos (AJ).

Teoría General del AJ: reglas y principios aplicables a todos los AJ.

2. Fundamento histórico de la Teoría General del AJ.

Autonomía de la voluntad: la persona se obliga porque es libre y esa es su voluntad. Puede celebrar actos, determinar su contenido y efectos.

3. La Teoría del AJ en el CC chileno.

No la recoge ni regula expresamente. Pero el Libro IV ("De las obligaciones en general y de los contratos.") se aplica a los AJ, salvo que no sea aplicable por el tenor de la disposición o por la naturaleza de las cosas.

4. Los hechos jurídicos. Conceptos generales.

Hechos: cualquier acontecimiento, situación, suceso o actuaciones.

Clasificación:

1. a) Naturales.
b) De la persona
2. a) Jurídicos: producen efectos jurídicos. Sólo éstos tienen "relevancia jurídica": cambian una realidad, creando nuevas situaciones con clasificación jurídica distinta.
b) No jurídicos.

Efectos jurídicos: adquisición, modificación o extinción de derechos o en una visión más amplia una relación jurídica.

5. Supuesto jurídico.

Supuesto jurídico: Hecho que la norma legal prevé y le atribuye la producción de efectos jurídicos. El hecho concreto debe poder subsumirse en el tipo construido por la norma.

Clasificación:

Supuesto simple: un hecho.

Supuesto complejo: más de un hecho.

6. Clasificación de los hechos jurídicos.

1. **a) Naturales**: acontecimiento de la naturaleza. Los más importantes son:
 - Nacimiento: la criatura adquiere la calidad de persona y puede ser titular de derechos subjetivos.
 - Muerte: pone fin a la existencia de la persona (transmisión de derechos y obligaciones transmisibles).
 - Demencia: priva de la capacidad de ejercer por si mismo derechos civiles.
 - Mayoría de edad: otorga capacidad para ejercer por si mismo derecho civiles.
- b) Voluntarios**: acto de la persona. Ejm. contrato, matrimonio, comisión de un delito.

Se critica a esta clasificación porque habría hechos en que participan ambos. La respuesta es que el criterio a utilizar es la trascendencia de la voluntad de la persona en los efectos del hecho, por tanto no existen los hechos "híbridos".

2. a) Positivos: los efectos son consecuencia de que ocurra algo (acontecimiento de la naturaleza o acto de la persona).
b) Negativos: los efectos son consecuencia de que no ocurra algo. Cuando tienen efectos es porque van junto con uno positivo (supuesto complejo). Ejm. (-) No pago del deudor (+) existencia de una obligación exigible.
3. a) Constitutivo: su consecuencia es la adquisición de un derecho subjetivo.
b) Extintivo: pone fin a una relación jurídica.
c) Impeditivo: obsta a la eficacia de los dos anteriores.

Importancia de esta clasificación: quien alega el hecho debe probarlo.

7. Consecuencias de los hechos jurídicos.

- A) Adquisición: se adquiere una relación jurídica cuando la ley a atribuye a un sujeto determinado como consecuencia de un hecho jurídico. Adquisición es más amplio que nacimiento.
- B) Modificación: la relación sufre cambios que la hacen diferente, sin perder su identidad (cambia el contenido o los sujetos). La modificación puede ser por ley o por la voluntad de la persona
- C) Extinción: muerte del derecho. La pérdida de un derecho no implica su muerte, pues el derecho subsiste, pero cambia de titular. La extinción también puede ser por ley o por la voluntad de la persona

8. Desde qué momento se producen los efectos de los hechos jurídicos.

Desde que se cumplen todos los requisitos previstos por el supuesto.

Estado de pendencia: situación de incertidumbre que se produce mientras no se verifican todos los hechos de un supuesto complejo.

9. Retroactividad de los efectos de un hecho jurídico.

La retroactividad es excepcional. Puede ser:

- 1. Por voluntad de las partes.
- 2. Legal: por una ficción se supone que efectos que no se habían producido en determinado momento, se consideran después producidos desde ese momento.

10. Hechos jurídicos de la persona (actos humanos).

Cuando se habla de ellos, se refiere a los voluntarios. Los involuntarios se asimilan a los hechos naturales.

11. Clasificación de los actos humanos.

Lícitos: se conforman con el Derecho. Están protegidos por el Derecho y producen los efectos queridos por su autor.

Ilícitos: contravienen el Derecho, el cual reacciona:

- impidiendo que el acto produzca efectos, u
- ordenando reparar los daños.

Algunos sectores de la doctrina alemana e italiana distinguen entre el negocio jurídico y el acto jurídico. El negocio jurídico sería aquel cuyos efectos son los queridos por el autor y las partes. En el acto jurídico, en cambio, sus efectos no necesariamente irían de la mano de la voluntad del autor o las partes.

Con todo, hay que notar que esta clasificación es ajena a la doctrina y legislación nacional.

1.2 NOCIÓN DEL AJ.

1. Concepto del AJ.

AJ: Manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, modificar o extinguir derechos, y que produce los efectos queridos por su autor o por las partes porque el Derecho sanciona dicha manifestación de voluntad.

Análisis de la definición:

A) El AJ es una manifestación de voluntad.

Es necesario que la voluntad se exteriorice por medio de una declaración o comportamiento. Deben concurrir dos elementos:

- Interno: la voluntad.
- Externo: la manifestación.

B) La manifestación debe perseguir un propósito específico y determinado:

- Doctrina tradicional: debe perseguir un propósito jurídico.
- Doctrina moderna: debe perseguir un fin práctico.

Ambas doctrinas son en el fondo lo mismo, con diferente enfoque: la primera es como lo ve el Derecho; la segunda, como lo ven las partes.

C) La manifestación de voluntad produce los efectos queridos por el autor o por las partes porque el Derecho la sanciona.

Existen dos teorías sobre la causa eficiente de los efectos jurídicos:

- Se producen por la sola voluntad.
- Se producen por el Derecho; la voluntad es necesaria sólo para configurar el supuesto de hecho.

Vial tiene una posición intermedia: se producen por ambos, pues derivan inmediatamente de la voluntad y mediatamente de la ley, que es la que en definitiva permite la autonomía privada.

2. Estructura del AJ.

Art. 1444 CC. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.

1) Elementos esenciales del AJ.

Elementos esenciales: los necesarios y suficientes para la constitución de un AJ.

Clasificación:

1. Comunes o generales: no pueden faltar en ningún AJ.
2. Especiales o específicos: requeridos para cada AJ en especial.

En consecuencia, si se omite un elemento esencial general, el acto no produce ningún efecto, es inexistente. En cambio, si se omite uno específico del acto, no se producen los efectos de ese AJ, pero se pueden producir los de otro AJ diferente.

Art. 1445 CC. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: 1. que sea legalmente capaz; 2. que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3. que recaiga sobre un objeto lícito; 4. que tenga una causa lícita.

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra.

De los requisitos enumerados por la disposición, sólo son esenciales la voluntad, el objeto y la causa. La capacidad, la voluntad sin vicios, el objeto lícito y la causa lícita no son esenciales, pues si faltan, el AJ produce sus efectos, pero puede ser anulado.

2) Elementos de la naturaleza o naturales.

No existen realmente elementos naturales del AJ, sino efectos naturales. Por lo demás, el CC no dice "elementos", sino "cosas".

Art. 1444 CC. "(...) son de la *naturaleza* de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial;..."

Las partes pueden eliminarlas sin alterar la esencia del AJ.

Ej. En la compraventa, es de la naturaleza la obligación de saneamiento de la evicción y de los vicios redhibitorios.

3) Elementos accidentales.

Art. 1444 CC. "(...) y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales."

Las partes, en virtud de la autonomía privada, pueden agregarlas al AJ sin alterar su naturaleza. Pueden referirse a su existencia o eficacia.

Estos elementos se vinculan con las modalidades (condición, plazo, modo, etc.) Sin perjuicio, de que excepcionalmente las modalidades pueden ser elementos de la esencia (Por ej: Art. 1554 N° 3 CC) o de la naturaleza (Por ej: Art. 1489 CC)

Ver anexo en página final.

3. Requisitos de los AJ.

1) Requisitos de existencia.

Son indispensables para que el AJ nazca a la vida del Derecho. Si faltan, el acto es jurídicamente inexistente, por lo que no produce efecto alguno.

Son requisitos de existencia:

- la voluntad
- el objeto
- la causa
- las solemnidades requeridas para la existencia de acto.

2) Requisitos de validez.

Son necesarios para que el AJ tenga una vida sana y produzca sus efectos en forma estable. Su omisión no impide que el acto nazca, pero nace enfermo, con un vicio que lo expone a morir si es invalidado.

Son requisitos de validez:

- la voluntad no viciada
- el objeto lícito
- la causa lícita
- la capacidad.

4. Clasificación de los AJ.

1. Atendiendo al número de partes cuya voluntad es necesaria para que el AJ se forme:

1. Unilaterales: requieren la manifestación de voluntad de una sola parte.
Simples: emanan de la voluntad de una sola persona.
Complejos: procede de varias personas que manifiestan una voluntad común. No hay intereses contrapuestos.

Los actos jurídicos unilaterales pueden clasificarse a su vez, en recepticios o no recepticios. Se consideran actos jurídicos recepticios aquellos que para producir efectos requieren de la manifestación de voluntad de una parte distinta del autor del acto (por ejemplo, la oferta para celebrar un contrato que requiere la aceptación del destinatario de la oferta) Los no recepticios son aquellos en que la declaración de voluntad tiene eficacia sin necesidad de que sea dirigida a alguien en particular (como por ejemplo, el testamento).

2. Bilaterales: requieren la manifestación de voluntad de dos partes. Doctrinariamente se llama "convención". Existen dos partes con intereses diversos.

Autor: parte cuya voluntad es necesaria para dar nacimiento al AJ unilateral.

Partes: personas que teniendo intereses contrapuestos, se ponen de acuerdo para dar nacimiento a un AJ bilateral.

No deja de ser unilateral un AJ por requerir en algunos casos, para producir sus plenos efectos, la manifestación de voluntad de otra persona.

Los Arts. 1437 y 1438 CC hacen sinónimos los términos convención y contrato, siendo que existe entre ambos una relación de género a especie: el contrato es una convención que crea derechos y obligaciones. Pero este error no es importante en la práctica, pues a ambos se les aplican las mismas reglas y principios.

3. Plurilaterales: requieren la manifestación de voluntad de más de dos partes (clase agregada por la doctrina moderna. Ej. Novación por cambio de acreedor.

2. Atendiendo a si el AJ para producir sus efectos requiere o no la muerte del autor o de una de las partes:

1. Entre vivos: no requieren naturalmente la muerte del autor o de una de sus partes. Es la regla general de los AJ.

2. Por causa de muerte: requieren la muerte del autor o de una de sus partes. Ej. Testamento (Art. 999 CC), mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante (Art. 2169 CC).

3. Atendiendo a la utilidad o beneficio que reporta el AJ para quienes lo ejecutan:

1. A título gratuito: se celebran en beneficio exclusivo de una persona o parte.
2. A título oneroso: se celebran teniendo en consideración la utilidad o beneficio de ambas partes.

4. Atendiendo a si el AJ produce o no sus efectos de inmediato y sin limitaciones:

1. Puros y simples: producen sus efectos de inmediato y sin limitaciones.
2. Sujetos a modalidad: sus efectos están subordinados a una modalidad.

Modalidades: cláusulas que se incorporan a un AJ con el fin de alterar sus efectos normales. Las principales son la condición, el modo y el plazo. La doctrina agrega la representación y la solidaridad.

5. Atendiendo al contenido de los AJ:

1. De familia: atañen al estado de las personas o a las relaciones del individuo dentro de la familia.
2. Patrimoniales: tienen por finalidad la adquisición, modificación o extinción de un derecho pecuniario.

6. Atendiendo a si el AJ subsiste o no por sí mismo:

1. Principales: subsisten por sí mismos, sin necesidad de otro acto que les sirva de sustento o apoyo.
2. Accesorios: para poder subsistir necesitan de un acto principal que les sirva de sustento o apoyo, al cual acceden. Se clasifican en:
 - a) De garantía: Cauciones: se constituyen para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de tal manera que no pueden subsistir sin ella (Art. 46 CC). Ej. Prenda, hipoteca, fianza.
 - b) Dependientes: no tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de una obligación. Ej. Capitulación matrimonial.

Los AJ accesorios no pueden subsistir sin un AJ principal, pero pueden tener existencia jurídica con anterioridad a éste. Faltando en definitiva el AJ principal, el accesorio caduca.

7. Atendiendo a si la ley exige o no formalidades para su celebración:

1. Solemnes: están sujetos a la observancia de ciertas formalidades especiales requeridas para la existencia misma del acto, o para su validez.
2. No solemnes: no están sujetos a requisitos externos o formales.

8. Atendiendo a si están o no reglamentados por la ley:

1. Nominados o típicos: están reglamentados por la ley, que señala el supuesto de hecho al cual atribuye efectos jurídicos y determina éstos.
2. Innominados o atípicos: no están previstos por la ley, pero pueden adquirir existencia jurídica como consecuencia de la autonomía privada. Si se conforman con la ley, el orden público y las buenas costumbres, producen los efectos queridos por las partes, rigiéndose, en lo no previsto por ellas, por las reglas generales aplicables a los actos y declaraciones de voluntad.

CAPÍTULO 2. LA VOLUNTAD JURÍDICA

2.1 GENERALIDADES.

1. Conceptos generales.

El primer requisito de existencia del AJ es la voluntad. Para que la voluntad produzca efectos jurídicos debe cumplir dos requisitos copulativos:

- a) Manifestarse. De modo que se pueda conocer.
- b) Ser seria. Perseguir efectivamente un fin reconocido o tutelado por el derecho.

2. Primer requisito: La manifestación de voluntad.

A) Manifestación de voluntad expresa (explícita o directa):

Se realiza a través de una declaración, contenida en palabras (orales o escritas) o incluso en gestos o indicaciones. No es posible concebir una declaración sin un destinatario.

La claridad es un deber del declarante. Este principio es acogido por el CC en las reglas de interpretación de los contratos:

Art. 1566 CC. "(...) Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por ella."

B) Manifestación de voluntad tácita (Implícita o presunta):

Se realiza a través de un comportamiento que, a diferencia de la declaración, no va dirigido a un destinatario. Existe una conducta concluyente: conducta de la cual, a través de un proceso de deducción lógica, se hace posible extraer una conclusión inequívoca, y desprender una manifestación de voluntad implícita o indirecta.¹

3. La manifestación de voluntad en el CC.

En el CC, la manifestación expresa y la tácita tienen el mismo valor, al igual que en el CCom (Art. 103 CCom).

Excepcionalmente, se requiere necesariamente manifestación expresa. Ej. Testamento, solidaridad. Asimismo, las partes pueden determinar que no sea suficiente la manifestación tácita.

¹ Ejemplo: Un vendedor ambulante que, sentado en silencio, tiene sus productos desplegados en un paño, en señal de estar ofreciendo su venta.

4. El silencio.

Se discute si puede o no atribuirse al silencio el significado de una manifestación de voluntad.

La regla general es la negativa, pero excepcionalmente puede tener el valor de una manifestación de voluntad.

- i. La ley puede atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad:

Ej.

- Asignatario constituido en mora de declarar si acepta o repudia la herencia, se entiende que repudia (Art. 1233 CC)
- Personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos, transcurrido un término razonable desde que se les hace el encargo, su silencio se mira como aceptación (Art. 2125 CC).

- ii. Las partes pueden atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad:

Ej. En la sociedad o el arrendamiento, es frecuente que las partes establezcan que si al vencimiento del plazo nada se dice, se entenderá renovado el contrato.

- iii. El juez puede atribuir al silencio el valor de manifestación de voluntad:

Silencio circunstanciado: aquel que necesariamente debe ir acompañado de antecedentes o circunstancias externas que permitan atribuir al silencio, inequívocamente, el valor de una manifestación de voluntad.²

5. Reglamentación aplicable al silencio.

En lo que sea aplicable, se sujeta a las mismas reglas que toda manifestación de voluntad. Por ello, es posible que se encuentre viciado por error, fuerza o dolo.

No es lo mismo, jurídicamente, el silencio del cual puede extraerse una manifestación de voluntad, que el silencio de la personas que tenía la carga de manifestar explícitamente algo por mandato de la ley. Ej. Vicios redhibitorios.

6. Segundo requisito: La manifestación de voluntad debe ser seria.

Seria: existe el propósito de producir un efecto práctico sancionado por el Derecho. En definitiva, lo apreciará el juez.

Ejemplo legal de voluntad no seria: Art. 1478 CC.

² Ejemplo: Dos empresas mantienen una relación comercial, existiendo varios contratos entre ellas en que le dan al silencio el valor de una manifestación de voluntad. En un nuevo contrato, aunque no le den dicho valor al silencio, el juez podría hacerlo, pues ello se desprende de las circunstancias del caso.

7. Fases en que puede observarse el elemento subjetivo.

1. Voluntad de la declaración: el sujeto se representa la existencia de una necesidad, para cuya satisfacción debe relacionarse con otros. La voluntad se manifiesta en el querer interno, a partir del cual el sujeto manifiesta su voluntad, la exterioriza. Es importante que el sujeto tenga conciencia de la trascendencia social de su manifestación, pues esta conciencia es el fundamento de su responsabilidad.
2. Voluntad del contenido: el sujeto quiere lograr un fin práctico, reconocido y sancionado por el Derecho. Su manifestación se encamina hacia ese fin.
3. Voluntad normativa: exteriorizada la voluntad, ésta se hace objetiva y adquiere vida independiente. Es la intención de las partes de quedar vinculadas con el acto jurídico del cual conocen su significación y valor.

2.2 PRINCIPIO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD.

1. Conceptos generales.

La Teoría General del AJ descansa sobre dos pilares: libertad y voluntad.

La persona es libre para vincularse con otros, y si decide obligarse, lo hará por su propia voluntad.

Suponiendo que todas las personas son iguales y libres, todo contrato libremente convenido por las partes es necesariamente equitativo, por lo que cualquier traba implicaría una injusticia.

En el campo de la economía, esto se traduce en el liberalismo. El comercio se basa en la libertad ilimitada.

Los conceptos de libertad y voluntad dan origen al principio de la autonomía de la voluntad.

a) Autonomía

La autonomía, en términos genéricos, significa autorregulación o auto reglamentación, es decir, es la capacidad que se le reconoce a alguien para autodictarse sus propias normas, con independencia de otra persona.

b) Autonomía privada

Consiste en un poder que el ordenamiento jurídico confiere (reconoce) al individuo para que gobierne sus propios intereses, es autorregulación de intereses y relaciones jurídicas. Es un poder de autogobernarse, de dictarse sus propias normas, es decir, de decidir, reglamentar o no las relaciones jurídicas en las que desee ser parte o no.

Un supuesto de la autonomía es la libertad, aunque no son lo mismo. En efecto, la libertad consiste en la actuación en términos soberanos que una

persona tiene reconocida por el ordenamiento, pero la autonomía, agrega a dicha libertad, un reconocimiento absoluto al acto emanado en ejercicio de dicha libertad. Es decir, es hacer y que esto sea reconocido y eficaz ante los otros, esto es autonomía.

c) La autonomía de la voluntad

Cuando hablamos de autonomía de la voluntad cometemos un equívoco, porque en realidad el sujeto de la autonomía no es la voluntad, sino que el individuo, la persona, que es la esencia del ordenamiento jurídico y del Estado como entidad jurídica que existe para el servicio de la persona humana.

La clave aquí, es que la autonomía de la voluntad no se ejercita “queriendo” – lo que es propio de la voluntad –, sino que todas las potencias y funciones del individuo.

2. Consecuencias del principio de la autonomía de la voluntad.

- i. La persona es libre para obligarse o no, y si lo hace, es por su propia voluntad.
- ii. La persona es libre para renunciar, por su sola voluntad, a un derecho establecido en su beneficio, con tal que mire al interés individual del renunciante y que la ley no prohíba su renuncia (Art. 12 CC).
- iii. La persona es libre para determinar el contenido de los AJ. Lo que los particulares convengan (contenido del contrato) los obliga igual que una ley.
- iv. Cada vez que surjan dudas, debe indagarse por la intención o querer real de las partes (Art. 1560 CC).

3. La autonomía privada.

Autonomía privada: facultad o poder que la ley reconoce a los particulares para regular sus intereses, actuando según su propio juicio y responsabilizándose por las consecuencias de su comportamiento.

El instrumento de la autonomía privada es el AJ.

La autonomía privada supone:

1. La libertad del individuo. La iniciativa surge como consecuencia de la libertad.
2. La autorresponsabilidad, es decir, la obligación de soportar las consecuencias que emanan del AJ.

4. Limitaciones a la autonomía privada.

1. Faculta a los particulares para disponer de sus propios intereses, no de los ajenos.
2. Es necesario que el acto o contrato se ajuste a los requisitos o condiciones que la ley establece para su valor jurídico.

3. Hay materias respecto de las cuales los particulares no pueden crear AJ distintos al tipo establecido por la ley. Esto ocurre en las materias en que está comprometido el interés superior o público, o en las materias relativas a las relaciones de familia.

4. Está limitada también por el orden público y las buenas costumbres.

Orden público: organización considerada como necesaria para el buen funcionamiento general de la sociedad.

Buenas costumbres: aspecto particular del orden público, poco definido, que comprende las ideas morales admitidas en una época determinada.

El acto que infringe cualquiera de las dos, se sanciona con la nulidad absoluta.

5. En cuanto a los AJ innominados, estos no pueden ser arbitrarios o caprichosos, en el sentido de no perseguir un fin práctico, pues no sería merecedor de tutela jurídica.

5. La autonomía privada en el CC.

El CC reconoce el valor de ley sólo a los contratos legalmente celebrados, y subordina la eficacia de la voluntad al respeto a las leyes, las buenas costumbres y el orden público.

6. Reacciones contra el principio de la autonomía de la voluntad.

Se planteó que la voluntad es impotente para crear obligaciones por sí sola; la sociedad es la única que tiene este poder.

Además, la experiencia demuestra que los contratos no son necesariamente justos o equitativos.

Esto influye en la doctrina moderna, la cual no desconoce el rol de la voluntad, pero la considera un instrumento del bien común, un medio al servicio del Derecho, lo que justifica la intervención del legislador.

Así, ha surgido el contrato dirigido: intervención del Estado en los contratos de los particulares, a fin de evitar que una de las partes se aproveche de la inferioridad o debilidad de la otra o de la desigualdad de condiciones en que contratan. Ej. Contrato de trabajo.

2.3 LA VOLUNTAD EN LOS AJ BILATERALES.

1. El consentimiento.

Consentimiento:

- Acuerdo de voluntades de las partes, necesario para dar nacimiento al AJ bilateral.
- Requisito esencial para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad. Art. 1445 CC.

2. Formación del consentimiento en los AJ bilaterales.

Está reglamentada por el Código de Comercio (Arts. 97-108 CCom), que rige también la formación del consentimiento en las convenciones reglamentadas por el CC, pues se trata de una materia de aplicación general.

El Código de Comercio señala expresamente que viene a llenar un sensible vacío de la legislación civil.

3. La oferta.

Oferta: Acto jurídico unilateral por el cual una persona propone a otra celebrar una determinada convención.

Hay que tener en cuenta que la oferta es un AJ unilateral recepticio, es decir, para que produzca los efectos jurídicos deseados por su autor es necesario que la persona a la que va dirigida manifieste su voluntad.

a) Requisitos de la oferta:

1) Como toda manifestación de voluntad debe manifestarse y ser seria.

2) Debe ser completa: debe formularse en términos tales que baste con la simple aquiescencia de la persona a quien la oferta se dirige para que la convención se perfeccione.

Si el contrato es nominado, es completa la oferta que contiene los elementos esenciales del contrato propuesto.

Si no contiene estos elementos, la oferta es incompleta. Con ella lo que se pretende es establecer una negociación preliminar.

La respuesta del destinatario formulando, a su vez, otra oferta, se llama contraoferta.

b) Clasificación de la oferta.

A) Oferta expresa:

Está contenida en una declaración, en la cual el proponente, en términos explícitos y directos, revela su intención de celebrar una determinada convención. Puede ser:

1. Verbal: se manifiesta con palabras o gestos que hagan inequívoca la proposición de celebrar una convención.
2. Escrita: se hace a través de la escritura.

B) Oferta tácita:

Se desprende de un comportamiento que revela inequívocamente la proposición de celebrar una convención.³

³ Ejemplo: Un taxi que circula con el cartel de "libre" encendido.

C) Oferta hecha a persona determinada:

Va dirigida a un destinatario debidamente individualizado.

D) Oferta hecha a persona indeterminada:

No va dirigida a ninguna persona en especial, sino al público en general. Si se realizan en cualquier especie de anuncio impreso, no engendran obligación alguna para el que las hace (Art. 105 CCom).

Lo que dispone el C. de Comercio en el Art. 105 quedaría sin efecto (para las personas que encuadran dentro de la categoría de proveedores) por lo señalado en el artículo 12 de la Ley del Consumidor que prescribe:

Artículo 12 Ley de Consumidor: Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio.

c) Persona de quien puede emanar la oferta.

Es indiferente que la oferta emane del futuro acreedor o del futuro deudor.

4. La aceptación.

Aceptación: AJ unilateral por el cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con ella.

a) Clasificación de la aceptación.

A) Aceptación expresa:

Se contiene en una declaración en la cual el destinatario de la oferta manifiesta en términos explícitos y directos su conformidad con ella. Puede ser:

1. Verbal: se manifiesta por palabras o gestos.
2. Escrita: se hace por la escritura.

B) Aceptación tácita:

Se desprende de un comportamiento que revela inequívocamente la aceptación.

C) Aceptación pura y simple:

El destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con ésta en los mismos términos en que se le formuló.

D) Aceptación condicionada:

El destinatario de la oferta le introduce modificaciones o sólo se pronuncia parcialmente. Esto importa una contraoferta (Art. 102 CCom).

b) Aceptación parcial cuando la oferta comprende varias cosas.

Para determinar los efectos, hay que distinguir:

- a) La intención del oferente era formular una oferta divisible: se entiende que ha hecho varias ofertas, formándose el consentimiento respecto de aquellas que el destinatario aceptó.
- b) La intención del oferente era formular una oferta indivisible: la aceptación parcial no es idónea para formar el consentimiento, siendo sólo una contraoferta.

c) Requisitos que debe reunir la aceptación para que se forme el consentimiento.

i. Aceptación pura y simple:

El destinatario de la oferta debe aceptarla en los mismos términos en que se le formuló (Art. 101 CCom).

ii. Aceptación en término oportuno:

Debe manifestarse la aceptación dentro del plazo legal o dentro del plazo señalado por el oferente. Hay que distinguir:

- 1. Si la oferta es verbal: la aceptación debe darse en el acto de ser conocida por el destinatario (Art. 97 CCom).
- 2. Si la oferta es escrita: hay que distinguir nuevamente (Art. 98 CCom):
 - Si el destinatario reside en el mismo lugar que el oferente: la oferta debe aceptarse dentro del plazo de 24 horas.
 - Si el destinatario reside en un lugar distinto: debe aceptar a vuelta de correo.

Aceptación extemporánea: aquella que se da fuera de las oportunidades indicadas.

Vencidas estas oportunidades, la oferta se tiene por no hecha. El oferente está obligado a comunicar al aceptante que su aceptación ha sido extemporánea. (Art. 98 CCom).

La aceptación no se presume, pero una vez probada, se presume que se ha dado dentro de plazo, a menos que se pruebe lo contrario.

iii. Aceptación mientras la oferta se encuentre vigente:

Hechos que producen la pérdida de vigencia de la oferta:

1. Retracción tempestiva: arrepentimiento del oferente a su propuesta. El oferente puede retractarse válidamente en el tiempo que media entre el envío de la oferta y la aceptación; excepcionalmente no tiene esta posibilidad en los siguientes casos (Art. 99 CCom):

- Si al hacer la oferta se comprometió a esperar contestación.
- Si se comprometió a no disponer del objeto del contrato sino después de transcurrido cierto plazo.

Efectos de la retractación: hay que distinguir:

a) Retracción tempestiva: aquella que se produce antes de la aceptación de la oferta. En este caso, la aceptación no forma el consentimiento, pero aún así, el oferente que se retracta debe indemnizar gastos, daños y perjuicios que puede haber sufrido el destinatario (Art. 99 CCom), pudiendo liberarse de esta obligación si se allana a cumplir el contrato propuesto (Art. 101 CCom).

b) Retracción intempestiva: aquella que se produce después de la aceptación de la oferta. En este caso, el oferente no puede exonerarse de cumplir el contrato propuesto.

2. Muerte o incapacidad sobreviniente del oferente.

5. Momento en que se forma el consentimiento.

Esto tiene importancia:

1. En lo que respecta a la capacidad de las partes: deben ser capaces al momento de contratar.
2. En lo que respecta al objeto del contrato: debe ser lícito al momento de contratar.
3. En lo que respecta a las leyes que se aplicarán al contrato: en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración (Art. 22 LERL).
4. En lo que respecta a los efectos del contrato: se empiezan a producir desde el momento en que se perfecciona el contrato.
5. En lo que respecta a la retractación del oferente: no puede retractarse válidamente una vez formado el consentimiento.

6. Teorías para determinar el momento en que se forma el consentimiento.

1. Teoría de la declaración de voluntad o de la aprobación:

El consentimiento se forma en el momento en que el destinatario acepta la oferta, aunque la aceptación sea ignorada por el oferente.

2. Teoría de la expedición:

El consentimiento se forma en el momento en que el destinatario de la oferta envía la correspondencia que contiene su aceptación.

3. Teoría de la recepción:

El consentimiento se forma en el momento en que la aceptación, contenida en una carta o telegrama, llega al domicilio del oferente.

4. Teoría del conocimiento o de la información:

El consentimiento se forma en el momento en que el oferente toma conocimiento de la aceptación.

- El CCom (Arts. 99 y 101) se inclina por la teoría de la declaración.
- Respecto a este punto es conveniente hacer notar que esta teoría tiene como límite los contratos reales y solemnes, que se perfeccionan con la entrega de la cosa y las solemnidades requeridas, correspondientemente (Art. 1443 CC).
- Excepcionalmente encontramos en el CC un caso en que no basta la sola aceptación: las donaciones entre vivos, que acoge la teoría del conocimiento (Art. 1412 CC).

7. Lugar en que se forma el consentimiento.

Es importante porque:

1. El contrato se rige por la ley del lugar.
2. El lugar determina la costumbre que se aplica a ciertos contratos.
3. También determina, en ciertos casos, el tribunal competente.

El CCom dispone que si los interesados residen en distintos lugares, se entiende celebrado el contrato en el de la residencia del que haya aceptado la propuesta original o la modificada.

2.4 LOS VICIOS DE LA VOLUNTAD.

Vicios de la voluntad: circunstancias que atentan contra la posibilidad de que la voluntad se manifiesta de forma libre e informada.

El acto en que falta la voluntad no existe. En cambio, el acto en que incide un vicio de la voluntad, existe, pero expuesto a ser invalidado.

El Art. 1445 CC requiere, en primer lugar, el consentimiento, y agrega que éste no debe adolecer de vicios, de lo que se infiere que el consentimiento puede faltar, o bien existir pero viciado.

Art. 1451 CC. Los vicios de que puede adolecer el consentimiento, son error, fuerza y dolo.

Crítica al Art. 1451 CC. Habla de consentimiento y debería decir voluntad puesto que puede también estar viciada la voluntad del autor de un AJ unilateral.

2.4.1 EL ERROR

1. Conceptos generales.

Error: falsa representación de la realidad determinada por la ignorancia o por la equivocación.

Lo que determina a una persona a manifestar su voluntad es el conocimiento que tenga de la realidad. Existe en el sujeto un hecho psicológico de carácter positivo (representación de la realidad) que lo induce a actuar, pero dicha representación es falsa por ignorancia o equivocación.

La manifestación del sujeto no puede, en este caso, producir válidamente sus efectos propios. Existe voluntad, pero se encuentra viciada.

2. Equivocación e ignorancia.

Quien ignora algo no tiene noción de una cosa; quien se equivoca tiene una noción, pero errada.

Cualquiera de estos dos conceptos puede configurar el error.

La duda excluye al error, pues en ella el sujeto tiene conciencia de que su representación de la realidad puede ser falsa, y ella no lo inhibe para actuar. Existen, sin embargo, ciertos AJ en los cuales subyace una duda objetiva, la cual no excluye el campo de aplicación del error.

3. Hechos que constituyen la realidad.

La pregunta es si la realidad corresponde a hechos presentes, pasados o futuros.

No cabe aplicar la teoría del error respecto de cosas que al tiempo del contrato no existen. Error de previsión: equivocación al proyectarse hacia un futuro que, al hacerse realidad, lo pondrá o no de manifiesto.

4. El error es un vicio del conocimiento.

El error es un vicio del conocimiento, más que del consentimiento.

5. La teoría del error en el CC.

- Arts. 1451 a 1455 CC reglamentan el error como vicio del consentimiento;
- El Art. 1057 CC señala los efectos del error en el nombre o calidad de un asignatario testamentario;
- El Art. 677 CC determina los efectos del error en la tradición,
- y el Art. 2455 CC reglamenta el error en la transacción.

6. Clases de error. (Arts. 1451 a 1455 CC)

Hay dos clases: error de derecho y error de hecho. Sin embargo, esta distinción es doctrinaria, puesto que el CC no lo clasifica expresamente.

1. EL ERROR DE DERECHO.

Error de derecho: falsa o inexacta representación de la realidad jurídica por:

- i. la ignorancia de una norma
- ii. o bien por la equivocada interpretación
- iii. o inexacta aplicación de la misma a un caso concreto.

El error de derecho no vicia el consentimiento, lo que significa que no puede alegarse, para impedir las consecuencias jurídicas de los actos lícitos ni para exonerarse de responsabilidad por los actos ilícitos, salvo en los casos expresamente exceptuados por la ley.

Art. 1452 CC. El error sobre un punto de derecho no vicia el consentimiento.
--

Esto es consecuencia lógica de la ficción legal que supone que las normas jurídicas son conocidas por todos (Art. 8º CC: Nadie puede alegar ignorancia de ley después que ésta haya entrado en vigencia). Más aún, el Art. 706 CC presume la mala fe de quien alega error sobre un punto de derecho en materia posesoria (El error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe, que no admite prueba en contrario)

Así, el sujeto no puede sustraerse de las consecuencias de su declaración alegando que su voluntad está viciada por ignorancia o falso concepto de una norma jurídica.

Esto tiene dos excepciones aparentes en relación al cuasicontrato de pago de lo no debido, en las cuales la víctima del error, no obstante éste, puede sustraerse de las consecuencias jurídicas de la declaración de voluntad que no hubiera efectuado si hubiese tenido una acertada representación de la realidad jurídica.

Situación del Art. 2297 CC. "Se podrá repetir aun lo que se ha pagado por error de derecho cuando el pago no tenía por fundamento ni aun una obligación puramente natural."

Situación del Art. 2299 CC. "Del que da lo que no debe, no se presume que lo dona, a menos de probarse que tuvo perfecto conocimiento de lo que hacía, tanto en el hecho como en el derecho." Por lo tanto, si una persona da lo que no debe porque incurrió en un error de derecho, ese error va a ser relevante: impide presumir la donación.

El carácter aparente de estas excepciones se funda en el hecho de que para ser verdaderas excepciones, el efecto que debería generarse es viciar la voluntad, sin embargo, de los Art. 2297 y 2299 CC lo que se genera es una acción de repetición propia de los cuasicontratos que busca reparar el enriquecimiento sin causa.

2. EL ERROR DE HECHO¹.

Error de hecho: falsa representación que se tiene, por ignorancia o equivocación, de una cosa, de un hecho o de una persona.

Error esencial (en sentido amplio): aquel que es relevante e invalida el contrato.

Las hipótesis de error constituyen una discrepancia entre lo querido y lo declarado.

Sin embargo, en el error obstativo u obstáculo, no se produce esta discrepancia, sino que los planteamientos de las partes son diametralmente opuestos e imposibles de conciliar (porque no están de acuerdo en el contrato que se celebra o en el objeto del contrato): no hay acuerdo de voluntades.

¹ Además de los requisitos que se estudiarán en cada tipo de error en particular, parte de la doctrina ha señalado que para viciar el consentimiento la equivocación ha de ser excusable, esto es, no debe poder ser atribuido a la propia negligencia de quien lo invoca.

I. EL ERROR ESENCIAL U OBSTÁCULO. ART. 1453 CC

El Art. 1453 CC regula dos supuestos de error:

1. Error que recae sobre la especie del acto o contrato que se ejecuta o celebra.
2. Error que recae sobre la identidad de la cosa específica de que se trata.

Art. 1453 CC. El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra, como si una de las partes entendiese empréstito y la otra donación; o sobre la identidad de la cosa específica de que se trata, como si en el contrato de venta el vendedor entendiese vender cierta cosa determinada, y el comprador entendiese comprar otra.

El error obstáculo es considerado un vicio del consentimiento, pese a que doctrinariamente error obstáculo y error vicio son dos cosas distintas.

Sanción del error obstáculo.

Existen 3 interpretaciones:

1. Para quienes estiman que este error impide el acuerdo de voluntades, la convención sería jurídicamente inexistente (falta la voluntad).
2. Otros estiman que la sanción es la nulidad absoluta, pues, pese a que el error impide el consentimiento, la inexistencia no está considerada como sanción por el CC.
3. Los demás creen que la sanción es la nulidad relativa. Razones:
 - i. El Art. 1453 CC dice que este error vicia el consentimiento, y de acuerdo al Art. 1682 inc. final CC, cualquier vicio que no esté configurado como causal de nulidad absoluta produce la nulidad relativa.
 - ii. Este error sólo perjudica al interés particular de los contratantes y no al interés general de la sociedad.
 - iii. "*Asimismo*" del Art. 1454 CC. El Art. 1453 señala que este tipo de error vicia el consentimiento. Luego, el Art. 1454 CC, que asigna al error de hecho la sanción de nulidad relativa, comienza diciendo "*el error de hecho vicia asimismo el consentimiento*" de manera que se hace extensiva la misma sanción al Art. 1453 precedente.

II. EL ERROR SUSTANCIAL O ERROR SOBRE LAS CALIDADES ESENCIALES DE UNA COSA. ART. 1454 INC. 1.

Art. 1454 inc. 1 CC. El error de hecho vicia asimismo el consentimiento cuando la sustancia o calidad esencial del objeto sobre que versa el acto o contrato, es diversa de lo que se cree; como si por alguna de las partes se supone que el objeto es una barra de plata, y realmente es una masa de algún otro metal semejante.

La víctima del error atribuye a la cosa objeto del acto o contrato una sustancia o calidad esencial que en realidad no tiene.

Sustancia: materia concreta que constituye una cosa, lo que supone un concepto estrictamente objetivo y materialista.

Calidad esencial: dice relación con la intención de las partes y sus motivos para contratar en relación a las características que le atribuyen a la cosa. Por lo tanto, es un concepto subjetivo.

El error en la sustancia vicia el consentimiento sólo cuando la sustancia o materia que se la atribuye a la cosa constituye, a lo menos para una de las partes del contrato, una calidad esencial. La expresión clave del Art. 1454 CC es “calidad esencial”.

No es posible formular una regla jurídica que permita establecer en abstracto qué es lo que constituye la calidad esencial de una cosa. Depende de la intención de las partes.

Pero, dado que no es frecuente que las partes dejen expresamente establecido qué es lo que constituye para ellas la calidad esencial, corresponderá al juez determinarla, atendiendo a las circunstancias del caso concreto. En este sentido, si bien el concepto de calidad esencial atiende a cuestiones subjetivas, el ejercicio del juez para determinar qué es una calidad esencial necesariamente se remitirá a cuestiones objetivas: ¿qué calidades de la cosa habrían sido consideradas esenciales por un contratante promedio en estas circunstancias concretas? Así, este concepto subjetivo se “objetiviza” por medio de la figura del contratante promedio.

El error en la sustancia, por regla general, es relevante, en el entendido de que la consideración de que la cosa tiene una determinada sustancia es lo que resuelve a una de las partes a contratar. Pero esta presunción puede ser desvirtuada, demostrando que el error no era relevante.

Se discute si constituye o no cualidad relevante de la cosa adquirida a título de compraventa la circunstancia de pertenecer en dominio al vendedor, pues la venta de cosa ajena es válida. Si el comprador pidiera la nulidad de la compraventa, alegando que para él constituía calidad esencial de la cosa que ésta le perteneciera al vendedor, el juez podría presumir esa intención si las circunstancias del caso lo permitieran.

Efectos del error sustancial.

Vicia el consentimiento; su sanción es la nulidad relativa.

III. ERROR SOBRE LAS CALIDADES ACCIDENTALES. ART. 1454 INC. 2.

Art. 1454 inc. 2 CC. El error acerca de otra cualquiera calidad de la cosa no vicia el consentimiento de los que contratan, sino cuando esa calidad es el principal motivo de una de ellas para contratar, y este motivo ha sido conocido de la otra parte.

Para saber qué son calidades accidentales de una cosa, es preciso determinar primero cuáles son las calidades esenciales de la misma. Todas las demás son accidentales.

El error en las calidades accidentales no es relevante.

Requisitos para que vicie el consentimiento:

1. esa calidad constituya el motivo determinante que tuvo una de las partes para contratar,
2. y esto haya sido conocido por la otra parte.

Efectos del error sobre las calidades accidentales.

No vicia, por regla general, el consentimiento, a menos que:

1. la calidad accidental sea el motivo principal que determinó a una de las partes a contratar
2. y que la otra conozca dicho motivo.

Cuando vicia el consentimiento, la sanción es la nulidad relativa.

Labor del juez cuando se alegare por una de las partes en un contrato que ha sido víctima de error sobre las calidades o cualidades de una cosa.

1. Debe deducir cuáles serían las cualidades de la cosa que la mayoría de las personas consideraría, en esas mismas circunstancias, esenciales y relevantes para contratar, en términos tales que, de conocer que faltaban, se habría abstenido de contratar.
2. Si se produce una coincidencia entre la apreciación que hace la víctima y la deducción del juez, deberá rescindir el contrato, a menos que la parte en contra de la cual se declare la rescisión pruebe que el error no fue determinante para su contraparte.
3. Del proceso deductivo surge, por exclusión, el concepto de calidad accidental, respecto del cual existe una presunción contraria: no es, por regla general, el motivo principal para contratar, por tanto, la víctima deberá probar que esa calidad no esencial fue el principal motivo.

IV. ERROR EN LA PERSONA.

Quien sufre este error yerra en identidad de una persona o en alguna de sus cualidades personales.

Este error es, por regla general, irrelevante (Art. 1455 CC).

Art. 1455 CC. El error acerca de la persona con quien se tiene intención de contratar no vicia el consentimiento, salvo que la consideración de esta persona sea la causa principal del contrato.

Pero en este caso la persona con quien erradamente se ha contratado, tendrá derecho a ser indemnizada de los perjuicios en que de buena fe haya incurrido por la nulidad del contrato.

Excepcionalmente, cuando el acto se celebra en consideración a una persona determinada, es relevante y reviste carácter esencial: actos intuitu personae. Esto es lo que sostiene la doctrina tradicional.

Ej.

- Actos de familia que se suponen celebrados en consideración a persona determinada.
- Los actos patrimoniales, por regla general, no son intuitu personae, salvo en el caso de los contratos gratuitos que se suponen celebrados en atención a persona determinada (como la donación) y los onerosos que importan confianza en una persona específica (como el mandato).

La doctrina moderna es más amplia: será preciso demostrar en cada supuesto que el error en la persona ha sido esencial y determinante del consentimiento. En los contratos basados sustancialmente en el intuitu personae, normalmente no será necesario probar la esencialidad, por la índole del contrato.

Cualidades personales: notas o caracteres objetivos de índole estable o permanente que configuran la personalidad.

El error en la persona es especialmente relevante en el matrimonio. En él, el error se refiere a la identidad de la persona del otro contrayente.

La opinión dominante estima que esta identidad comprende no sólo la física, sino también las cualidades relevantes, interpretadas con criterio restrictivo. Ej. de cualidades relevantes: creer a la mujer honrada mientras se dedica a la prostitución, no saber que el contrayente ha sufrido condenas penales o que tiene una enfermedad transmisible a los herederos.

Efectos del error en la persona.

Por regla general es irrelevante. Pero en los contratos en que la consideración de la persona es la causa principal para contratar, el error vicia el consentimiento. Se sanciona con la nulidad relativa.

Declarada la nulidad, la persona con que erradamente se contrató tiene derecho a demandar indemnización de perjuicios, siempre que haya estado de buena fe.

7. El error en los AJ unilaterales.

Por regla general, el error puede invocarse como causal de anulación en todos los AJ, incluso unilaterales, siempre que revista carácter de relevante.

Ej

.

- La asignación que pareciere motivada por error de hecho, quedando claro que sin el error no habría tenido lugar, se tendrá por no escrita (Art. 1058 CC).
- El error en el nombre o calidad del asignatario testamentario no vicia la disposición si no hubiera duda acerca de la persona (Art. 1057 CC).
- La aceptación de una herencia puede rescindirse por lesión, que supone siempre un error: el aceptante debe ignorar que por disposiciones testamentarias de que no tenía noticia el valor de la asignación ha disminuido a más de la mitad (Art. 1234 CC).

2.4.2 LA FUERZA

1. Conceptos generales.

Fuerza: apremios físicos o morales que se ejercen sobre una persona destinados a que preste su consentimiento para la celebración de un AJ.

Es un vicio de la voluntad porque se opone a la libertad, sin embargo, se restringe a la fuerza moral porque la fuerza física excluye la voluntad.

2. Fuerza moral.

En ella, el apremio se ejerce sobre la psiquis de la víctima con el fin de intimidarla. Se produce una manifestación de voluntad del sujeto, pero éste no ha sido libre, pues la manifestación le fue impuesta por una amenaza actual de un mal futuro.

3. Requisitos doctrinarios para que la fuerza moral vicie la voluntad.

A) Fuerza moral importante:

Aquella que influye de manera significativa en el ánimo de la víctima. Para ello se toma en consideración un tipo medio de persona sensata, apreciando edad, sexo y otras condiciones. Fuerza moral injusta:

El mal con que se amenaza debe ser ilegítimo, es decir, contrario a derecho; o bien, no siendo en sí mismo ilícito, debe perseguir la consecución de una ventaja desproporcionada e injusta.

La amenaza no es injusta cuando se tiene derecho a ejercerla. Ej. Amenaza de embargar los bienes del deudor. Pero aun cuando se tenga este derecho, es injusta en cuanto sirva para obtener beneficios injustos.

Para la licitud de la amenaza no basta con que su objeto sea permitido, ni que constituya una práctica jurídica, ni tampoco que el resultado perseguido sea lícito y susceptible de coacción jurídica. Debe elegirse el justo medio encaminado a la consecución del resultado.

4. De quién puede provenir la amenaza.

Debe provenir necesariamente de una persona:

- la contraparte
- el destinatario de una declaración unilateral
- o un tercero

No importa que quien ejerce la amenaza no tenga intención de concretarla. Lo decisivo es que la amenaza se haya realizado con la voluntad y conciencia de determinar al otro sujeto al negocio.

5. Hechos que no constituyen fuerza moral.

No hay violencia o fuerza cuando:

- la víctima, por error, se autosugestiona con la impresión de una amenaza inexistente.
- Tampoco la hay en el temor reverencial: estado de sujeción en el que nos encontramos por razones de obediencia, gratitud, respeto, admiración o devoción frente a otros.

6. La fuerza en el CC.

Se encuentra regulada como vicio en los Arts. 1456 y 1457 CC.

Art. 1456 CC. La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como una fuerza de este género todo acto que infunde a una persona un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave.

El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento.

Art. 1457 CC. Para que la fuerza vicie el consentimiento no es necesario que la ejerza aquel que es beneficiado por ella; basta que se haya empleado la fuerza por cualquiera persona con el objeto de obtener el consentimiento.

7. Requisitos legales para que la fuerza vicie el consentimiento.

- 1) **Grave.** Es aquella capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Será el juez quien determine si la fuerza cumple o no este requisito. La víctima debe probar:
 - i. la existencia de la amenaza;
 - ii. la gravedad de la misma.Por excepción, la ley presume la gravedad cuando la amenaza infunde en la víctima un justo temor de verse expuesta ella, su consorte o alguno de sus ascendientes o descendientes, a un mal irreparable y grave.
- 2) **Injusta o ilícita.** El CC no lo exige, pero hay consenso en la doctrina nacional en que el apremio debe ser contrario a la ley o al derecho.
- 3) **Determinante.** El consentimiento obtenido con la amenaza debe ser consecuencia inmediata y directa de ella, de modo que sin la fuerza, la víctima no habría celebrado el acto para el cual se la forzó.

8. De quiénes puede provenir la fuerza.

Es indiferente que provenga de una de las partes o de un tercero (Art. 1457 CC).

9. El temor reverencial.

El Art. 1456 inc. 2º CC define temor reverencial como "... el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto...". No vicia el consentimiento.

10. Efectos de la fuerza moral.

El acto existe, pero con un vicio que lo expone a ser invalidado. La sanción es la nulidad relativa.

11. El estado de necesidad.

En el estado de necesidad, el sujeto que se siente amenazado por un hecho de la naturaleza o un acto de la persona, para evitar el daño que teme, adopta un determinado comportamiento que puede producir un daño a terceros o bien producir un daño de sus propios intereses. Este sujeto no va a estar obligado a reparar los daños que produzca a terceros. En caso de que el

comportamiento afecte los intereses propios, el sujeto, entre dos males, está escogiendo el que cree el menor. Aquí se produce una situación semejante a la fuerza. Pero ambas se diferencian en que:

1. En el estado de necesidad, la coacción puede derivar de un hecho natural o humano, en cambio en la fuerza, proviene necesariamente de la persona.
2. En el estado de necesidad, el hecho no está encaminado a obtener una manifestación de voluntad, en cambio en la fuerza, el apremio va directamente dirigido a obtener el consentimiento.

En el CC, el contrato que se celebró como consecuencia del estado de necesidad no es, por esta causa, rescindible. Tampoco podría pretenderse la rescisión por lesión, pues esta institución objetiva es aplicable sólo a los casos determinados por ley.

2.4.3 EL DOLO

1. Conceptos generales de dolo.

En el dolo también se produce una falsa representación de la realidad; pero, a diferencia del error, ésta no surge en forma espontánea, sino que es consecuencia de las maquinaciones o maniobras fraudulentas fraguadas por otras personas para inducir a error al sujeto.

Concepto legal de dolo: Dolo: intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. (Art. 44 inc. final CC)

Concepto doctrinario de dolo: vicio del consentimiento constituido por la maquinación fraudulenta destinada a que una persona preste su consentimiento para la celebración de un acto o contrato.

El dolo es un engaño provocado, pero hay que tener presente que constituye un vicio distinto del error. Aún cuando el error provocado por el dolo sea irrelevante, el acto en que incide va a ser ineficaz.

2. Clasificación del dolo.

A) Dolo bueno y dolo malo:

1. Dolo bueno: engaño menor, producto de las exageraciones que son normales en el comercio. Es la jactancia o exageración de las cualidades o del valor de la cosa ofrecida. Es un comportamiento lícito.
2. Dolo malo: supone un comportamiento ilícito, destinado a engañar a otra persona y que la induce a una manifestación de voluntad que, sin el dolo, no habría realizado, o habría realizado en condiciones menos onerosas. Excede de la simple exageración.

B) Dolo positivo y dolo negativo:

1. Dolo positivo: el engaño se realiza a través de razonamientos o actos tendientes a representar como verdaderas circunstancias falsas o a suprimir o alterar las verdaderas.
2. Dolo negativo: el engaño consiste en ocultar sagazmente hechos verdaderos. Es una omisión: silencio o reticencia⁴

C) Dolo determinante y dolo incidental:

1. Dolo determinante: induce en forma directa a una persona a realizar una manifestación de voluntad que, de no mediar el dolo, se habría abstenido de realizar.
2. Dolo incidental: no es determinante para la manifestación de voluntad, que la víctima hubiera formulado de todas maneras aunque, de no existir el dolo, la hubiera formulado en condiciones menos onerosas.

3. De qué personas puede provenir el dolo.

1. AJ unilaterales: necesariamente de una persona que no es parte en el acto.
2. AJ bilaterales: de una de las partes o de un tercero. Si proviene de una de las partes y es determinante, vicia el consentimiento. Si proviene de un tercero, no vicia el consentimiento, salvo que la parte beneficiada con él tuviere conocimiento del dolo y no lo hubiere advertido a su contraparte; reticencia que, de ser determinante, vicia el consentimiento.
3. AJ plurilaterales: de una de las partes o de un tercero. La nulidad sólo la pueden pedir las partes que fueron directamente engañadas, y el acto se invalida sólo para ellas, salvo que la participación de éstas en el contrato sea esencial para las demás.

4. El dolo en el CC.

El dolo no sólo es tratado en nuestro CC como vicio de la voluntad. Su campo de aplicación abarca tres materias:

1. Vicio de la voluntad;
2. Circunstancia agravante de la responsabilidad del deudor que no cumple la obligación asumida (Art. 1558 CC);
3. Elemento del supuesto de hecho del delito civil (intención de causar daño, Art. 2284 CC).

5. Discusión doctrinaria en torno a la aplicación del concepto legal de dolo.

Una parte de la doctrina sostiene la aplicación del concepto legal a las tres materias antes señaladas. Sin embargo, otra postura doctrinaria sostiene que

⁴ Parte de la doctrina ha estimado que para que sea posible configurar un dolo por reticencia, es necesaria la existencia correlativa de un deber de informar.

el artículo 44 habla de un dolo directo, dirigido a causar daño a otro ("intención positiva"). El dolo eventual, en cambio, revela en el autor una conciencia de estar generando el daño que no ha buscado directamente, le es indiferente.

- En el dolo como vicio del consentimiento, lo que busca la parte es que la otra contrate, mediante engaño, manifestado en maquinaciones fraudulentas; no busca dañarlo, por eso se dice, por parte de la doctrina, que la definición del 44 no le es aplicable.

- En el dolo como agravante de la responsabilidad contractual las maquinaciones fraudulentas están dirigidas a evadir el cumplimiento de la obligación, el daño que se genera en la contraria es consecuencia de esta evasión, pero no es lo buscado directa o "positivamente", por lo que se asimila al concepto de dolo eventual.

- Donde si recibe aplicación, sin dudas, la definición del 44, es en materia de responsabilidad extracontractual (dolo como presupuesto del ilícito civil)

6. El dolo como vicio del consentimiento.

Art. 1458 CC. El dolo no vicia el consentimiento sino cuando es obra de una de las partes, y cuando además aparece claramente que sin él no hubieran contratado. En los demás casos el dolo da lugar solamente a la acción de perjuicios contra la persona o personas que lo han fraguado o que se han aprovechado de él; contra las primeras por el total valor de los perjuicios, y contra las segundas hasta concurrencia del provecho que han reportado del dolo.

Para que el dolo vicie el consentimiento debe reunir dos requisitos copulativos:

1. ser determinante
2. y ser obra de una de las partes (Art. 1458 inc. 1º CC).

Esto se refiere a los AJ bilaterales, más concretamente a los contratos, pero la voluntad puede también estar viciada en los AJ unilaterales. En este caso, basta que el dolo sea determinante, pues el dolo provendrá necesariamente de un tercero, siendo indiferente que ese tercero se beneficie o no.

El dolo produce un error, y aunque ese error sea irrelevante, el dolo se sanciona siempre.

Por tener un alcance tan amplio, el dolo se excluye del matrimonio.

7. Efectos que atribuye el CC al dolo.

Vicia la voluntad cuando es determinante y obra de una de las partes. Se sanciona con la nulidad relativa.

Si no reúne los requisitos, no vicia el consentimiento, pero da derecho a la víctima para pedir indemnización de perjuicios.

Para obtener esta indemnización, la víctima tiene 2 posibilidades (Art. 1458 inc. 2º CC):

1. Demandar a la persona que fraguó el dolo por el total.
2. Demandar a la persona que, sin haber fraguado el dolo, ha obtenido provecho de él, hasta la concurrencia de dicho provecho (art. 2316 CC)

8. Acción por provecho del dolo ajeno

La acción por provecho de dolo ajeno se ha construido doctrinalmente a partir de lo establecido en los incisos segundos de los artículos 1458 y 2316 del Código Civil. Se afirma que tales disposiciones consagrarían una acción general que permite dirigirse en contra del tercero que obtuvo beneficios como consecuencia de un acto doloso cometido por otra persona, con el objeto que entregue dicho provecho a la víctima del dolo.

La acción constituiría una manifestación del rechazo al dolo y al enriquecimiento sin causa que se encuentra a lo largo del Código Civil. En este sentido se ha señalado que es el enriquecimiento injustificado del tercero, en tanto su ganancia ha sido obtenida con dolo ajeno, lo que genera su obligación de pagar al demandante por el monto del provecho⁵.

8.1 Naturaleza jurídica de la acción: ¿acción indemnizatoria o restitutoria?

Entre quienes consideran que tiene naturaleza indemnizatoria se encuentra Ramón Domínguez, quien además de considerar que se trata de una acción de indemnización de perjuicios fundada en el enriquecimiento injusto, exige que para su interposición se haya previamente fallado que existe un delito civil por parte del autor del dolo.⁶

Por otra parte, la mayoría de la doctrina nacional considera que se trata de una acción restitutoria. Así por ejemplo Carlos Pizarro, Enrique Barros, Alberto Pino, entre otros⁷. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema.

⁵ Pino, Alberto (2016): "La restitución de ganancias ilícitas y la acción del provecho por dolo ajeno", en: Revista Ius et Praxis, Año 22, Nº 1; Zúñiga, Francisco (2016), Informe en derecho "Sobre la procedencia de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos segundos de los artículos 1458 y 2316 del Código Civil"; Peña, Carlos (2016): Informe en derecho "Sobre la constitucionalidad de los artículos 1458 y 2316 aplicados al cobro de un crédito legítimo", los dos últimos en Rol Nº2985-16, Tribunal constitucional.

⁶ Domínguez, Ramón (2009): "Sobre el artículo 2316 inciso segundo del Código Civil y la acción contra el que recibe provecho del dolo ajeno", en: Revista de Derecho Universidad de Concepción (Nº 225-226).

⁷ Barros Bourie, Enrique (2006): "Tratado de Responsabilidad Extracontractual"; Pino, Alberto (2016); Pizarro, Carlos (2009): "La acción de restitución por provecho de dolo ajeno", en: Estudios de Derecho Civil IV.

Se argumenta que se trata de una acción restitutoria, ya que el monto a pagar por el demandado se encuentra determinado exclusivamente por los beneficios que se ha obtenido por la comisión del dolo y no los perjuicios causados a la víctima del dolo. De hecho, la norma enfatiza el hecho que el demandado “sólo es obligado hasta concurrencia de lo que valga el provecho”. En el mismo sentido, señala Pizarro Wilson señala que no hay una real conexión entre el daño ocasionado a la víctima y la acción para el pago del provecho.

Los requisitos que se exijan según se le dé una u otra naturaleza son distintos. En este sentido, si se considera una acción indemnizatoria deberían concurrir todos los requisitos a su respecto, entre ellos concurrencia de daños y factor de imputabilidad, requisitos que no exigiría la acción restitutoria para poder dirigirse en contra del tercero enriquecido. En esta línea, Peña dispone que para el éxito de la acción es indiferente que el título mediante el cual se obtuvo el provecho indirecto sea legítimo y que no exista mala fe del demandado. Lo que buscan estos artículos es evitar el provecho indirecto que es producto del dolo y por eso basta el provecho para que la acción prospere.

En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema, que en el marco de los juicios del caso Inverlink ha expresado que los requisitos para que la acción restitutoria sea procedente son; que exista una acción dolosa, que un tercero reciba provecho de ese dolo ajeno, y que el que recibe el provecho no sea cómplice del dolo.

Considerando que la acción del provecho por dolo ajeno es restitutoria, resulta interesante analizar si sería procedente entablar la acción restitutoria y una indemnizatoria para recuperar tanto las ganancias como las pérdidas eventualmente sufridas. En efecto, así ha procedido la CORFO en el caso Inverlink, ejerciendo además acciones civiles indemnizatorias exitosamente.

Considerando que las acciones tienen objetivos distintos, una busca la restitución del provecho obtenido a través del dolo y la otra la compensación por las pérdidas o daños que el acto doloso ha producido, en teoría ambas podrían proceder. No obstante ello, algunos han constatado que en caso que exista un daño ocasionado por el dolo no debiera ser posible para la víctima obtener la restitución de las ganancias obtenidas por el tercero y a la vez obtener la indemnización de todos los perjuicios sufridos por parte del autor del daño, ya que se configuraría un doble pago. Así, se ha afirmado que la acumulación llevar a resultados injustos, proveyendo una reparación excesiva para la víctima⁸.

8.2 El caso Inverlink.

La acción por provecho del dolo ajeno prácticamente no había sido utilizada con

⁸ Momberg, Rodrigo (2015): Desempolvando el Código: la acción por provecho del dolo ajeno. En Mercurio Legal; Pino (2016).

anterioridad al caso Inverlink, considerando uno de los mayores escándalos financieros en nuestro país. En el caso, producto del descubrimiento de las comunicaciones que mantenía la secretaria del presidente del Banco Central con uno de los principales ejecutivos de Inverlink, a quien entregaba información relevante, se generó un ambiente de desconfianza que llevó a los inversionistas del grupo financiero a exigir los retiros de sus inversiones provocando un déficit de caja. Para evitar la insolvencia de la empresa ejecutivos de Inverlink obtuvieron mediante maniobras dolosas una serie de instrumentos financieros de CORFO, que luego liquidaron en el mercado y con el dinero resultante financiaron las operaciones de la empresa y pagaron los retiros de sus clientes. CORFO, como titular de los créditos que fueron fraudulentamente obtenidos y luego liquidados, accionó contra los inversionistas de Inverlink que recibieron los pagos con los instrumentos obtenidos ilícitamente, fundándose en los artículos 1458 y 2316 del Código Civil. Dada la situación de insolvencia de Inverlink en la práctica resultaba infructuoso dirigirse en su contra para recuperar el valor de los instrumentos sustraídos.

En diversos juicios que ha iniciado CORFO, la Corte Suprema ha acogido la acción del provecho por dolo ajeno estimando que los demandados, terceros inversionistas de Inverlink que no participaron en la perpetración del fraude, habían obtenido un beneficio consistente en el pago de sus créditos proveniente de dineros obtenidos mediante la sustracción dolosa de los instrumentos financieros de CORFO.⁹

9. Prueba del dolo.

Art. 1459 CC. El dolo no se presume sino en los casos especialmente previstos por la ley. En los demás debe probarse.

Ej. Son indignos para suceder al causante los que dolosamente han detenido u ocultado un testamento, presumiéndose dolo por el mero hecho de la detención u ocultación. (Art. 968 N° 5 CC).

10. Condonación del dolo.

El dolo no puede personarse o condonarse anticipadamente. La condonación del dolo futuro adolece de objeto ilícito y se sanciona con la nulidad absoluta (Art. 1465 CC).

⁹ Véase por ejemplo sentencias de 30 de septiembre de 2013, Rol N° 4871-2012 y 30 de enero de 2013, Rol N° 6302-2010.

2.4.4 LA LESIÓN

1. Conceptos generales sobre la lesión.

Lesión: perjuicio que experimenta una persona cuando ejecuta ciertos AJ, y que resulta de la desigualdad existente entre la ventaja obtenida y el sacrificio hecho para obtenerla.

En materia contractual, su campo de aplicación se restringe a los contratos onerosos conmutativos, en los casos especialmente regulados. En ellos, la lesión está constituida por la desigualdad entre las prestaciones recíprocas de las partes.

2. Naturaleza jurídica de la lesión.

A) Criterio subjetivo: Es un vicio del consentimiento. Dos posturas:

a) Es un vicio propio y específico: la desigualdad proviene del apremio moral causado por la imperiosa necesidad de dinero, que coarta la libertad de decisión. Crítica: Parece antijurídico que cualquier persona pudiera pedir la nulidad del contrato que considera desfavorable para sus intereses por la sola razón de haber consentido en él por la imperiosa necesidad de dinero.

b) Es un vicio asimilable a los demás: la desigualdad revela que la parte que se obliga a dar más de lo que recibe ha sido víctima de error, fuerza o dolo. Crítica: Si la lesión es una consecuencia del error, fuerza o dolo, no hay razones para considerarla un vicio del consentimiento.

Este criterio debe desecharse para resguardar la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídicas. La necesidad puede obligar a contratar en condiciones desfavorables, pero no por eso se pierde la voluntad de contratar; no coarta la libertad.

B) Criterio objetivo: La lesión no es un vicio del consentimiento, no tiene relación con el consentimiento de la víctima. Opera cuando el contrato revela una desigualdad de las prestaciones que supera los márgenes permisibles. El legislador debe establecer hasta qué límites tal desigualdad es tolerada.

C) Criterio mixto: Para que exista lesión, es necesario:

1. Que las prestaciones recíprocas revelen una desigualdad o falta de equivalencia que supere los límites permitidos por la ley.

2. La desproporción debe ser consecuencia de la necesidad, miseria, ligereza o inexperiencia de la víctima, que la pone en una situación desmedrada frente a una contraparte astuta o inescrupulosa.

Crítica: si la desigualdad no se funda en estas causas, no sería reprochable, por muy grande que ella sea.

3. La lesión en el CC.

Se puede afirmar que nuestro CC sigue un criterio objetivo y, por consiguiente, no debe ser considerado un vicio del consentimiento, por las siguientes razones:

- El Art. 1451 CC no la menciona como vicio del consentimiento.
- El proyecto original la incluía en el Art. 1451 CC.
- Para nuestra legislación, no constituye la lesión una causal genérica de rescisión, sino que se describen ciertos casos en los cuales existe un daño patrimonial considerado excesivo, dictando, para esos casos, normas que tienden a restablecer el equilibrio.
- Su sanción se aparta de la sanción contemplada para los vicios de la voluntad, puesto que además de la rescisión se contempla en muchos casos la rebaja.

4. Casos de lesión en nuestro CC.

- Lesión en el contrato de compraventa de bienes raíces:

La compraventa puede rescindirse por lesión enorme (Art. 1888 CC). Sólo cabe la lesión en la compraventa voluntaria de bienes raíces (Art. 1891 CC).

Lesión enorme (Art. 1889 CC):

1. Del vendedor: el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende.
2. Del comprador: el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella.

Estos son los límites tolerados; si son superados, hay lesión enorme, sin consideración a factores subjetivos, y aun cuando la víctima hubiera conocido y aceptado la lesión.

Efectos de la lesión: produce los efectos propios de la nulidad, a menos que la parte contra quien se pronuncie la rescisión se allane a respetar el justo precio, restableciendo así el equilibrio (Art. 1890 CC).

- Lesión enorme en el contrato de permuta de bienes raíces:

Al contrato de permuta se aplican todas las disposiciones relativas a la compraventa que no se opongan a la naturaleza de aquel contrato (Art. 1900 CC).

Cada permutante es considerado como vendedor de la cosa que da, y el justo precio de ella a la fecha del contrato se mira como el precio que paga por lo que recibe a cambio.

- **Lesión en la cláusula penal enorme:**

Cláusula penal: avaluación anticipada que hacen las partes de los perjuicios que deriven del retardo en el cumplimiento de una obligación, o del incumplimiento de la misma.

Cláusula penal enorme: aquella que es excesiva o desmesurada, perdiendo, en consecuencia, su carácter indemnizatorio y convirtiéndose en un lucro para el acreedor. Según el Art. 1544 CC, el límite está dado por el doble de la cantidad que se obliga a pagar el deudor en virtud del pacto principal. Todo lo que exceda de este duplo puede ser rebajado.

- **Lesión en la aceptación de una herencia:**

Esta situación se refiere al heredero que al aceptar la herencia creía que ésta tenía un determinado valor, ignorando, al tiempo de aceptarla, que existían disposiciones testamentarias del causante, en virtud de las cuales el valor de la herencia disminuye en más de la mitad. En este caso, el heredero puede pedir la rescisión de la aceptación (Art. 1234 CC).

- **Lesión en la partición de bienes:**

Si en la partición un comunero es perjudicado en más de la mitad de su cuota podrá demandar la rescisión de la partición (Art. 1348 CC).

- **Lesión en el mutuo con intereses excesivos:**

Interés convencional máximo: interés corriente aumentado en un 50%.

Se produce lesión cuando se estipula un interés superior al convencional máximo. Esta estipulación no es nula; el interés se rebaja al corriente (Art. 2206 CC y Art. 8 Ley 18.010).

- **Lesión en la anticresis:**

Anticresis: contrato real por el que se entrega al acreedor una cosa raíz para que se pague con sus frutos (Art. 2435 CC).

Los intereses que se pacten están sujetos, en caso de lesión enorme, a la misma reducción que en caso de mutuo (Art. 2443 CC).

5. Efectos de la lesión.

Su sanción no es uniforme, pues en algunas hipótesis produce la rescisión, y en otras, sin afectar la validez del acto, trae como consecuencia la rebaja de la prestación que supera los límites permitidos.

2.5 INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR VICIOS DEL CONSENTIMIENTO¹⁰

Si bien en la doctrina nacional no existe mayor desarrollo al respecto, se ha afirmado que el hecho que el legislador disponga expresamente que los vicios de la voluntad generan una acción de nulidad no obsta a que el perjudicado pueda ejercer además una acción de indemnización por los daños derivados por la declaración de dicha nulidad, ya que ambas acciones tienen distintos objetivos. Ahora, como afirma Barros, la reparación de los perjuicios que se siguen de la nulidad tiene un objeto complementario y no acumulativo respecto de las prestaciones mutuas que se deban realizar.

La doctrina ha enmarcado este tema en sede de responsabilidad precontractual, por lo que la indemnización se regiría por las normas de la responsabilidad extracontractual, debiendo cumplir sus presupuestos.

En el caso del dolo y la fuerza aparece más claramente que, por sus características y requisitos para que vicien la voluntad, en la medida en que ocasionen un daño dan derecho a la víctima para demandar su reparación. Distinto sería el caso del error, pues su existencia no determina un ilícito per sé. Así, López señala que el artículo 1455 CC establecería la *procedencia general* de la indemnización por error, ya que no se advertiría por qué el legislador consagró la pretensión indemnizatoria en el caso del error in personam y no en los demás, cuando en estos supuestos la nulidad también puede ocasionar daños al otro contratante. Conforme expone López, otros afirman que se debe distinguir la clase de error, en el error *esencial* y el error *sustancial* no procedería, pues ambos contratantes sufren equivocación, de modo que las culpas se compensan (artículo 2330). De acuerdo a otros, tratándose del error esencial y sustancial no necesariamente ambas partes incurrirán en él, caso en el cual la otra podrá, en la medida que haya ignorado el error de la primera, demandar la indemnización del daño derivado de la nulidad, toda vez que no será justo que sufra la privación de la expectativa contratada si ella no ha provocado tal error.

En cuanto al alcance de la indemnización, como ocurre en general con la responsabilidad precontractual, se ha señalado que los perjuicios indemnizables a la víctima son los sufridos en razón de la confianza en la eficacia del contrato y no los que corresponden al interés contractual que suponía el contrato válido. Así, conforme a lo señalado por Barros, la víctima no podría demandar el lucro

¹⁰ Bibliografía: Barros, Enrique (2006): Tratado de responsabilidad civil extracontractual; López, Patricia (2018): "Los supuestos y el alcance de la indemnización de daños como medio de tutela precontractual en el Código Civil chileno y su eventual confluencia con la indemnización por incumplimiento contractual" en: Revista Ius et Praxis, Año 24, Nº 1, 2018, pp. 243 – 292; Contardo, Juan Ignacio (2011): "Los criterios de interés contractual positivo y negativo en la indemnización de perjuicios derivada de resolución contractual", Revista de Derecho UCN, Año 18 - Nº 1, 2011 pp. 85-118.

cesante que se sigue del contrato nulo (porque no hay contrato que se pueda invocar como fuente de la responsabilidad), sino sólo el que resulte de no haber aprovechado una oportunidad cierta de negocios por haber confiado en la validez del contrato que resultó ser nulo. El daño emergente indemnizable corresponderá a los costos incurridos en las negociaciones y celebraciones del contrato, así como a los gastos realizados en la confianza de que el contrato era válido. Recurriendo a la distinción que ha efectuado en doctrina comparada, se afirma que la indemnización comprenderá el *interés negativo*, esto es, se busca al perjudicado en la situación en que se encontraría de no haber celebrado el contrato¹¹.

2.6 DESACUERDO ENTRE VOLUNTAD Y DECLARACIÓN.

1. Voluntad real y declaración.

El querer interno del sujeto, que constituye su voluntad real, es lo que normalmente lo impulsa a manifestar su voluntad para dar nacimiento a un AJ. Por eso, lo corriente es que la manifestación coincida con la voluntad real. Pero puede ocurrir que la manifestación no refleje exactamente la voluntad real, lo que ocurre en 2 hipótesis:

- a) El sujeto ha sido víctima de error, fuerza o dolo.
- b) La disconformidad ha sido deliberadamente buscada.

El problema es establecer cuál voluntad tiene trascendencia jurídica y prima sobre la otra: la real o la declarada.

2. Teorías sobre el rol de la voluntad en los AJ.

1) Teoría de la voluntad o dogma de la voluntad (Savigny):

La esencia del AJ es la voluntad. La declaración no es más que un instrumento para exteriorizarla. Por tanto, lo más importante es la voluntad real.

Es por ello que el intérprete tiene, como primera misión, la de indagar cuál es la voluntad real, y como segunda, la de verificar si la declaración reproduce o no esa voluntad. En caso de conflicto, prima la real sobre la declarada.

2) Teoría de la culpa in contrahendo (Ihering):

La teoría de la voluntad posibilita abusos o excesos. Ej. Declarante que culpable o dolosamente encubre su voluntad real. En ese caso, la culpa o dolo no priva al declarante de la facultad de pedir la ineficacia de la declaración, aún en desmedro de la persona a quien estaba destinada. Por ello, se agrega un elemento:

¹¹ Conforme a lo expuesto por Contardo; La indemnización de perjuicios que cubre el daño al *interés positivo* tiene por objeto colocar al acreedor en una situación similar a si se hubiese cumplido el contrato; la del *interés negativo* tiene por objeto colocar al acreedor en una posición similar a si el contrato no se hubiera celebrado.

Culpa in contrahendo: responsabilidad que adquieren las partes en los actos o comportamientos previos o preliminares al AJ.

Si una persona, culpable o dolosamente, formula una declaración que no se ajusta con su voluntad real, adquiere una responsabilidad por la invalidez o nulidad que pudiera producirse por esa causa.

El declarante garantiza que su declaración corresponde y se identifica con su voluntad; si no es así, adquiere la obligación de indemnizar perjuicios. (Windscheid)

3) Teoría de la declaración:

La teoría de la voluntad atenta contra el principio de la seguridad y estabilidad de las relaciones jurídicas.

La declaración que proviene de una persona capaz produce plenos efectos jurídicos, aunque no corresponda a la voluntad real del declarante.

4) Pensamiento de Hartmann:

Corresponde al juez, luego de analizar las circunstancias del caso, la buena o mala fe de las partes y la actitud hipotética que tendría "la persona ideal" en sus relaciones jurídicas, sentenciar lo que estime más justo y conforme a la equidad.

Conclusión:

Se critica a la teoría volitiva el hecho de que obligue a indagar por una intención psicológica, ajena al campo del Derecho. Además, deja al destinatario de la declaración en una situación desmedrada.

Se critica a la teoría de la declaración porque atribuye a las meras palabras o declaraciones los efectos jurídicos del acto. Si sólo tuviera trascendencia la declaración, debería negarse toda relevancia a los vicios de la voluntad o a la simulación. Además, deja al declarante en situación desmedrada, pues no puede eximirse de los efectos de su declaración aunque pruebe que ella no refleja su real querer por un error u otra circunstancia que no le sea imputable. La teoría de la responsabilidad es la que mejor equilibra los intereses de la partes. En el acto jurídico deben concurrir conjuntamente voluntad y declaración.

3. El problema en el CC.

El CC atribuye un rol decisivo a la voluntad real. Algunos piensan que sigue tan fielmente el dogma de la voluntad, que sólo tendría relevancia la voluntad real, apoyándose en el Art. 1560 CC, interpretado en el sentido de que la voluntad real, aún oculta, prima sobre la declaración.

Ese no es el alcance de la disposición. Es cierto que obliga al intérprete del contrato a indagar la intención de las partes, pero siempre que ésta sea "conocida", es decir, se haya manifestado por algún medio.

El CC no resuelve el caso de que una de las partes, por negligencia o dolo, formule una declaración que no corresponde a su voluntad real. Existe la opinión de que no podría sustraerse a los efectos del acto, pues la conducta dolosa o negligente no la hace merecedora de protección jurídica. Esto fluye de los fines mismos del ordenamiento jurídico.

2.7 LA SIMULACIÓN.

1. Conceptos generales.

Como ya hemos visto, el Código Civil regula expresamente las consecuencias que se derivan de desacuerdos entre la voluntad real y la declarada, cuando dicha discrepancia no es deseada por las partes. Sin embargo, el Código no estableció disposición alguna que aludiera a la disconformidad deliberadamente querida y buscada por el autor del acto o las partes de la convención. Dicha situación es lo que en doctrina se designa por medio del término 'simulación'.

Para abordar este concepto, la doctrina suele citar la definición ofrecida por Francisco Ferrara: "la declaración de un contenido de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre las partes, para producir, con fines de engaño, la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo". De la precedente definición, se desprende que la simulación se compone de los siguientes elementos:

- (1) una declaración de voluntad, cuyo contenido no es real;
- (2) emitida de forma deliberada y consciente por las partes que intervienen en el negocio jurídico;
- (3) para producir con fines de engaño la apariencia de un acto o contrato que no existe o diverso del que se suscribió realmente.

Ejemplo:

Víctor se concierta con Mario para aparentar, frente a terceros la celebración de un acto – una compraventa – cuando, en realidad, no pretenden celebrar ningún negocio. El objetivo de Víctor es perjudicar el derecho de prenda general de los acreedores disminuyendo sus bienes. Así, Víctor y Mario, conscientemente, han manifestado frente a terceros una voluntad distinta a la que efectivamente poseen.

2. Requisitos que supone toda simulación

1. Existencia de una declaración que deliberadamente no se conforma con la intención de las partes. En el ejemplo, dicha declaración corresponde al contrato de compraventa que celebran Víctor y Mario;
2. Dicha declaración ha sido concertada de común acuerdo entre las partes. Aun cuando Víctor no tiene interés en transferir los derechos que recaen sobre el bien y Mario, por su parte, tampoco está interesado en adquirirlos, ambos concurren a la suscripción del referido contrato;

3. El propósito perseguido por las partes es engañar a terceros. Víctor y Mario buscan sustraer bienes de su patrimonio, con el propósito de perjudicar el derecho de prenda general de sus acreedores.

3. Clasificación de la simulación

A) Simulación absoluta y relativa.

1. Simulación absoluta: Se produce cuando se celebra un acto jurídico que no tiene nada de real; es ficticio en su totalidad. El acto aparenta una voluntad negocial, cuando en realidad tal voluntad no existe. Ejemplo: Víctor y Mario aparecen celebrando una compraventa, cuando en realidad no han celebrado contrato alguno.

2. Simulación relativa: La diferencia que media entre la voluntad que consta en la declaración y aquella que es efectivamente vinculante entre las partes puede recaer en: (i) la identidad de los sujetos de derecho que aparecen vinculados (Víctor actúa ocultando un mandato de Juan); (ii) en la especie de acto o contrato que se ejecuta o celebra (Víctor y Mario dicen celebrar una compraventa y en realidad, mediante un instrumento privado, acuerdan celebrar un arrendamiento) o (iii) en el contenido prescriptivo del contrato (las partes declaran que el precio ha sido íntegramente pagado, cuando en realidad se pagará en cuotas).

B) Simulación lícita e ilícita.

1. Simulación lícita: Aquella en que las partes no persiguen el perjuicio de terceros. Existe el ánimo de inducir a error o de engañar a terceros, no existe, en cambio, la intención de perjudicarlos. Por ejemplo: Víctor decide simular la enajenación para sustraerse a las amenazas de Álvaro, aspirante a su herencia.

2. Simulación ilícita: A diferencia de la anterior, tiene como móvil el perjuicio de terceros o la violación de la ley. Dicho motivo es el que inspira a las partes. Por ejemplo: Víctor toma conocimiento de que el Banco realizará la acreencia de la que es titular, razón por la que decide enajenar fingidamente un inmueble de su propiedad, con el fin de burlar la ejecución.

4. Desde qué momento existe la simulación

El acuerdo simulatorio existe desde su propia suscripción. Así lo ha sostenido la doctrina más autorizada. Sin perjuicio de ello, hay autores que estiman consumada la simulación sólo una vez que las partes pretendan hacer oponible a terceros el acto simulado.

5. Simulación y reserva mental

La reserva mental puede definirse como no aceptar en el fuero interno lo que se

manifiesta como la voluntad real. También tiene el propósito de engañar. Si bien ambas se asemejan en que ambas suponen una declaración de lo que no se quiere con el propósito de engañar, podemos identificar una serie de diferencias entre ellas:

1. La reserva mental existe solo en una de las partes, el declarante; la simulación es compartida por ambas partes.
2. El propósito de la reserva mental es engañar a la contraparte; el propósito de la simulación es engañar a terceros.
3. La reserva mental no atenta contra la validez de los actos jurídicos; la simulación sí, en ciertos casos y condiciones.

6. La simulación relativa

Se advierten con nitidez en la simulación relativa dos actos jurídicos: el simulado o fingido, que es el acto declarado por las partes, y el disimulado u oculto, que es aquel que refleja la verdadera intención de las partes y que se encuentra encubierto por el primero.

Si bien esto ha llevado a cierta doctrina a sostener que en la simulación concurren dos voluntades – una de las cuales consta en el acto disimulado y la otra en el fingido – dicha conclusión debe rechazarse. Como bien lo señala Carlos Peña, en la simulación existe nada más que una sola voluntad. Desde el punto de vista de las apariencias, en la simulación relativa comparecen dos actos, mas se trata de una sola voluntad insincera puesto que entre un acto y otro existe simultaneidad intelectual. Esta unidad ideológica que caracteriza a la simulación permite caracterizarla como un modo insincero y, en principio, lícito de manifestar la voluntad.

El acto fingido puede perseguir fines ilícitos. Como bien señalábamos, si éste persigue perjudicar a terceros o infringir la ley podría estar expuesto a la sanción respectiva. Por ejemplo: el contrato disimulado que suscribieron Víctor y Mario adolece de un problema de lesión enorme en relación con el precio del bien raíz. Una vez que aparece a la luz, éste podría ser objeto de la rescisión.

Es importante señalar que la simulación no se sanciona en sí misma. Lo que puede estar afecto a sanciones es el acto disimulado. El Código Civil no contempla una sanción específica para la simulación. Tampoco la prohíbe expresamente. Por el contrario, dentro de ciertos límites, el legislador la tolera.

7. Consecuencias de la simulación

Si la simulación es absoluta, establecida, el acto simulado se desvanece, quedando, en suma, inexistente. Si es relativa, se desvanece y queda inexistente el acto simulado; no va a producir efectos porque carece de causa o tiene una causa falsa o engañosa. Queda a la vista, en cambio, el acto disimulado, que puede tener una causa lícita o ilícita y se sancionará según los vicios que en él se adviertan.

El acto disimulado no es de por sí nulo. Es importante reafirmar dicha idea. Solamente será anulable en la medida que en él se contenga un vicio que haga procedente la sanción de ineficacia respectiva. Si éste no adolece de vicios y cumple con los requisitos de existencia y validez determinados por la ley, producirá válidamente sus efectos.

8. Efectos de la simulación

Los efectos de la simulación pueden analizarse entre las partes y respecto de terceros.

A) Efectos de la simulación entre las partes.

Acorde a la doctrina nacional, en las relaciones recíprocas de las partes prevalece la voluntad real. Ello tiene sentido, considerando que entre éstas el acto simulado no existe. Retomando nuestro ejemplo: si Víctor y Mario aparecen celebrando una compraventa, cuando en realidad se ha entregado la cosa en razón de un comodato, en el caso hipotético que Víctor – quien comparece como vendedor en el contrato simulado – exigiere el pago del precio, Mario se defenderá alegando que el contrato que realmente los vincula es un comodato, razón por la que no procede pago alguno.

Es frecuente en la práctica que las partes, en forma paralela al documento en que hacen constar el contrato aparente, extiendan otro documento que deja constancia escrita de su voluntad real. A ello se le denomina contraescritura, pues contradice lo expresado en otro documento y constituye, precisamente, un medio para probar la voluntad real de los contratantes. Esta idea, implícitamente, está contenida en el artículo 1707 del Código Civil.

Artículo 1707 CC. Las escrituras privadas hechas por los contratantes para alterar lo pactado en escritura pública, no producirán efecto contra terceros. Tampoco lo producirán las contraescrituras públicas, cuando no se ha tomado razón de su contenido al margen de la escritura matriz cuyas disposiciones se alteran en la contraescritura, y del traslado en cuya virtud ha obrado el tercero.

Desde el punto de vista de su ubicación, el artículo 1707 es un precepto relativo a la prueba de las obligaciones. En particular, refiere al valor probatorio de la prueba instrumental. Este precepto regula, en efecto, el valor que cabe atribuirle a un instrumento privado enfrente de uno público, cuando entre uno y otro media oposición en relación a aquello de lo que dan cuenta. Toda vez que existan instrumentos contradictorios, el conflicto deberá ser resuelto con arreglo a lo previsto en el precitado artículo 1707.

Peña, sin embargo, va más allá de dicha interpretación. Sostiene que es una regla referida a la simulación, en tanto establece la fuerza obligatoria que cabe atribuir a los actos que constan en los instrumentos. Para aplicar el precepto, entonces, no basta que existan dos actos cuyo contenido sea inconciliable. Éste sostiene que la noción de *contraescritura* a la que alude la disposición debe entenderse en un sentido restringido – como sinónimo de contrato disimulado. Dicha posición ha sido refrendada por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Nuestro máximo tribunal distingue entre el concepto de contraescritura en sentido estricto – que es sinónimo de contrato disimulado – y en sentido amplio, subsumiendo bajo dicha categoría todo acto que tenga por objeto alterar, modificar o extinguir un contrato anterior. Así, la contraescritura es aquel instrumento que tiene por objeto hacer constar la voluntad real de las partes.

Como bien adelantábamos, conviene distinguir según si estamos ante un supuesto de simulación absoluta o relativa. Dado que en la simulación absoluta no hay voluntad alguna, los sujetos no quieren celebrar ningún acto. En este caso, el negocio jurídico puede ser dejado sin efecto mediante la acción de nulidad absoluta.

La simulación relativa es válida. Entre las partes debe primar la voluntad oculta, a la luz de lo previsto en el artículo 1560. Una vez conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Víctor y Mario, en nuestro ejemplo, están vinculados por su voluntad real. Ello se desprende, adicionalmente, a contrario sensu de lo previsto en el artículo 1707: la escritura privada no produce efectos respecto de terceros, mas sí entre las partes.

B) Efectos de la simulación respecto de terceros.

En principio, los terceros se rigen por el acto público. Estos no conocen el acuerdo simulatorio, por lo que a ellos no puede imponérseles el acto oculto. Ello se desprende de la lectura del artículo 1707: *no producirán efectos contra terceros.* Estos, sin embargo, podrán tener interés en que prevalezca la voluntad real por sobre la declarada. A este efecto, debe considerarse que la disposición en comento ha consagrado la inoponibilidad de la simulación en favor de los terceros y no en contra de ellos. En consecuencia, existiendo la posibilidad de que los terceros rechacen el intento de las partes por extender a su respecto la eficacia del acto aparente, de igual forma habría de serles reconocida la facultad de servirse de las contraescrituras a fin de invocar, en su beneficio, la real voluntad de las partes. En razón de esto podemos distinguir dos tipos de terceros:

1. Terceros que quieren prevalecerse de la voluntad real: Les perjudica la simulación y tienen interés en que se declare la voluntad real, pues quieren que al acto oculto se le apliquen las sanciones correspondientes o, bien, produzca sus efectos para ejercer las acciones que les competan. Si seguimos nuestro ejemplo, serán los acreedores de Víctor quienes estarán interesados en que el

juez declare cuál ha sido la voluntad real de las partes. De esta forma, establecida ésta y además que Víctor y Mario perseguían perjudicar a terceros, podrá solicitarse se declare la nulidad de la venta simulada. ¿Qué causal podrá fundar la demanda de los acreedores? Como bien lo señala Enrique Alcalde, es una materia discutida. En principio, siendo ilícita la simulación en razón de hallarse motivada en el fraude a terceros, estos podrían alegar la nulidad absoluta por adolecer de causa ilícita. A juicio de Alcalde, dicha solución es errada, pues ante un supuesto de simulación absoluta ilícita en realidad atendemos a un problema de falta de consentimiento, por lo que el acto público será inexistente o nulo, según la posición a la que se adscriba. Por el contrario, al aludir al supuesto de simulación relativa, Alcalde enfatiza que la simulación y la nulidad son instituciones completamente diversas entre sí. Por ello, acreditada la simulación y quedando al descubierto el acto disimulado, su nulidad solo podrá pronunciarse en el evento que la respectiva convención haya omitido alguno de los requisitos que la ley prescribe para su valor.

2. Terceros que quieren prevalecerse de la voluntad simulada: Tal como señalábamos, a ellos les interesa aprovecharse de las consecuencias favorables del acto simulado. No tienen interés en que el acto sea impugnado. Entre estos figuran los terceros de buena fe que hubieren contraído una relación jurídica con una de las partes del contrato simulado. En nuestro ejemplo: Mario, quien aparece como comprador de la venta simulada, vende la cosa objeto del contrato a Patricio, quien cree estar adquiriendo el dominio del referido bien.

¿Cómo se resuelven los conflictos que se suscitan entre estos tipos de terceros? ¿Cuáles merecen tutela jurídica? Si bien la ley no lo resuelve de forma expresa, la doctrina es unánime: las consecuencias de la simulación demandada por terceros no afecta a otros terceros de buena fe. Tales consecuencias sólo son oponibles a los terceros que sabían o debían saber, sin negligencia de su parte, que sus derechos derivaban de un título simulado.

9. Acción de simulación

Es aquella que ejercen los terceros a quienes la simulación perjudica para que el juez declare la voluntad real de las partes. Para ejercer la acción de simulación, se requieren las siguientes condiciones:

1. Solamente la puede entablar aquel tercero al contrato simulado que es titular de un derecho subjetivo o de una posición jurídica amanezada o embarazada por el contrato aparente. Dicho en otras palabras, el actor debe tener un interés jurídico.
2. El actor debe probar el daño sufrido como consecuencia de la incertidumbre ocasionada por el acto simulado, daño que determina la necesidad de invocar la tutela jurídica. Un medio de prueba frecuente lo constituyen en esta materia las presunciones que pueda deducir el juez.

Con respecto a la prescripción de la acción de simulación, la ley nada establece.

Hay autores que consideran que tal acción no se extingue por su no ejercicio; otros, en cambio, no divisan razón para aplicar a su respecto la regla general que determina la prescriptibilidad de las acciones.

Quienes defienden la imprescriptibilidad de la acción de simulación, arguyen que su ejercicio se supedita al ejercicio de la acción de nulidad. Por tanto, la acción de simulación perdería eficacia al transcurrir el plazo de prescripción para demandar la nulidad absoluta o relativa del contrato encubierto – 10 años o 4 años, respectivamente.

Esta interpretación solo resulta aplicable si la simulación es relativa. No soluciona el problema si la simulación fuera absoluta. Adicionalmente, no soluciona tampoco el problema si en el supuesto el contrato oculto es válido.

Víctor Vial defiende la prescriptibilidad de la acción de simulación acorde a las reglas generales. El plazo sería el de las acciones personales (5 años), a menos que se estimara que la acción emana de un delito civil, en cuyo caso el plazo de prescripción sería de 4 años, contados desde la fecha del contrato simulado.

CAPÍTULO 3. EL OBJETO.

3.1 GENERALIDADES.

1. Conceptos generales.

El objeto es un requisito de existencia del AJ. El Art. 1445 CC requiere que el acto o declaración recaiga en un objeto lícito.

El artículo 1460 CC define el objeto en los siguientes términos

Art. 1460 CC. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración.

Distinciones doctrinarias en torno al objeto:

1. Objeto del contrato: Derechos y obligaciones que el acto crea, modifica o extingue, es decir, lo querido por el autor o las partes.
2. Objeto de la obligación: Es la prestación.
3. Objeto de la prestación: aquello que se debe dar, hacer o no hacer.

Crítica al Art. 1460 CC. Nuestro CC se saltaría una etapa al señalar que objeto del contrato es la prestación.

2. Requisitos doctrinarios y generales del objeto.

En doctrina se dice que el objeto debe ser determinado, posible y lícito.

1. Determinado: El objeto debe determinarse al momento de la conclusión del AJ o, a lo menos, debe ser determinable (por un medio objetivo).
2. Posible: El objeto debe ser posible, tanto en el hecho como en el derecho.
Imposibilidad de hecho: imposibilidad material o física.
Imposibilidad jurídica: se debe a razones o causas jurídicas.
3. Licitud del objeto: Objeto lícito: el que no es contrario a la ley, al orden público o a las buenas costumbres. El objeto que contraviene la ley es ilegal; el que contraviene las buenas costumbres es inmoral.

3.2 EL OBJETO PARA EL CÓDIGO CIVIL

1. Requisitos que debe reunir el objeto.

Hay que distinguir:

1. El objeto es una cosa.
2. El objeto es un hecho.

Art. 1461 CC. No sólo las cosas que existen pueden ser objetos de una declaración de voluntad, sino las que se espera que existan; pero es menester que las unas y las otras sean comerciables, y que estén determinadas, a lo menos, en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es físicamente imposible el que es contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el prohibido por las leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público.

2. Requisitos que debe reunir la cosa objeto de la declaración de voluntad.

1) Cosa real:

La cosa tiene que existir al momento de la declaración de voluntad o, a lo menos, esperarse que exista (Art. 1461 CC).

La venta de cosa futura:

- Conmutativa y condicional: La condición de que la cosa llegue a existir constituye un elemento de la naturaleza del contrato (Art. 1813 CC).
 - Aleatoria y pura y simple: Cuando:
 - Las partes manifiestan expresamente que la compraventa no se entiende hecha bajo esa condición.
 - De la naturaleza del contrato aparece que lo que se compra es la suerte.
- En ambos casos, y aunque la cosa no llegue a existir, el comprador va a estar obligado a pagar el precio.

Si se vende una cosa que al tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y, en realidad, no existe, la venta no producirá efecto alguno (Art. 1814 CC). El contrato será inexistente, pues no existe la cosa objeto del mismo.

2) Cosa comerciable:

La cosa debe:

- Ser susceptible de dominio o posesión por los particulares.
- Encontrarse en el comercio humano.

- No estar excluida de él por su naturaleza, por su destinación o por la ley (Art. 1461 CC).

Cosas inmerciables (Avelino León):

- Aquellas que se encuentran excluidas del comercio humano por su propia naturaleza y en general aquellas que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas, que no son susceptibles de dominio (Art. 585 CC). Ej. Mar, aire. Esta inmerciableidad es absoluta.
- Aquellas cosas que por su destinación (y mientras la conserven) no son susceptibles de dominio por los particulares. Ej. Bienes nacionales de uso público, cuyo dominio pertenece a la Nación y su uso a todos los habitantes (Art. 589 CC).

Hay un criterio generalizado por considerar inmerciables las cosas que se excluyen del comercio por razones de orden público, o en resguardo de la moral y buenas costumbres. Ej. Cosas cuya enajenación debe hacerse cumpliendo ciertos requisitos (drogas, armas, etc.). Avelino estima que no están fuera del comercio, porque pueden ser objeto de propiedad privada o posesión.

3) Cosa determinada:

La cosa debe estar determinada, a lo menos, en cuanto a su género (Art. 1461 CC).

- Determinación específica: se individualiza determinadamente un individuo de un género también determinado.
- Determinación genérica: se indica indeterminadamente un individuo de un género determinado. En este caso, es preciso indicar la cantidad o fijar reglas que sirvan para determinarla (cantidad determinable).

3. Requisitos que debe reunir el hecho objeto de la declaración de voluntad.

1. **Hecho determinado:** La persona que se obliga tiene que saber qué hecho debe ejecutar o de qué debe abstenerse. Igualmente, el acreedor debe saber qué es lo que puede exigir al deudor.

2. Hecho física y moralmente posible:

Físicamente imposible: contrario a la naturaleza.

Moralmente imposible: prohibido por las leyes o contrario a las buenas costumbres o al orden público. (Art. 1461 inc. final CC).

4. Sanción por la falta de objeto.

El acto que carece de objeto es inexistente, lo que se desprende del Art. 1814 CC que dice que la inexistencia de la cosa vendida acarrea como consecuencia que el contrato no produzca efecto alguno.

Para los autores que no admiten la teoría de la inexistencia, la sanción sería la nulidad absoluta.

3.3 EL OBJETO ILÍCITO.

1. Conceptos generales.

Para la validez del AJ se requiere que el objeto sea lícito. Si el AJ tiene objeto, pero éste es ilícito, el acto existe, pero con un vicio que lo hace susceptible de ser invalidado.

El CC exige que el objeto sea lícito (Art. 1445 CC), pero no lo define ni dice cuándo es ilícito.

2. Discusión doctrinaria en torno al concepto de objeto ilícito.

Una de las cuestiones más controvertidas del Derecho del Acto Jurídico es definir qué debe entenderse por *objeto ilícito*, pues, a diferencia de lo que ocurre con la causa ilícita, el legislador no define qué debe entenderse por *objeto ilícito*, y sólo se limita a entregar casos concretos y reglas generales para determinar su procedencia.

En la doctrina nacional, por su parte, no existe unanimidad para determinar qué debe entenderse por *objeto ilícito*.

A continuación, expondremos las variadas opciones que al respecto se han dado por los catedráticos del Derecho Civil:

- **Tesis de Claro Solar**

Para este autor, la clave está en el artículo 1461 inciso final, que define al objeto moralmente imposible, y en el artículo 1467, que define la causa ilícita como aquella que es "*prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público*", de modo que el objeto ilícito será aquel que es **contrario a la ley, a las buenas costumbres y/o al orden público**.

Esta tesis confunde objeto ilícito con el requisito que exige que el hecho como objeto del contrato sea moralmente posible, cualidad esencial del objeto cuando recae en un hecho.

- **Tesis de Eugenio Velasco**

Para este autor, objeto ilícito sería **aquel que carece de cualquiera de los requisitos que la ley señala al objeto**, sea que consista en cosa o hecho (determinación, comerciabilidad, existencia, posibilidad física y moral). Por lo mismo, el *objeto lícito* no sería un requisito adicional a los anteriores, sino que simplemente supondría la concurrencia de todos ellos.

Esta tesis confunde directamente los requisitos de existencia del objeto con el *objeto lícito*, de modo que licitud del objeto pasa a ser un componente de la existencia del objeto con todas las consecuencias que ello acarrea.

- **Tesis de León Hurtado**

Esta tesis sostiene que el objeto ilícito es **aquel que recae sobre: (i) cosas inmerciables (art. 1464 N°1); (ii) hechos o contratos prohibidos por las leyes (art. 1466); o, (iii) hechos contrarios a las buenas costumbres o al orden público (art. 1461).**

Esta definición de objeto ilícito es descriptiva ya que comprende los moldes de los casos que más adelante se expondrán.

- **Tesis Vial del Río**

Según este autor hay *objeto ilícito* en **todo acto o contrato que recaiga sobre un hecho ilícito**, porque las cosas en sí mismas no son lícitas ni ilícitas. Por lo anterior, elimina de la tesis de León Hurtado que el objeto ilícito recaiga sobre las cosas inmerciables, pero coincide con él en que *objeto ilícito* es el que versa sobre: **(i) hechos o contratos prohibidos por las leyes; o, (ii) hechos contrarios a las buenas costumbres o al orden público.**

Nuevamente, en este caso más que de hablar de ilicitud o licitud del objeto, nos estamos refiriendo a sus requisitos de existencia.

3. Casos en que se presenta con especial relevancia la ilicitud del objeto.

1. Actos que contravienen el derecho público chileno. Art. 1462 CC.

Art. 1462 CC. Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno. Así la promesa de someterse en Chile a una jurisdicción no reconocida por las leyes chilenas, es nula por el vicio del objeto.

¿Qué pasa con la sumisión a una jurisdicción extranjera? Las jurisdicciones extranjeras sí están reconocidas por las leyes chilenas, y dicha estipulación es legítima en el ámbito del derecho internacional privado.

Asimismo, son válidos los pactos de sumisión al derecho extranjero de los contratos internacionales en que sea parte el Estado de Chile o sus organismos.

Podemos encontrar ejemplos de actos que adolecen propiamente de objeto ilícito, bajo este artículo, en el contrato de sicariato, de trata de personas o de financiamiento de actividades sediciosas.

2. Pactos sobre sucesiones futuras. Art. 1463 CC.

Art. 1463 CC. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona.

Las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario, relativas a la misma legítima o a mejoras, están sujetas a las reglas especiales contenidas en el título De las asignaciones forzosas.

- No puede celebrarse válidamente ninguna convención entre la persona que debe una legítima y el legitimario que tenga por objeto la legítima. Excepción: pacto de no disponer de la cuarta de mejoras (Art. 1204 CC).
- En lo que respecta a la cuarta de mejoras, la única convención permitida es la de no disponer de dicha cuarta. Sin embargo, pensamos que existen otras convenciones plenamente válidas: donaciones irrevocables hechas en razón de legítimas o de mejoras (Art. 1185 CC).
- Ahora bien, podríamos discutir en torno al vicio de que adolece un acto que contravenga esta norma. Por un lado, podríamos decir que adolece de objeto ilícito. Pero, por el otro, podríamos afirmar que el vicio es la falta de objeto, toda vez que podríamos interpretar la formulación “no puede ser objeto” como una cuestión existencia, no de validez.
- En cambio, son perfectamente válidas las convenciones relativas a derechos sucesorios ya existentes, por haber muerto el causante.

3. Enajenación de las cosas enumeradas en el Art. 1464.

Art. 1464 CC. Hay un objeto ilícito en la enajenación:

1º De las cosas que no están en el comercio;

2º De los derechos o privilegios que no pueden transferirse a otra persona;

3º De las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice o el acreedor consienta en ello;

4º De especies cuya propiedad se litiga, sin permiso del juez que conoce en el litigio.

a) Qué se entiende por enajenación:

a. Sentido restringido del término enajenación. Conforme a este sentido, ha de entenderse que constituyen enajenación los actos jurídicos que importan un traspaso o transferencia en la titularidad del derecho real de dominio.

b. Sentido amplio del término enajenación. Conforme a este sentido, constituye enajenación no sólo los actos jurídicos que importen el traspaso o transferencia del derecho real de dominio, sino que también todos aquellos que importen una desmembración o limitación del dominio, como la constitución de una servidumbre, una hipoteca, usufructo, etc., los que, a su vez, importan la constitución de un derecho real distinto al de dominio.

b) ¿Cuál sentido se prefiere? Como dice Carlos Peña, de aquellos dos sentidos ha de preferirse la interpretación amplia en mérito fundamentalmente de dos razones:

(i) Primero, porque tal es el sentido "natural y obvio" en que, a la luz del artículo 20, han de entenderse las palabras de la ley. Enajenación implica tanto "pasar o transferir a otro el dominio" como "desposeerse o privarse de algo"; Y,

(ii) Segundo, porque así lo entendió Bello cuando, refiriéndose al actual artículo 23, expresa "Si, por ejemplo, la ley ordenase que no pueden enajenarse los bienes raíces del pupilo sin autorización de la justicia, debería extenderse esta prohibición a la hipoteca, porque la hipoteca equivale a una enajenación condicional".

Fernando Rozas Vial, señala que el Código Civil emplea la voz enajenación en un sentido amplio en los artículos 2.387 (prenda), 2.414 (hipoteca), y en un sentido restringido en los artículos 142 (bienes familiares), 393 (guardas), 1.135 (legados), 1.749 inciso 3º y 1.754 (sociedad conyugal). También podría agregarse 1. 491. En definitiva, cada vez que se distingue enajenar y/o gravar.

c) ¿Se pueden vender las cosas a que se refiere el Art. 1464?

Se deben realizar tres distinciones: Ver anexo en página final.

- A la sola luz del 1464 Código Civil, se puede afirmar que la venta se puede realizar, ya que ésta sólo constituye un título, sin generar el efecto de trasladar el dominio (importante: señalar que la venta no constituye enajenación)
- Sin embargo, a la luz de los artículos 1464, 1810, 1466, 1682 y 10, todos del Código Civil, se puede afirmar que la venta adolecería de objeto ilícito (importante: concordar los artículos 1810, 1464 y 1466, todos del Código Civil)
- Tesis de don Eugenio Velasco Letelier: distinguir conforme a la clasificación de las normas, armando "2 grupos": el primero con los números 1 y 2 (normas prohibitivas); y el segundo con los números 3 y 4 (normas imperativas de requisitos) (importante: distinguir tipos de normas)

d) Estudio particular de los casos enumerados en el Art. 1464.

(1) Enajenación de las cosas que no están en el comercio.

Hemos dicho que dentro de los requisitos del objeto está que la cosa sea comerciable, por lo que si la cosa no está en el comercio, el acto no existe por falta de objeto.

Sin embargo, el Art. 1464 N° 1 CC señala que la enajenación de cosa in comerciable adolece de objeto ilícito, lo que supone que una cosa que está fuera del comercio puede ser objeto de enajenación, y ésta se sanciona con la nulidad absoluta.

Vial opina que la falta de este requisito del objeto hace que el acto carezca de él, lo que trae la inexistencia jurídica del acto. Problema: El legislador confundió los requisitos de existencia con los de validez.

Algunos sostienen que serían requisitos de existencia sólo que la cosa sea real y determinada; la comerciability sería requisito de validez.

La absoluta indeterminación del objeto revela que no existe una intención seria de obligarse. Los actos que recaen sobre cosas in comerciables revelan la misma falta de seriedad, pues la in comerciability impide que el acto adquiera existencia jurídica.

Si la comerciability de la cosa fuera requisito de validez, por muy in comerciable que ésta sea, podría sanearse la nulidad absoluta con el transcurso del tiempo, lo que es absurdo. Sin embargo, la letra del CC permite atribuir tal efecto.

Cosa curiosa es que los únicos actos relativos a cosas in comerciables que expresamente tienen objeto ilícito son la compraventa y la enajenación. Nada se dice de los demás, por lo que no serían casos de objeto ilícito. Tales actos son in existentes. Pero resulta extraño que, por Ej., un comodato sobre una cosa in comerciable sea in existente, y la venta sobre la misma cosa sea sólo anulable.

Se concluye, que este N° es un error y está demás.

(2) Enajenación de los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otras personas.

El Art. 1464 N° 2 CC se refiere a los derechos personalísimos: aquellos que no pueden transferirse a otras personas. Estos están dentro del comercio humano, pues son susceptibles de dominio y posesión por los particulares, pero son in alienables. Por lo tanto, esto no es una repetición del N°1. Ejemplo: derecho de uso y habitación, derecho de alimentos.

(3) Enajenación de las cosas embargadas por decreto judicial.

La cosa embargada no sólo es aquella con respecto de la cual se ha trabado embargo en un juicio ejecutivo, sino también la cosa afectada por una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos o de gravar y enajenar.

- Desde qué momento debe entenderse que una cosa se encuentra embargada:

Hay que distinguir:

- Con respecto a las partes: desde que se notifica judicialmente al deudor de la resolución que ordena el embargo o prohibición.
- Con respecto a terceros:
 - a) Bienes muebles: desde el momento que han tenido conocimiento del embargo o prohibición.
 - b) Bienes inmuebles: desde que el embargo o prohibición se inscribe en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces.
- Cuándo debe existir el embargo o prohibición para que la enajenación adolezca de objeto ilícito: Al momento de la enajenación.
- ¿Hay objeto ilícito en la enajenación forzada de una cosa embargada?
Algunos autores (Claro Solar, Avelino León) piensan que esta enajenación sería válida, pues lo que la ley prohíbe son las enajenaciones voluntarias.
Otros piensan que cualquier enajenación tiene objeto ilícito, pues el legislador no distingue. Esta interpretación es más acorde con los fines de la ley en cuanto a proteger los intereses de los acreedores.
- ¿De qué manera se podría enajenar válidamente una cosa embargada?
El Art. 1464 N°3 CC establece 2 maneras:

1. Autorización judicial: debe darla el mismo juez que decretó la prohibición o embargo, y si varios jueces lo han hecho sobre la misma cosa, deben darla todos.

2. Consentimiento del acreedor: el acreedor en cuyo beneficio se trabó el embargo puede autorizar la enajenación, renunciando a prevalerse de los beneficios del embargo. Si son varios acreedores, todos deben consentir.

Ambas formas deben ser previas a la enajenación, no puede ser posterior porque la enajenación tiene objeto ilícito, sancionable con nulidad absoluta, la que no se puede sanear por la ratificación de las partes.

(4) Enajenación de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce del litigio.

Especies cuya propiedad se litiga: cuerpos ciertos, muebles o inmuebles, cuyo dominio se discute en juicio.

No hay que confundir la enajenación de una especie cuya propiedad se litiga con la enajenación de un derecho litigioso; esta última es válida. En la primera, el objeto es la cosa misma. En la segunda, el objeto es el evento incierto de la litis; en el fondo, lo que se cede es la suerte, la posibilidad de que se gane o pierda.

El Art. 296 CPC agrega un requisito para que la enajenación en cuestión tenga objeto ilícito: el juez debe decretar prohibición sobre los objetos.

- Si esta prohibición recae sobre inmueble, debe inscribirse en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del CBR, pues sin esta inscripción, no produce efectos respecto de terceros (Art. 297 CPC).
- Si recae sobre mueble, no se requiere inscripción; producirá efectos respecto de terceros que tengan conocimiento al tiempo de la enajenación.

El CC nada dice respecto a una posible autorización de la parte en cuyo beneficio se ha dictado la prohibición, lo que induce a pensar que esa autorización sería irrelevante. Pero se sostiene que los requisitos agregados por el CPC permiten equiparar la enajenación de una especie litigiosa con la de una cosa embargada, pudiendo en ambos casos autorizar la enajenación la parte en cuyo beneficio se decretó la prohibición.

4. Condonación del dolo futuro. Art. 1465 CC.

Art. 1465 CC. El pacto de no pedir más en razón de una cuenta aprobada, no vale en cuanto al dolo contenido en ella, si no se ha condonado expresamente. La condonación del dolo futuro no vale.

La condonación del dolo futuro no vale, pues, de lo contrario, se estaría aceptando anticipadamente que una de las partes actúe con dolo, lo que evidentemente es inmoral. El dolo puede condonarse por la persona que fue víctima de él, pero sólo una vez que lo ha conocido, debiendo formularse la consolución por declaración explícita. (Art. 1465 CC)

5. Deudas contraídas en juegos de azar. Art. 1466 CC.

Art. 1466 CC. Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juego de azar, en la venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente, de láminas, pinturas y estatuas obscenas, y de impresos condenados como abusivos de la libertad de la prensa; y generalmente en todo contrato prohibido por las leyes.

Según el Art. 1466 CC, tienen objeto ilícito.

El juego y la apuesta pueden ser lícitos o ilícitos (Art. 2259 CC):

1. Ilícitos: juegos de azar.

2. Lícitos:

a) Juegos en que predomina la fuerza o destreza corporal, siempre que no contravengan leyes y reglamentos de policía. Estos generan obligaciones civiles perfectas, es decir, el que gana tiene acción para exigir el pago. (Art. 2263 CC)

b) Juegos en que predomina la destreza o habilidad intelectual. Estos no otorgan acción, pero si el que pierde paga, no puede repetir lo pagado, a menos que se haya ganado con dolo. (Art. 2260 CC)

Por excepción, la ley permite ciertos juegos de azar. Sin embargo, algunos piensan que ese permiso legal impide solamente que se apliquen a los jugadores sanciones penales.

6. Venta de libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente o de objetos considerados inmorales (láminas, pinturas y estatuas obscenas). Art. 1466 CC.

Se refiere a libros cuya circulación es prohibida por autoridad competente, láminas, pinturas y estatuas obscenas, e impresos abusivos de la libertad de prensa. (Art. 1466 CC).

7. Actos prohibidos por la ley. Art. 1466 CC.

Regla general: hay objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes (Art. 1466 CC).

CAPÍTULO 4. LA CAUSA.

4.1 GENERALIDADES.

Todo acto o contrato requiere como elemento esencial para su existencia jurídica no solo la manifestación de voluntad y un objeto, sino que también una causa, y que requiere para la validez de este que dicha causa sea lícita. Dicho instituto, sin embargo, ha suscitado un gran número de controversias doctrinarias y jurisprudenciales. La razón que explica esta dificultad que presenta la causa para la dogmática es el hecho de que admite diversas y variadas acepciones. Así, Carlos Peña identifica las siguientes:

1. Causa eficiente: El elemento generador del efecto. Aquello que da vida a lo que antes no existía. Los efectos jurídicos hallan su causa eficiente en las fuentes de las obligaciones. Así, la obligación del vendedor tiene su causa eficiente en el contrato de compraventa.
2. Causa final: Es el fin inmediato o invariable de un acto, o sea, el fin próximo que determina la voluntad a obrar, que siempre es posible encontrar en la estructura misma del contrato y que es siempre idéntica para todos los actos pertenecientes a la misma especie. Así, en el contrato de compraventa, la causa del comprador es incorporar a su patrimonio una cosa; la del vendedor procurarse dinero a cambio de las cosas que entrega.
3. Causa ocasional: Está constituida por el fin lejano y variable de un acto y es de carácter estrictamente personal y psicológico. Es diferente para cada individuo. Corresponde a la razón que lo impulsa a celebrar un acto o contrato en determinadas circunstancias. Por ejemplo, la causa ocasional para el vendedor puede ser la necesidad de dinero; para el comprador, la necesidad de hacer un regalo.

Debido a lo anterior, la doctrina contemporánea ha denunciado la imposibilidad de saber con precisión qué es aquello que se denota por medio de la voz causa. Ello, sumado a otras dificultades, explica el declive histórico que ha experimentado este instituto, tal como se verá a continuación.

4.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA NOCIÓN DE CAUSA

La teoría de la causa encuentra su origen en el pensamiento de los canonistas medievales, quienes estiman que para que una convención engendre obligaciones no es suficiente el consentimiento de las partes, sino que es menester, además, que dicha convención encuentre su razón de ser en un motivo lícito y moral.

La doctrina tradicional o clásica – imperante al momento de la redacción del Código Civil chileno – se construye en base a los aportes de los juristas franceses

Jean Domat y Louis Pothier. El objeto de esta teoría se centra en identificar la causa que precede a las obligaciones que nacen del contrato o, dicho de otra forma, el fundamento a la obligatoriedad del vínculo contractual. La respuesta viene dada, precisamente, por la causa de la obligación. Así, la doctrina clásica agrupa todos los contratos en tres categorías:

1. Contratos bilaterales o sinalagmáticos: Ambas partes resultan obligadas recíprocamente. De esta forma la causa de la obligación de una de las partes es la obligación correlativa de la otra parte. En esta categoría se incorporan la compraventa, el arrendamiento, el mandato, la permuta, etc.
2. Contratos reales: Son aquellos que se perfeccionan por medio de la entrega de la cosa. La causa de la obligación de restituir la cosa que contrae la parte obligada es la entrega que de la misma se le hizo por la parte en virtud de un título que obligaba a su restitución. En esta categoría hallamos: el mutuo, el comodato, el depósito, la prenda, etc.
3. Contratos gratuitos: Aquellos que se celebran en consideración a la utilidad o beneficio de una sola de las partes, contrayendo la otra un gravamen. De acuerdo a Domat, la causa corresponde al motivo racional y justo en el que se funda la obligación. Pothier modifica con posterioridad esta idea y sostiene que la causa de los contratos gratuitos es el propósito de hacer una liberalidad. Figura en este listado, fundamentalmente, la donación.

Esta teoría ha sido objeto de duras críticas. Marcel Planiol, jurista francés, denuncia la falsedad e inutilidad de los postulados de la doctrina clásica. Así, la reacción de Planiol y la doctrina anticausalista puede sintetizarse de la siguiente forma:

1. En los contratos bilaterales, las obligaciones nacen al mismo tiempo. No podría entonces una ser la causa de la otra. Además, la supuesta falta de causa de una obligación en realidad sería un problema de falta de objeto.
2. En los contratos reales, la entrega de la cosa no es la causa de la obligación, sino un requisito de perfeccionamiento del vínculo contractual. De esta forma, si se omite la entrega, el contrato no produce efecto alguno, mas no por carecer de causa, sino por carecer de un requisito de la esencia.
3. Contratos gratuitos: La causa se confunde con los motivos. Es imposible distinguir ambos elementos. Así, la ausencia de estos motivos se traduciría, en realidad, en la ausencia de consentimiento.
4. Los problemas de ilicitud de la causa en la práctica se confunden con los de objeto ilícito.

El diagnóstico sobre la inutilidad de la causa se agudizó en la actualidad. El influjo del derecho anglosajón en materia de contratos, con la consiguiente inexistencia de este instituto en los modernos instrumentos de contratación internacional, ha propiciado que los ordenamientos jurídicos eliminen el requisito

de la causa en la legislación civil. Así se vio en la reciente reforma al Código Civil francés (2016), donde este instituto fue fundido con el objeto, dando lugar a un instituto novedoso: el *contenido* del contrato. Esta decisión respondió al carácter vago e incomprensible de la institución. Ahora, como bien lo destaca Rodrigo Momberg, la exclusión de la causa es más bien formal, pues las principales funciones de este instituto subsisten, toda vez que se establece de forma expresa que los contratantes no pueden transgredir el límite del orden público, ni en su contenido ni en su finalidad.

Además del desarrollo que ha tenido este instituto en Francia, podemos destacar otros desarrollos doctrinales relevantes: i) la doctrina italiana, la cual identifica la causa como la función económico-social que caracteriza al tipo de negocio; y ii) la doctrina del móvil, que reconoce el concepto de causa como uno puramente subjetivo, dada la imposibilidad de formular un concepto abstracto de causa según el acto o contrato de que se trate.

4.3. LA TEORÍA DE LA CAUSA EN EL CÓDIGO CIVIL CHILENO

Se refieren a la causa los artículos 1445 y 1467 del Código Civil.

Art. 1445 CC. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: 1º que sea legalmente capaz; 2º que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio; 3º que recaiga sobre un objeto lícito; 4º que tenga una causa lícita".

Art. 1467 CC No puede haber obligación sin una causa real y lícita; pero no es necesario expresarla. La pura liberalidad o beneficencia es causa suficiente. Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato y por causa ilícita la prohibida por ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público. Así, la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe, carece de causa; y la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho criminal, tiene una causa inmoral.

Establecidos los diversos conceptos de causa corresponde abocarse a determinar cuál de ellos es el que exige nuestro Código en los artículos 1445 y 1467. Por otro lado, sea cual sea la tesis que al respecto se tenga, objetivamente la legislación civil patrimonial exige la existencia de una causa real y lícita, de modo que necesariamente es un elemento estructural del negocio en conjunto con la voluntad y el objeto.

Las preguntas a las que se aboca la doctrina al analizar cómo se regula la causa en el Código Civil son las siguientes:

A) ¿Qué es lo que debe tener causa? ¿El acto o contrato o la obligación?

Argumentos de quienes sostienen que la obligación y no el acto del cual ésta emana requiere causa:

- Es el sentido del artículo 1445 CC ("para que una persona se obligue a otra") y del inciso primero del artículo 1467 CC ("no puede haber obligación sin una causa");
- El Código Civil se dictó en pleno auge de la doctrina clásica.

Argumentos de quienes sostienen que el acto o contrato debe tener una causa:

- El artículo 1445 CC está exigiendo, en realidad, una causa lícita para el acto que engendra la obligación ("para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad...");
- Esto se corrobora al constatar el contenido del inciso segundo del artículo 1467 CC ("causa es el motivo que induce al acto o contrato").
- El artículo 2057 CC se refiere a las sociedades nulas por ilicitud del objeto o la causa, es decir, es el contrato el que tiene causa ilícita.

B) ¿Qué criterio adopta el Código en materia de causa? ¿Uno objetivo u otro subjetivo?

Argumentos de quienes sostienen que el Código sigue el criterio objetivo de la doctrina tradicional:

- Argumento histórico: la doctrina clásica o tradicional era la que imperaba en la época de dictación del Código Civil. Asimismo, el Código Civil francés, que sirve de modelo al nuestro, sigue constantemente los postulados de Domat y de Pothier, sin apartarse de ellos en materia de causa.
- Si el artículo 1467 requiere una causa real y lícita, es porque pueden existir obligaciones que no tengan causa. Este hecho revela que el Código sigue la teoría clásica, pues según ella es posible que falte la causa de la obligación.
- Los ejemplos que coloca el Código en el inciso final del artículo 1467. En efecto, el hecho de que la promesa de dar algo en pago de una deuda que no existe carece de causa resulta de la aplicación de la teoría clásica, toda vez que la obligación que contrajo el prometiende no tiene como causa la obligación de la otra parte, o la entrega de una cosa que hubiera engendrado la obligación de restituirla, ni menos la intención liberal, porque el prometiende se obligó en la errada creencia que debía algo.
- Cuando el legislador define la causa como el motivo que induce a la celebración del acto o contrato, omitió que dicho motivo era abstracto – correspondiéndose así con los postulados de la doctrina clásica.

Se reconoce que no existe unanimidad en la doctrina nacional para precisar cuál es la causa de que trata nuestro Código Civil. En todo caso la posición dominante, y que ha sido ratificada por la jurisprudencia, indicaría que el análisis de la causa debe estar dividido en 2 etapas diversas.

La primera etapa es precisar si la causa existe o no en el negocio jurídico, es decir, es una cuestión de existencia de la causa – que la causa sea real en los términos del artículo 1467 inciso primero, para lo cual, se aplica el concepto de

la causa final (causa de la obligación).

Definido lo anterior, se procede a la segunda etapa de examen del negocio, esto es, la cuestión de la licitud de la causa del negocio bajo sospecha. Para este proceso, se recurre al concepto de causa móvil o motivo ocasional ante expuesta (causa del contrato). Por lo tanto, el análisis de licitud, se realiza por el Juez a la causa del contrato, entendida como causa motivo.

4.4 EL ROL JURÍDICO DE LA CAUSA

Ramón Domínguez sostiene que la causa desempeña un doble rol en el Código Civil. Por una parte, el instituto de la causa constituye un mecanismo destinado a proteger la voluntad negocial. En general, no es posible en el derecho chileno considerar el elemento de la voluntad desligado de la causa. Excepcionalmente, existen negocios jurídicos en que el derecho atiende exclusivamente a la voluntad y no a la causa. Tales son los llamados negocios jurídicos abstractos.

Por otro lado, la causa sirve para controlar el fin del negocio jurídico, de forma que este no atente contra el orden público, la ley y las buenas costumbres. De esta forma, se sostiene que la causa permite que el acto jurídico constituya una regulación de intereses que la ley permite que queden bajo la tuición privada, de los cuales se excluyen, desde luego, motivaciones e intereses ilícitos y contrarios a las normas esenciales para convivencia social.

Ambos roles resultan de la ley misma, pues el N° 1 del artículo 1445 exige que la declaración de voluntad tenga una causa, con lo cual une estrechamente la voluntad a su causa y pide además que esa causa sea lícita, con lo que quiere manifestar que también el derecho entrega al juez el control de la causa del negocio. El artículo 1467, de la misma manera, dice que no puede existir obligación sin causa real y lícita.

A) Negocios abstractos

En términos generales, se entiende por negocio abstracto aquel en que se separan los efectos y la voluntad de su causa, de forma que el fundamento de la prestación no condiciona su validez. Se separa o independiza el negocio de su causa. Por ello mismo se prescinde de esta en tales negocios. No es que no tengan causa; esta no es considerada por el derecho para efectos de su validez. La validez del negocio está fundada en la pura voluntad, de modo que la inexistencia de la causa no acarrea una sanción jurídica. Desde un punto de vista general, puede afirmarse que la utilidad del negocio abstracto se da principalmente en materia de títulos de crédito, a los que hace especial referencia el derecho comercial.

B) La causa debe ser real

El derecho no cautela cualquier emisión de voluntad, sino a aquella destinada a cumplir un determinado rol. Por ello, el negocio celebrado sin una causa que

motive la emisión de voluntad no tiene existencia. Así, tampoco la tiene el negocio en que hay error sobre la causa, pues en tal hipótesis la causa no es la supuesta por quien emitió la declaración de voluntad, de manera que en ese acto no hay una causa verdadera.

A juicio de Ramón Domínguez, faltará la causa en los negocios onerosos si no hay verdaderamente reciprocidad en las prestaciones, o en los gratuitos si no existe el ánimo de liberalidad. Especial atención merecen los negocios simulados, pues en estos casos se presenta una cierta causa sin ser ella verdadera. Esta simulación, por cierto, puede ser tanto absoluta como relativa. En el primer caso, se ha celebrado un negocio con una cierta causa, cuando en realidad no existe causa alguna, por lo cual no habrá tampoco negocio jurídico. La segunda se presenta en casos en que hay una apariencia de negocio bajo una cierta causa, aunque en realidad la causa es distinta de la que se muestra. En este caso, se ha fingido una causa ocultándose la causa real.

Si bien de la lectura del artículo 1467 se desprende que la causa se presume – ‘no es necesario expresarla’ reza el legislador – la jurisprudencia ha fallado que ella debe de algún modo desprenderse del contrato, pues en caso contrario hay nulidad. Así sucede, por ejemplo, en una dación en pago en la que no aparezca la obligación que se extingue.

C) La causa debe ser lícita

Para controlar el fin del negocio, se exige la licitud de la causa. Está es ilícita, acorde al referido artículo 1467 cuando es prohibida por la ley o contraria a las buenas costumbres o al orden público. El Código lo ilustra por medio del ejemplo de la promesa de dar algo en recompensa de un crimen o de un hecho inmoral.

La ilicitud es una noción variable. Se ha resuelto que ha de entenderse que la causa es lícita, a menos que se acredite la ilicitud. Así, el legislador y el juez deberán considerar la época en que se celebra el contrato, el medio y sus conceptos morales.

Como ejemplo de un contrato que adolece de causa ilícita, podríamos señalar aquel contrato de compraventa que tiene por objeto una gran cantidad de armas, celebrado con la finalidad de equipar a cierto número de individuos para pretender derribar al gobierno mediante un golpe de fuerza. Aquí, la motivación de los compradores es abiertamente contraria al orden público, por lo que, adolece en relación con el artículo 1467 ya citado de causa ilícita.

A modo de ejemplo, la jurisprudencia de nuestros tribunales ha entendido que hay causa ilícita en los negocios que los mandatarios, en el ejercicio de las facultades conferidas por el mandato, reporten beneficio a ellos en vez de redundar en favor de los mandantes. También se declaró nulo por ilicitud de la causa el contrato celebrado entre el deudor ejecutado y un tercero para alterar el verdadero precio de la subasta del bien embargado, por medio de maniobras

extrañas, perjudiciales para el acreedor ejecutante. Así mismo, se sostuvo que había causa ilícita en el contrato de compraventa que tuviere por objeto traspasar los bienes de una sociedad conyugal a terceras personas, colocando a los llamados a suceder al cónyuge difunto en la imposibilidad de reclamar sus derechos hereditarios.

Como se aprecia, en la jurisprudencia nacional, para evaluar la licitud de la causa se atiende a la intención jurídica que motivó a la persona a ejecutar el acto o celebrar el contrato.

4.5 EL ACTO EN FRAUDE A LA LEY.

1. Conceptos generales

Se define el fraude a la ley como todo aquel procedimiento en sí lícito, o en aquellas maniobras jurídicas a veces ingeniosas, que tienen la apariencia de legalidad y que, sin embargo, permiten realizar lo que la ley prohíbe o no hacer lo que la ley ordena.

Ejemplo:

Juan, quien es consciente de la inminencia de la interdicción por disipación, enajena la totalidad de sus bienes. La ley no quiere que Juan pueda administrar libremente sus bienes, pues su actuar revela una falta total de prudencia. Sin embargo, la prohibición no se ha configurado; las acciones de Juan son previas al decreto de interdicción y a la designación del curador.

Como puede observarse en el ejemplo, en los actos en fraude a la ley existe un aparente respeto a la norma, pues no se le infringe abiertamente. Sin embargo, se elude su aplicación en cuanto se realiza un resultado final contrario al que tutela el ordenamiento jurídico. He aquí la mayor diferencia que presenta este instituto respecto de la simulación: aquí, por medio de una serie de negocios y actos, se alcanza un resultado análogo al del negocio prohibido; en la simulación, por el contrario, se encubre la existencia del acto contrario a la ley tras la apariencia de un negocio jurídico en sí mismo lícito.

2. Elementos del fraude a la ley

- A. Elemento material u objetivo: el resultado que la ley no quiere. Dicho elemento se encuentra constituido por la similitud o equivalencia práctica del resultado que persigue el acto jurídico en fraude a la ley con el resultado prohibido por la norma.
- B. Elemento intencional o subjetivo: la intención de defraudar o burlar la ley. Significa que el sujeto realiza el acto con el propósito de burlar la norma y obtener con su realización el resultado que ésta no quiere. Este propósito se denomina *ánimo fraudatorio*.

Se discute si ambos elementos deben necesariamente coexistir para configurarse una hipótesis de fraude a la ley. Para un sector de la doctrina, el elemento intencional no sería de la esencia del fraude a la ley. A juicio de este sector, se dan casos en que no existe dicha intención. Así, bastaría con la sola oposición a la ley para que el negocio referido sea nulo, aun cuando el autor haya creído obedecer un precepto moral o jurídico.

Por el contrario, quienes consideran que el elemento subjetivo es de la esencia, vinculan el fraude a la ley con la causa. De esta forma, en el acto en fraude a la ley existe una causa ilícita: la intención fraudulenta.

3. Sanción del fraude a la ley

En el acto en fraude a la ley o en el complejo de actos jurídicos que configuran un procedimiento en fraude a la ley, la ilicitud no se encuentra en el acto mismo – no infringe abiertamente la ley. El problema radica en los motivos que se persiguen por medio de la celebración del referido acto o la realización del procedimiento. Doctrinariamente hay coincidencia en que el fraude a la ley se sanciona con la nulidad absoluta del acto o complejo de actos fraudulentos. Dicha nulidad es consecuencia de que tales actos se equiparan a los actos contrarios a la ley, hipótesis de causa ilícita acorde al artículo

CAPÍTULO 5. LAS FORMALIDADES

5.1 CONCEPTOS GENERALES.

Formalidades:

(1) Requisitos (2) que dicen relación con la forma o aspecto externo del AJ, (3) requeridos por la ley con objetivos diversos (4) y cuya omisión se sanciona en la forma prevista por el legislador.

5.2 CLASIFICACIÓN DE LAS FORMALIDADES.

Según sus objetivos, se clasifican en:

1. FORMALIDADES PROPIAMENTE TALES O SOLEMNIDADES.

a) Solemnidades requeridas para la existencia del AJ:

Concepto: Son los requisitos externos que exige la ley para la celebración de ciertos AJ, pasando a ser la solemnidad el único medio a través del cual el autor o las partes pueden manifestar su voluntad.

- Constituyen un requisito esencial para la existencia del AJ.
- Algunos plantean que no constituyen, en verdad, un requisito de existencia independiente de la voluntad, ya que la solemnidad es la manera de manifestarla.
- Lo normal es que los AJ sean consensuales. Por excepción, hay algunos actos solemnes, siendo la solemnidad un requisito de existencia.
- Las solemnidades no se presumen: sólo existen en virtud de texto expreso de la ley. Sin embargo, los particulares pueden hacer solemne un acto meramente consensual. Art. 1802 CC sobre la compraventa).

Ejemplo: Compraventa de las cosas enumeradas en el Art. 1801 inc. 2º CC. (Bienes raíces, servidumbres, censos, sucesión hereditaria), promesa de contrato debe constar por escrito, matrimonio.

Sanción: La omisión de la solemnidad impide que el acto exista, pues no hay voluntad.

b) Solemnidades requeridas para la validez de los AJ:

Concepto: En ciertos casos la ley exige la solemnidad como requisito de validez de los AJ; sin que constituya la solemnidad el único medio a través del cual se debe manifestar la voluntad.

Ejemplo: Presencia de testigos para el testamento, insinuación ante juez competente de las donaciones de más de 2 centavos.

Sanción: Si se omite la solemnidad requerida para la validez del acto en consideración a su naturaleza o especie, el acto existe, pero con un vicio que hace posible la declaración de nulidad absoluta.

2. FORMALIDADES HABILITANTES.

Concepto: Son los requisitos exigidos por la ley para completar la voluntad de un incapaz, o para protegerlo. Consiste, por lo general, en la autorización de una persona determinada.

Ejemplo:

- Art. 253 CC (autorización del padre, madre o curador para actos del hijo),
- Art. 255 CC (autorización judicial para enajenar o hipotecar bienes raíces del hijo).
- En este sentido, están sujetas a formalidades habilitantes, entre otras, las siguientes personas:
 - ✓ Incapaces relativos.
 - ✓ Representantes legales.
 - ✓ Marido.

Clases de formalidades habilitantes:

- ✓ Autorización: Permiso del representante legal o del juez. Podría incluirse también la pública subasta (véanse artículo 254 del C.c. y artículos 393 y 394 del C.c.).
- ✓ Asistencia: Intervención en el acto jurídico (véanse artículos 413 y 1.754 del C.C.).
- ✓ Homologación: Aprobación judicial de un acto jurídico ya celebrado (véase artículo 400 del C.c.).

Sanción: Acarrea, por regla general, la nulidad relativa, porque se omite una formalidad requerida para el valor del acto en consideración a la calidad o estado de las personas (Art. 1682 CC).

3. FORMALIDADES POR VÍA DE PRUEBA.

Concepto: Son aquellas en que la ley, para los fines de prueba de un acto no solemne, requiere un documento, de modo que sin él, aun cuando el acto es plenamente válido, no puede probarse por testigos.

Ejemplo:

- Art. 1709 CC. "*Deberán constar por escrito los AJ que contienen la entrega o promesa de entrega de una cosa que valga más de 2 UT*".
- Art. 2.217 del C.C.,
- Art. 14 de la Ley Nº18.010,
- Art. 20 de la Ley Nº18.101 sobre arrendamiento de predios urbanos.

Clasificación de las formalidades por vía de prueba:

a) Aquellas que prohíben la utilización de un medio de prueba determinado (Negativas) Ejemplo: art. 1709 excluye la prueba de testigos.

b) Aquellas en que el legislador impide la utilización de todos los medios de pruebas, salvo la documental propia de que consta la formalidad (Positivas). Ejemplo: Art. 14 ley 18010. La estipulación de intereses o la exoneración de su pago debe constar por escrito.

c) Aquellas que provocan la alteración de la carga de la prueba. Ejemplo: art. 20 Ley 18801. En los contratos de arrendamiento de predios urbanos si la renta no consta por escrito se presumirá que es la que diga el arrendatario.

Sanción: No afecta ni a la existencia ni a la validez del AJ. La sanción dependerá del tipo de formalidad infringida. Se podrían excluir ciertos medios de prueba, prohibir un cierto medio de prueba en particular, o alterar la carga de la prueba.

4. FORMAS O MEDIDAS DE PUBLICIDAD.

Concepto: Tienen por objeto proteger a los terceros que pueden verse alcanzados por los efectos del AJ. Por eso, la ley exige la inscripción del acto en un registro público, su publicación en un periódico, etc.

Clases de formas o medidas de publicidad:

1. De simple noticia.

Concepto: tienen por objeto poner en conocimiento de terceros las relaciones jurídicas de otras personas en que pueden tener interés.

Ejemplo: Publicación en el periódico de los decretos de interdicción (Arts. 447 y 461 CC).

Sanción: da derecho a la persona perjudicada a demandar la indemnización, pues el responsable ha cometido un delito o cuasidelito civil.

2. Sustanciales:

Concepto: tienen por objeto precaver a los terceros interesados (aquellos que están o estarán en relaciones jurídicas con las partes) de los actos que éstas celebren.

Ejemplo: Notificación al deudor de la cesión de un crédito (Art. 1902 CC).

Sanción: acarrea la inoponibilidad (ineficacia con respecto a terceros) del derecho que ha nacido como consecuencia del AJ.

CAPÍTULO 6. EFECTOS DE LOS ACTOS JURÍDICOS

6.1 CONCEPTOS GENERALES.

Para la doctrina italiana, el fin perseguido por el autor o las partes de un AJ, al menos en forma inmediata, es un fin práctico, de contenido socioeconómico. Existe una estrecha relación entre el fin perseguido por el autor o las partes de un AJ y los efectos que la ley asigna al mismo. Si el fin es merecedor de tutela, el ordenamiento crea una figura típica a través de la cual se puede lograr la satisfacción de la necesidad del sujeto, y determina los efectos que producirá el tipo creado, teniendo presente qué es lo que el sujeto persigue con él. Los efectos del AJ, entonces, son la visión que tiene el legislador del fin práctico. Es la conversión de éste a un fin jurídico.

6.2 CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS AJ.

1. Esenciales: Son aquellos que determina la ley y que se producen como obligada consecuencia de su celebración, de modo tal que las partes no pueden descartarlos ni sustraerse a ellos. Ej. Obligación del comprador de pagar el precio.
2. No esenciales o naturales: Son aquellos que estando establecidos por la ley (que interpreta, al establecerlos, una presunta voluntad del autor o las partes), pueden ser eliminados, siendo posible sustraerse a su aplicación, sin que su omisión afecte a la existencia o validez del AJ. Ej. Obligación de saneamiento.
3. Efectos accidentales: Son aquellos que las partes pueden, en virtud de la autonomía privada, incorporar a los AJ. No están previstos por el legislador en el acto tipificado, ni prohíbe su incorporación.

6.3 OTRA CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS AJ.

1. Directos: Son aquellos que surgen como consecuencia inmediata y directa de la celebración del AJ. Ej. Obligación del comprador de pagar el precio.
2. Indirectos: Son aquellos que no surgen como consecuencia inmediata y directa de la celebración de un AJ, sino que resultan de ciertas relaciones o situaciones jurídicas que son producto, a su vez, de un AJ. Ej. Obligación de alimentos de los cónyuges.

6.4 PERSONAS CON RESPECTO DE LAS CUALES SE PRODUCEN LOS EFECTOS DE LOS AJ.

1. Efectos de los AJ entre las partes.

La regla general limita la producción de efectos a las partes que celebraron el acto. Por eso es lógico que puedan determinar el contenido y alcance del AJ, sustituirlo por otro o dejarlo sin efecto.

La revocación de un AJ requiere:

1. Emanar del autor o las partes.
2. Cumplir con las mismas formalidades y requisitos del AJ que se revoca.

2. Efectos de los AJ respecto de terceros.

Excepcionalmente, el AJ puede producir efectos respecto de terceros. Se distingue:

1) AJ unilaterales: Cuando el AJ está destinado a crear, modificar o extinguir una relación jurídica, sus efectos no pueden, por regla general, radicarse exclusivamente en la persona del autor, siendo necesario que alcancen a terceros. Se crea así una relación entre el autor y el destinatario de los efectos.

2) AJ bilaterales:

- **Estipulación en favor de otro (Art. 1449 CC):** son partes el estipulante y el obligado, sin que tenga la calidad de tal el tercero beneficiado que está llamado a tomar la calidad de acreedor. Sí es realmente una excepción al efecto relativo de los actos.

- **Promesa de hecho ajeno (Art. 1450 CC):** son partes el prometiende del hecho ajeno y el beneficiario, sin que tenga calidad de tal el tercero que está llamado a tomar la calidad de deudor. No es realmente una excepción al efecto relativo de los actos porque mientras no medie ratificación del tercero, el acto le es inoponible.

- **Novación entre el acreedor y uno de los deudores solidarios (Art. 1645 CC):** libera a los codeudores que no han sido parte de la novación.

6.5 TERCEROS A QUIENES PUEDEN AFECTAR LOS AJ.

1. Terceros absolutos: aquellos para quienes el AJ es indiferente, no los afecta.

2. Terceros relativos: aquellos para quienes el AJ presenta un indudable interés o relevancia por el beneficio o gravamen que pudiera ocasionar para ellos. Son terceros relativos:

i. Los herederos, sucesores o causahabientes a título universal: En estricto rigor, son terceros en relación con los AJ que realizó el causante, pero como consecuencia de dichos actos, pueden beneficiarse o perjudicarse, aunque el beneficio o perjuicio sólo se hace presente una vez producida la apertura de la sucesión, tomando en este momento la calidad de parte.

Sin embargo, los herederos representan al causante y son los continuadores de su personalidad, por lo que no cabe, jurídicamente, atribuirles la calidad de terceros. Ellos asumen jurídicamente la calidad de parte en los actos o contratos que celebró el causante.

ii. Los sucesores o causahabientes a título singular: Se van a ver afectados por los actos o contratos realizados por su antecesor y que tengan por objeto la cosa o relación jurídica determinada adquirida de él.

iii. Los acreedores de las partes: Los acreedores de las partes, pese a su clara calidad de terceros, pueden quedar afectados por los actos que éstas realicen.

CAPÍTULO 7. INEFICACIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS.

7.1 CONCEPTOS GENERALES.

No existe el principio general de que toda disconformidad del acto con el ordenamiento jurídico se sanciona con la ineficacia de aquel.

Cuando el ordenamiento reacciona en contra del acto y no en contra de la persona o personas que lo celebraron, lo sanciona con la ineficacia.

El AJ es ineficaz cuando no produce efecto alguno o cuando sus efectos se producen de modo efímero o caduco.

La ineficacia es la reacción del ordenamiento jurídico que incide sobre la producción de los efectos del acto, eliminándolos o reduciéndolos.

En este mismo sentido señala Díez-Picazo: *"La idea de ineficacia del contrato representa la contrapartida de eficacia. Así como al hablar de la eficacia aludíamos a la producción de unas determinadas consecuencias, a la creación de un deber de observancia del contrato y de una vinculación a lo establecido, así como a la proyección del contrato respecto de o sobre una situación jurídica anterior, cuando ahora hablamos de ineficacia aludimos a la falta de producción de consecuencias o, cuando menos, de aquellas consecuencias que normalmente deberían haberse producido y que puedan ser razonablemente esperadas en virtud de la celebración del contrato"*.

7.2 CLASES O ESPECIES DE INEFICACIA.

La ineficacia puede provenir de:

1. DE UNA CIRCUNSTANCIA INTRÍNSECA AL ACTO JURÍDICO:

1) La omisión de un requisito esencial para la existencia de un AJ. Esta ineficacia se llama inexistencia e impide que el acto nazca a la vida del derecho y produzca efectos.

2) La omisión de un requisito esencial para la validez de un AJ. Esta ineficacia se llama nulidad. El acto produce todos los efectos que le son propios hasta que se declare judicialmente la nulidad.

2. DE UNA CIRCUNSTANCIA EXTRÍNSECA AL ACTO JURÍDICO:

El acto nace plenamente válido pero por circunstancias coetáneas o posteriores a la celebración del acto, se le priva de sus efectos. Existen numerosas circunstancias que pueden provocar esta ineficacia.

Ejemplos:

- i. El hecho de que falle una condición suspensiva.
- ii. El cumplimiento de una condición resolutoria.
- iii. La omisión de un trámite o diligencia que la ley prescribe para que un AJ produzca efectos respecto de terceros, con lo cual los efectos del acto quedan limitados solamente a las partes e ineficaz respecto de terceros.
- iv. Causas de impugnación que, hechas valer por el interesado en forma legal, privan al negocio de eficacia.

AJ impugnables.

Son aquellos actos que, incluso reuniendo todos los requisitos de validez, pueden destruirse en sus efectos, en virtud de acción de las partes o de tercero, por circunstancias extrínsecas, a menudo sobrevinientes, a las que el ordenamiento da relevancia.

Ejemplos:

- i. El incumplimiento de las obligaciones en un contrato bilateral.
- ii. La ingratitud del donatario.
- iii. La lesión.
- iv. El fraude en perjuicio de los acreedores.

Los actos impugnables producen todos sus efectos hasta que sea declarada su ineficacia por sentencia judicial, al igual que los actos anulables. Se diferencian de éstos en que:

- a) La ineficacia de los impugnables se debe a una causa extrínseca al acto.
- b) La impugnación no opera normalmente con efecto retroactivo.

7.3 LA INEFICACIA POR INEXISTENCIA EN EL CC.

1. Conceptos generales.

Es tradicional en la doctrina nacional la controversia sobre si el CC sanciona o no con la inexistencias los actos o contratos en que se ha omitido un requisito de existencia.

2. Posición de Luis Claro Solar: la teoría de la inexistencia tiene aplicación en el CC.

Si falta una de las cosas esenciales a su existencia, el AJ no puede existir, no puede producir efecto alguno, es la nada, lo que es distinto de la nulidad.

Nada: no existencia. Nulidad: invalidez.

Esta distinción está formulada en el CC:

1. Art. 1444 CC: si falta alguna de las cosas esenciales, el contrato “no produce efecto alguno”. Los actos que tiene un vicio de nulidad producen todos sus efectos mientras no se declare la nulidad.
2. Art. 1701 CC: la falta de instrumento público no puede suplirse por otra prueba en los actos en que la ley requiere esa solemnidad, y “se mirarán como no ejecutados o celebrados”, es decir, como inexistentes.
3. Art. 1809 CC: en cuanto a la determinación del precio en la compraventa, en caso de no convenirse, “no habrá venta”.

Todo esto da a entender que la omisión de ciertos requisitos tiene un alcance más amplio que la nulidad, pues “no produce efecto alguno” o “se mira como no ejecutado”, lo que no ocurre con el acto que tiene un vicio de nulidad, pues se tiene por ejecutado y produce todos sus efectos hasta que se declare judicialmente la nulidad.

3. Posición de Arturo Alessandri Rodríguez: la teoría de la inexistencia no tiene aplicación en el derecho chileno, por no estar acogida en el CC.

El CC establece, como máxima sanción, la nulidad absoluta, no la inexistencia. Argumentos:

1. El CC no contempla la inexistencia como sanción ni reglamenta sus consecuencias.
2. El Art. 1682 CC sanciona con la nulidad absoluta la omisión de los requisitos que la ley prescribe para el valor de los AJ en consideración a su naturaleza, refiriéndose tanto a la existencia como a la validez.
3. El mismo Art. sanciona con nulidad absoluta los actos de los absolutamente incapaces, los cuales, doctrinariamente hablando, deberían ser inexistentes, pues falta la voluntad.

4. Réplica de Luis Claro Solar.

1. El CC reglamenta la nulidad como un modo de extinguir las obligaciones. No podría haberse referido a la inexistencia, pues el acto inexistente no engendra obligaciones.
2. Art. 1682 CC se refiere a la omisión de los requisitos exigidos para el valor del acto, debiendo entenderse la expresión “valor” como sinónimo de validez.

3. En el hecho, los incapaces absolutos no consienten en el acto que ejecutan, o no pueden dar a conocer su verdadera voluntad. Pero como pueden aparentemente consentir, la ley expresamente declara que adolece de nulidad absoluta ese acto.¹²

5. Principales diferencias entre el acto inexistente y el acto nulo.

1. Efectos

- :
- El acto inexistente no origina ningún efecto que sea necesario destruir.
- El acto que adolece de un vicio de nulidad produce sus efectos propios, pero esa producción es efímera o caduca pues puede desaparecer con la declaración de nulidad.

2. Sentencia judicial:

- Para que el acto sea inexistente no se requiere una sentencia judicial, opera ipso iure, lo que no obsta a que el juez pueda reconocerlo.
- La anulación no puede hacerse sino en virtud de una sentencia judicial.

3. Saneamiento:

- El acto inexistente no puede sanearse (adquirir existencia).
- El acto que tiene un vicio de nulidad puede sanearse o validarse.

¹² Opinión de Vial.

Problema: El legislador no formuló en términos explícitos la distinción entre requisitos de existencia y validez. Pero implícitamente lo hace. El Art. 1444 CC señala que la omisión de una cosa de la esencia de un contrato impide que produzca efecto alguno, lo que se vincula a los requisitos de existencia, pues el acto a que falta un requisito de validez, produce efectos.

Antecedente adicional: El Art. 6º Ley 18.046 señala que "Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 6ºA, la sociedad anónima que no sea constituida escritura pública o en cuya escritura de constitución se omita cualquiera de las menciones exigidas en los números 1, 2, 3 ó 5 del artículo 4º, o cuyo extracto haya sido inscrito o publicado tardíamente o en el cual se haya omitido cualquiera de las menciones que para él se exigen en el artículo 5º, es nula absolutamente, sin perjuicio del saneamiento en conformidad a la ley", y agrega que las omisiones en la escritura de constitución o en el extracto se sancionan con la nulidad absoluta del pacto social.

La Ley 19.499 modificó la disposición, eliminando la referencia a la inexistencia y estableciendo la nulidad absoluta como sanción general. Sin embargo, en el Art. 6ºA se establece que "no obstante lo dispuesto en el Art. anterior, la S.A. que no conste de escritura pública, ni de instrumento reducido a escritura pública, ni de instrumento protocolizado, **es nula de pleno derecho y no podrá ser saneada**".

El término "nulidad de pleno derecho" es desconocido por el CC, y esa sanción ni siquiera puede inferirse de las normas del CC, a diferencia de la inexistencia. Se distingue claramente entre inexistencia y nulidad.

Es elemento de esencia específico de la S.A. la solemnidad prevista por la ley, de modo que si falta, la sociedad es **nula de pleno derecho, lo que significa que sin necesidad de una sentencia judicial** que declare la nulidad, la sociedad se mira como si nunca hubiera existido, lo que justifica que no pueda sanearse.

Esto revela que la nulidad de pleno derecho es diferente a la nulidad del CC, la cual jamás opera ipso iure: antes de la declaración, el acto existe y produce sus efectos, lo que justifica que pueda sanearse. Estas diferencias permiten asimilar la nulidad de pleno derecho a la inexistencia, pues no requiere sentencia judicial que la declare.

En conclusión, el concepto de nulidad de pleno derecho no desvanece el concepto de inexistencia, sino que lo fortalece.

7.4 LA INEFICACIA POR NULIDAD EN EL CC.

1. Conceptos generales.

Nulidad: Sanción para todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie o la calidad y estado de las partes. (Art. 1681 inc. 1º CC).

El CC regula la nulidad como un modo de extinguir las obligaciones (Art. 1567 Nº 8). Pero no extingue propiamente la obligación, sino que destruye el acto que la engendró, extinguiéndose por consecuencia la obligación.

2. Clases de nulidad.

Puede ser absoluta o relativa (Art. 1681 inc. 2º CC). Se diferencian por:

- 1) Sus causales.
- 2) Las personas que pueden impetrarla.
- 3) Su saneamiento.

Los efectos son los mismos.

3. Principios aplicables para ambas clases de nulidad.

- 1) Es una sanción de derecho estricto. Regla general (Art. 1681 CC):
 - Si se omite un requisito establecido por la ley para que el acto tenga valor, según su especie, la nulidad es absoluta;
 - Si el requisito mira a la calidad o estado de las partes, es relativa.
- 2) La nulidad no puede renunciarse anticipadamente porque protege intereses superiores de la colectividad. (Art. 1469 CC)
- 3) Cuando dos o más personas han contratado con un tercero, la nulidad declarada a favor de una de ella no aprovecha a las otras. (Art. 1690 CC)
- 4) La nulidad puede hacerse valer como acción o excepción.

7.4.1 LA NULIDAD ABSOLUTA.

1. Concepto de nulidad absoluta.

Es la sanción a todo acto o contrato a que falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del acto, según su especie. (Art. 1681 CC)

2. Causales de nulidad absoluta. (Art. 1682)

- 1) Objeto ilícito;
- 2) Causa ilícita;
- 3) Omisión de requisito que la ley prescribe para el valor del acto en consideración a su naturaleza;
- 4) Incapacidad absoluta.

Para quienes no aceptan la inexistencia, se agrega:

- 5) Falta de voluntad;
- 6) Falta de objeto;
- 7) Falta de causa;
- 8) Error esencial (algunos lo sancionan con nulidad relativa);
- 9) Falta de solemnidad requerida para la existencia del acto.

3. Personas que pueden impetrar la nulidad absoluta.

Para que un acto sea nulo es menester que una sentencia judicial lo declare.

Vías (Art. 1683 CC):

- 1) Declaración de nulidad absoluta a petición de una persona que tiene interés en ello.**

La ley no califica el interés que hace posible la petición, pero la doctrina y jurisprudencia coinciden en que:

- (1) Debe ser pecuniario y
- (2) Debe existir al momento de solicitarse la declaración (actual).

Personas interesadas: autor o partes del acto, e incluso un tercero que no intervino en él.

Excepción a la titularidad (Art. 1683 CC): no puede pedir la nulidad absoluta el que celebró el acto sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba. Esto debe interpretarse restrictivamente: afecta al autor o las partes, pero no a terceros, lo que es lógico, porque el autor o la parte que contrata en esa situación, revela mala fe.

- "*Sabiendo*": conocimiento personal, real y efectivo del vicio.
- "*Debiendo saber*": conocimiento que debería tener el autor o la parte en atención a las circunstancias del acto o la condición de quienes intervienen en él, no siendo posible considerar lógica o razonable la ignorancia del vicio.

- 2) Declaración de nulidad absoluta a petición del ministerio público (Fiscales CS y CAp).**

El interés que lo faculta no es pecuniario. La nulidad absoluta es de orden público y mira al interés general de la sociedad, por lo que se le concede la facultad de solicitar la declaración en el solo interés de la moral o de la ley. La ley no requiere que el vicio aparezca de manifiesto.

3) Declaración de nulidad absoluta de oficio por el juez.

El juez no lo solicita, sino que lo declara de oficio cuando el vicio aparece de manifiesto en el acto o contrato.

Principio procesal general: en materia civil, el juez puede actuar sólo a petición de parte. Una de las excepciones es la obligación de declarar la nulidad absoluta de oficio cuando el vicio aparece de manifiesto.

Manifiesto: descubierto, patente, claro. De la simple lectura del instrumento en que consta el acto, el juez advierte la existencia del vicio, sin necesidad de relacionarlo con ninguna otra prueba o antecedente.

4. Saneamiento de la nulidad absoluta.

La ley impide que la voluntad de las partes valide un acto que adolece de un vicio de nulidad absoluta, pues está establecida en el interés general. Sólo puede sanearse por el transcurso del tiempo. El plazo es de 10 años contados desde la fecha de celebración del acto.

7.4.2 LA NULIDAD RELATIVA

1. Concepto de nulidad relativa.

Es la sanción a todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del acto, según la calidad o estado de las partes. (Art. 1681 CC)

2. Causales de nulidad relativa.

El Art. 1682 CC, luego de mencionar las causales de nulidad absoluta, dice que "*cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa...*".

Las causales son:

1. Incapacidad relativa;
2. Error sustancial;
3. Error en la calidad accidental cuando haya sido el principal motivo para contratar y era conocido por la otra parte;
4. Error en la persona, cuando es relevante;
5. Fuerza moral grave, injusta y determinante;
6. Dolo determinante;
7. Omisión de requisito que la ley prescribe para el valor del acto en consideración a la calidad o estado de las partes;
8. Lesión, en ciertos casos.

3. Personas que pueden impetrar la nulidad relativa.

Pueden alegarla solamente aquellos en cuyo beneficio la ha establecido la ley, o sus herederos o cesionarios. (Art. 1684 CC)

No puede ser declarada de oficio por el juez ni puede solicitarse por el ministerio público o cualquier persona que tenga interés.

Pueden alegarla los herederos de la persona que, teniendo el derecho a pedirla, falleció sin haberlo hecho.

Cesionarios: personas a quienes los beneficiados con la nulidad transfieren, por acto entre vivos, los derechos que emanan del acto o contrato nulo, incluyéndose en esa cesión el derecho a demandar la nulidad.

Excepción a la titularidad:

Art. 1685 CC. Si de parte del incapaz ha habido dolo para inducir al acto o contrato, ni él ni sus herederos o cesionarios podrán alegar nulidad. Sin embargo, la aserción de mayor edad, o de no existir la interdicción u otra causa de incapacidad, no inhabilitará al incapaz para obtener el pronunciamiento de nulidad.

El incapaz relativo no puede solicitar la nulidad relativa de un acto alegando su incapacidad para obligarse. (Art. 1685 CC)

Esto supone que la parte que contrató con el incapaz lo hizo en la creencia de que éste no estaba afectado por ninguna incapacidad, incurriendo así en un error que fue provocado por las maniobras dolosas del incapaz (nadie puede beneficiarse de su propio dolo).

Contraexcepción: La ley no considera constitutivo de dolo el engaño consistente en la simple aserción de mayor edad o de no existir interdicción u otra causa de incapacidad, sancionando, de esta manera, la excesiva credulidad de la persona que no hizo nada por comprobar si afectaba o no a la contraparte alguna causal de incapacidad.

4. Saneamiento de la nulidad relativa.

El Art. 1691 CC contempla el plazo para pedir la rescisión: 4 años.

1) Saneamiento de la nulidad relativa por el transcurso del tiempo.

Supone que la persona que tenía derecho a pedirla no lo hizo en los 4 años. Este plazo se cuenta:

1. En caso de fuerza e incapacidad: desde que cesa;
2. En caso de error o dolo: desde la celebración del acto;

Si no se pide en ese plazo, el vicio desaparece, entendiéndose que jamás existió.

Situación que se produce cuando la persona que puede demandar la rescisión muere.

Está regulada en el Art. 1692 CC, que distingue:

- (1) Situación de los herederos mayores de edad: Si el cuadrenio no ha empezado a correr, tendrán 4 años para pedir la nulidad del acto celebrado por el causante, que se cuentan desde la muerte de éste; si el cuadrenio ha empezado a correr, pueden pedirla en el tiempo que falte para cumplir los 4 años. (Art. 1692 inc. 1º CC)
- (2) Situación de los herederos menores de edad: Si el cuadrenio no ha empezado a correr, tienen los 4 años a contar del día en que lleguen a mayor edad; si el cuadrenio ha empezado a correr, tienen el residuo a contar de ese mismo día. (Art. 1692 inc. 2º CC)

La ley establece exclusivamente el beneficio de los herederos menores la suspensión del plazo, el cual no beneficia a herederos incapaces por otra causa.

El Art. 1692 inc. final CC establece una excepción: *"(...) en este caso no se podrá pedir la declaración de nulidad pasados 10 años de la celebración del acto o contrato."*

Duda: ¿esta excepción se refiere a todos los herederos o sólo a los menores?
(limitar su posibilidad de acogerse al beneficio de la suspensión)

Argumento para decir que se aplica a todos: 10 años es el plazo máximo de prescripción, transcurrido el cual se consolidan todas las relaciones jurídicas.

Vial cree que esta interpretación no se conforma con el Art. 1691 CC que señala desde cuándo se cuenta el plazo para demandar la rescisión, pues al decir que en caso de fuerza o incapacidad se empieza a contar desde que ésta cesa, no establece el plazo máximo de 10 años. El plazo debe contarse desde que cesa, sin importar cuántos años hayan transcurrido desde la celebración del acto.

El problema práctico se soluciona pues en la mayoría de los casos, se habrán producido los efectos de la prescripción adquisitiva.

En consecuencia, la excepción se refiere sólo a los herederos menores, para quienes se suspende el cómputo del cuadrenio. Si no hubiera transcurrido el plazo de 10 años desde la fecha del acto, el heredero menor podrá acogerse a la suspensión del plazo. La norma pretende beneficiar a los herederos menores y no perjudicarlos.

2) Saneamiento por la ratificación o confirmación del acto rescindible.

“Confirmación” es ajena al CC, que usa “ratificación”.

Ratificación: consiste en la renuncia a la inoponibilidad. Por ejemplo, los casos en que el mandante aprueba lo obrado por el mandatario que actuó sin poder suficiente o excediéndose de sus límites; o en que el dueño aprueba la venta de la cosa ajena.

Confirmación: acto jurídico unilateral por el cual la parte que tenía el derecho de alegar la nulidad relativa renuncia a esta facultad, saneando el vicio de que adolecía el acto. El acto se transforma en plenamente válido.

La confirmación se fundamenta en el Art. 12 CC que permite renunciar los derechos que miren al interés individual y cuya renuncia no esté prohibida.

Clasificación de la confirmación.

1. Expresa: Declaración en la cual, la parte que tiene derecho a pedir la rescisión, en términos explícitos y directos, manifiesta su voluntad de validar dicho acto.

2. Tácita: Ejecución voluntaria de la obligación contratada (Art. 1695 CC).

Análisis de algunos problemas doctrinarios en relación con la confirmación tácita.

A) ¿Qué significa ejecución voluntaria de la obligación? Requisitos:

- i. Se hace en forma libre y espontánea,
- ii. con la voluntad exenta de vicios
- iii. el conocimiento del confirmante del motivo de anulabilidad.

Vial concuerda con la necesidad de este tercer requisito, porque la voluntariedad de la ejecución requiere una representación fiel y acertada de la realidad, y para lograr ese conocimiento, es necesario que el sujeto sepa que el acto adolece de un vicio por el cual podría demandar la rescisión.

B) ¿Podría otro hecho, además de la ejecución voluntaria de la obligación, importar confirmación tácita? Posible caso: la parte que tiene derecho a alegar la rescisión, con conocimiento de ello, solicita a la otra parte un plazo para pagar la obligación.

Opinión mayoritaria: sólo cabe confirmación tácita por la ejecución voluntaria de la obligación.

Pero esto no obsta a que la conducta del sujeto permita desprender, si no una confirmación, una renuncia tácita al derecho a alegar la rescisión.

Existe una manifiesta relación entre la confirmación y la renuncia, pues toda confirmación involucra la renuncia al derecho a alegar la rescisión. Pero no toda renuncia confirma o convalida el acto.

- C) ¿Es necesario para que exista confirmación tácita que el acto se ejecute en su totalidad o basta con la ejecución de una parte? Para el CC, basta el cumplimiento de la obligación, sin distinguir si la obligación ejecutada implica cumplimiento del contrato en su totalidad o en una parte.

Características de la confirmación.

1. AJ unilateral.
2. AJ accesorio, pues no puede subsistir sin el acto que se convalida.
3. Irrevocable.
4. Opera con efecto retroactivo: por ficción legal, se supone que el acto siempre ha sido válido y jamás ha tenido vicios.

Requisitos de la confirmación.

1. Debe tratarse de un vicio sancionado con nulidad relativa (no absoluta).
2. Debe necesariamente provenir de la parte que tiene derecho a alegar la nulidad.
3. El confirmante debe ser capaz de contratar. Esto no significa que si el acto era rescindible por incapacidad relativa de una de las partes, ésta deba necesariamente esperar a que cese la incapacidad para confirmar válidamente, pues puede confirmar antes si lo hace representado.
4. Debe hacerse en tiempo oportuno: el que media entre la celebración del acto y la declaración judicial de nulidad.
5. Debe efectuarse después de haber cesado la causa de invalidez (Ej. fuerza).
6. Cuando es expresa, debe cumplir con las mismas solemnidades a que por ley está sujeto el acto que se confirma. (Art. 1694 CC)

..... DIFERENCIAS ENTRE LA NULIDAD ABSOLUTA Y LA NULIDAD RELATIVA.....

- Causales
- Personas que puedes impetrarla
- Saneamiento

I. Personas que pueden pedir la declaración judicial de nulidad:

1. Absoluta: todo el que tenga interés (salvo el que lo ejecutó sabiendo o debiendo saber el vicio), ministerio público.
2. Relativa: persona en cuyo beneficio la ha establecido la ley, sus herederos o cesionarios.(salvo el caso del incapaz doloso)

II. Declaración de nulidad de oficio por el juez:

1. Absoluta: debe ser declarada de oficio cuando aparece de manifiesto.
2. Relativa: no puede ser declarada de oficio.

III. Saneamiento por el transcurso del tiempo:

1. Absoluta: 10 años desde la fecha de celebración del acto.
2. Relativa: 4 años desde los momentos que ya vimos.

IV. Saneamiento por confirmación o ratificación:

1. Absoluta: no puede sanearse por voluntad del autor o las partes.
2. Relativa: puede sanearse por confirmación o ratificación.

7.4.3 NULIDAD TOTAL Y NULIDAD PARCIAL.

1. Invalidez total y parcial.

Nulidad total: el vicio afecta a todas las partes y cláusulas del AJ.

Nulidad parcial: el vicio afecta sólo a una parte o una cláusula del AJ, o a una parte o elemento de una cláusula.

Problema: la invalidez de una parte ¿implica la invalidez de todo el acto?

2. Principios doctrinarios aplicables a la nulidad parcial.

- a) La parte o cláusula inválida se separa del AJ, quedando éste válido en todo lo no afectado por el vicio.
- b) La parte o elemento de la cláusula afectada se tiene por no existente y la cláusula se reduce: reducción interna de la cláusula.

Estos principios no se pueden aplicar si la parte no afectada por la invalidez es por su naturaleza dependiente o accesorio respecto a la inválida. Tampoco se aplican si se prueba que, sin la parte o cláusula inválida, el AJ no se habría realizado; o que sin esa parte o elemento, la cláusula no se habría estipulado.

3. Invalidez parcial en el CC.

El CC no soluciona el problema. Pero hay casos en que se aplica la no extensión de la invalidez a todo el acto. Ej.

1. Art. 966 CC declara nula la disposición a favor de un incapaz y no el testamento entero.
2. Art. 1401 CC dice que la donación sobre 2 centavos que no se insinúa es nula en el exceso.
3. Art. 2344 CC establece que cuando el fiador se obliga en términos más onerosos que el deudor principal, la fianza es nula en el exceso.

7.4.4 EFECTOS DE LA NULIDAD.

1. Conceptos generales.

Para que se produzcan los efectos, es necesaria la existencia de una sentencia judicial firme o ejecutoriada que declare la nulidad del acto. Antes de la sentencia, el acto produce todos sus efectos, como si fuera válido. Pero esos efectos son efímeros.

No hay diferencias entre la nulidad absoluta y relativa en cuanto a los efectos de la nulidad judicialmente declarada.

2. Efectos que produce la nulidad para las personas que celebraron el acto o contrato nulo.

Principio general (Art. 1687 inc. 1º CC): *"...da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto..."*.

La nulidad impide que el acto produzca efectos hacia el futuro, pero como además opera con efecto retroactivo, se entiende que el acto nunca existió.

La declaración de nulidad es uno de los modos de extinguir las obligaciones. (Art. 1567 N° 8 CC).

En ciertos casos, el efecto retroactivo sólo puede conseguirse a través de determinadas prestaciones tendientes, en general, a que la persona que recibió algo en virtud del acto lo restituya a quien se lo dio o entregó. Estas prestaciones mutuas se rigen por las reglas de la acción reivindicatoria.

Se acostumbra hacer ciertas distinciones para analizar los efectos de la nulidad:

1. El acto no engendró obligaciones.
2. El acto sí engendró obligaciones:
 - a) No se han cumplido: la nulidad las extingue de acuerdo al Art. 1567 N° 8 CC.
 - b) Sí se han cumplido por una o ambas partes: opera el Art. 1687 CC que obliga a efectuar prestaciones.

Esta distinción tiene imprecisiones, es insatisfactoria para los contratos reales. Ej. Comodato. Si se declara la nulidad del comodato, ¿significa que la obligación de restituir, cuyo cumplimiento está pendiente, se extingue sin más? La respuesta negativa se impone por lo injusto que sería. La obligación de restituir se ha extinguido, pero el efecto retroactivo de la nulidad impone al comodatario la restitución de la cosa, no en virtud del contrato nulo, sino como consecuencia del Art. 1687 CC.

Entonces, cabe agregar a la regla de que si el acto engendró obligaciones que no se han cumplido, éstas simplemente se extinguen, el requisito de que con

ello se pueda volver al estado anterior. Si no es así, deberán las partes efectuar las prestaciones tendientes a restituir lo recibido.

En las restituciones, cada parte es responsable de:

- la pérdida o deterioro de las especies,
 - de los intereses
 - de los frutos,
 - y del abono de las mejoras,
- ☐ ☐ Tomándose en consideración casos fortuitos y posesión de buena o mala fe, todo de acuerdo a las reglas generales de la reivindicación (Art. 1687 inc. 2º CC).

Debe restituirse la cosa, y también sus frutos naturales y civiles, distinguiendo si el poseedor estaba de buena o mala fe. Está de mala fe quien recibió la cosa conociendo el vicio del acto.

3. Excepciones a la regla general establecida por el Art. 1687.

1) Declaración de nulidad por objeto o causa ilícita:

Se refiere al Art. 1468 CC: no puede repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas.

2) Situación del poseedor de buena fe:

No está obligado a restituir los frutos naturales y civiles percibidos antes de la contestación de la demanda. (Art. 907 CC). Algunos señalan que este caso más que una excepción es aplicación de las reglas de las prestaciones mutuas de la acción reivindicatoria.

3) Situación en que se encuentran las partes como consecuencia de la declaración de nulidad de un contrato por la incapacidad de una de ellas:

Si se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz, el que contrató con ella no puede pedir restitución o reembolso de lo pagado o gastado en virtud del contrato, sino en cuanto probare haberse hecho más rica con ello la persona incapaz. (Art. 1688 CC)

Se entiende que se hizo más rica:

- i. En cuanto las cosas pagadas o adquiridas por medio de ellas le hayan sido necesarias.
- ii. O en cuanto las pagadas o adquiridas por medio de ellas, que no le hubieren sido necesarias, subsistan y quiera retenerlas.

La ley protege a los incapaces pues teme que, cuando actúan sin los requisitos exigidos por ley, no den adecuada inversión a lo que obtengan del contrato.

Pero este temor no se da si el incapaz se hizo más rico. Además, si las cosas no le son necesarias y están en su poder, es lógico que las restituya. Ahora, si no subsisten en su poder, se dan las condiciones que justifican la protección.

Algunos consideran que esta regla es una manifestación al principio de reparación al enriquecimiento sin causa.

Esta regla sólo se aplica cuando el acto se anula precisamente por la causal de incapacidad.¹²

4) Situación de la persona que debiendo restituir la cosa adquiere su dominio por prescripción:

Se refiere a cuando la persona adquiere por tradición, y luego se anula la tradición o el título traslativo. La nulidad impide que la tradición transfiera el dominio, pero no obsta a la adquisición de la posesión.

El poseedor puede adquirir el dominio por prescripción, en este caso extraordinaria, pues su posesión es irregular (el título en que se funda no es justo, Art. 704 N° 3 CC). Así, el poseedor puede retener la cosa que debía restituir.

La posibilidad de que a la fecha de la demanda el poseedor ya haya adquirido el dominio se da en el caso de que el demandante esté en tiempo porque el cuadrienio no había empezado a correr o quedaba un residuo.

4. Efectos de la nulidad judicialmente declarada en relación con terceros.

Regla general: la nulidad judicialmente declarada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores (Art. 1689 CC).

Art. 1689 CC. La nulidad judicialmente pronunciada da acción reivindicatoria contra terceros poseedores; sin perjuicio de las excepciones legales.

Quien reivindica debe ser dueño de la cosa.

¹² Ejemplo 1: Juan, de quince años, le vende su bicicleta a Pedro por \$100.000 pesos. Luego, Juan gasta todo el dinero en los Juegos Diana. Al anularse el contrato, Pedro no puede pedir la restitución del dinero que pagó, pues Juan no se hizo más rico con este contrato.

Ejemplo 2: Diego, de catorce años, le vende su chaqueta a Luis por \$50.000 pesos. Luego, Diego se compra una mochila nueva con ese dinero. Al anularse el contrato, Luis sí puede pedir la restitución del dinero que pagó, pues la mochila era necesaria para Luis y, en cualquier caso, subsiste y la quiere retener.

La regla no distingue si los terceros están de buena o mala fe.

5. Excepciones a la regla general del Art. 1689.

1) Caso del poseedor que ha adquirido el dominio por prescripción adquisitiva:

El tercero ha adquirido, en todo caso, en virtud de la tradición que se le hizo, la posesión de la cosa, que le permitirá ganar el dominio por prescripción.

2) Caso del heredero indigno que enajena bienes de la herencia:

Declarada judicialmente la indignidad del heredero o legatario, éste es obligado a la restitución de la herencia o legado con sus accesiones y frutos (Art. 974 CC). Sin embargo, si el indigno ha enajenado los bienes, los herederos a quienes beneficia la declaración de indignidad tendrán acción sólo contra los terceros de mala fe. (Art. 976 CC).

3) Caso del comprador que es condenado a restituir la cosa cuando se ha declarado la rescisión de la compraventa por lesión enorme:

Las enajenaciones o gravámenes que hubiera hecho el comprador sobre la cosa antes de que se pronuncie la nulidad no quedan sin efecto de pleno derecho como consecuencia de ésta. Por eso este caso es una excepción al efecto retroactivo de la nulidad, y por eso el comprador debe “purificarla” previamente a su restitución.

Art. 1893. Perdida la cosa en poder del comprador no habrá derecho por una ni por otra parte para la rescisión del contrato.
Lo mismo será si el comprador hubiere enajenado la cosa; salvo que la haya vendido por más de lo que había pagado por ella; pues en tal caso podrá el primer vendedor reclamar este exceso, pero sólo hasta concurrencia del justo valor de la cosa, con deducción de una décima parte.

Art. 1895. El comprador que se halle en el caso de restituir la cosa, deberá previamente purificarla de las hipotecas u otros derechos reales que haya constituido en ella.

4) Caso de la declaración de nulidad de una sociedad:

La nulidad del contrato de sociedad no perjudica las acciones que puedan tener terceros de buena fe en contra de los asociados, por operaciones de la sociedad (art. 2058).

7.4.5 CONVERSIÓN DEL ACTO NULO.

1. Conceptos generales sobre la conversión.

Conversión: medio jurídico en virtud del cual un negocio se salva de la nulidad convirtiéndose en otro distinto, que sustituye al primero, en la medida de lo posible salvaguardando con ello hasta ese límite el fin perseguido por las partes.

Para que esta sustitución opere, es necesario que en el negocio nulo se contengan los requisitos sustanciales y formales del negocio en que se convierte.

2. Requisitos para que opere la conversión.

1. Que el acto nulo cumpla con los requisitos que se exigen para el acto diverso en que se transforma.
2. Que las partes tengan conocimiento de la ineficacia del primer acto.

3. La teoría de la conversión en el CC.

El CC no contempla ninguna norma que la permita.
Podría pensarse que lo permite el Art. 1444 CC, al decir que la omisión de un elemento de la esencia trae como consecuencia que el acto no produzca efecto alguno o degenere en uno diferente. Pero esto no es una hipótesis de conversión. Las partes, por ignorancia o equivocación, se formularon una representación errada del derecho, pues creían celebrar un contrato y celebraban otro.

Sí puede extraerse mejor el principio de la conversión de:

1. Art. 1701 CC: el instrumento público defectuoso por incompetencia del funcionario u otra falta formal, vale como instrumento privado si está firmado por las partes. Es decir, la escritura pública se convierte en instrumento privado.
2. Art. 1138 CC: las donaciones entre cónyuges valen como donaciones revocables. Es decir, la donación ineficaz como irrevocable, se convierte en revocable.

Como no hay un principio general en el CC, la posibilidad de conversión se restringe a los casos particulares en que la ley lo permite.

7.4.6 EL ERROR COMÚN ACERCA DE LA CAUSA DE INVALIDEZ.

1. Conceptos generales del error común.

A fin de conciliar el derecho y la equidad a algunos les parece oportuno

apoyarse en el principio *error communis facit ius* para sostener que el error no individual, sino común, en torno a la causa de invalidez del negocio lo hace inatacable, como si hubiese sido válidamente constituido.

Esta es la posición tradicional de la doctrina francesa, que estima que el error común sobre la causa de nulidad valida al acto en que incidió el vicio.

2. Fundamentos de la teoría del error común.

A) Fundamento histórico: Este efecto validante era aceptado por el derecho romano.

B) Fundamento jurídico:

1. Tendencia del legislador de proteger la buena fe, la que se da incluso cuando el error no es común, sino que individual, como ocurre en el matrimonio putativo.

2. La nulidad se impone como una sanción a quienes celebran un AJ que no cumple con los requisitos establecidos por la ley para su validez, lo que supone culpa o negligencia, aunque sea mínima, en la persona que contrató pese a la existencia del vicio. Sería injusto que se dieran las consecuencias de la nulidad en caso de que, existiendo error común, no se dé culpa punible.

3. Requisitos del error para validar un acto nulo.

1) Debe ser común, es decir, compartido por la generalidad de los que se hallan en las mismas circunstancias que las partes.

2) Debe ser excusable, esto es, justo motivo de error.

3) Buena fe de quienes incurrir en él.

4. Doctrina que rechaza el efecto validante del error común como principio general.

a) No es efectivo que los romanos establecieron este principio general. Es una deformación histórica.

b) No es efectivo que la nulidad sea una sanción que requiera la existencia de culpa o negligencia, sino que constituye una sanción de carácter estrictamente objetivo.

No es necesario recurrir a la máxima *error communis facit ius*, pues en la mayoría de los casos en que se pretende aplicarla, el legislador, guiado por razones de justicia, equidad y protección a la buena fe, expresamente ha contemplado disposiciones que le dan validez al acto, las que son de carácter excepcional.

5. La teoría del error común en el CC.

No contempla ninguna norma que reconozca expresamente y en términos generales el efecto validante del error común. Pero hay disposiciones que se

fundan en él. Ej. Art. 1013 CC: Si alguna de las causas de inhabilidades para ser testigo en un testamento solemne no se manifiesta en el aspecto o comportamiento de un testigo, y se ignora generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se invalida el testamento.

La doctrina y jurisprudencia nacionales coinciden en que el efecto validante del error común es un principio general.

7.5 LA INEFICACIA POR INOPONIBILIDAD

Cuando un acto jurídico nace en la vida del derecho, crea una nueva situación jurídica que no puede ser desconocida. Por lo mismo, y salvo casos de excepción, todos estamos obligados a reconocer la existencia del contrato. Sin embargo, la eficacia de un acto en relación a terceros tiene aparejado ciertos peligros, pues podrían estar en legítima ignorancia del acto. Es por ello que, en ciertas circunstancias, el legislador interviene negando la eficacia de dicho acto.

La inoponibilidad es una sanción de ineficacia jurídica respecto de los terceros ajenos al acto o contrato, y en cuya virtud se les permite desconocer los derechos emanados de ellos.

A diferencia de la nulidad, la inoponibilidad no es objeto de una regulación orgánica, sin embargo, ella está establecida en múltiples preceptos.

1. Diferencias entre la inoponibilidad y la nulidad

1. La nulidad supone la existencia de un vicio en el nacimiento del acto jurídico. En la inoponibilidad el acto es válido e irreprochable, pero pierde su eficacia respecto a terceros por el acaecimiento de ciertas circunstancias.
2. En relación a sus efectos, la nulidad priva al acto de sus efectos, respecto a las partes y terceros. La inoponibilidad, en cambio, deja al acto subsistir entre las partes, pero lo priva de efectos respecto a terceros.
3. En relación a la posibilidad de renunciar a la sanción por las partes, en la nulidad dicha opción es limitada, pues existe por regla general un interés público comprometido. La inoponibilidad puede ser renunciada.
4. La nulidad absoluta puede ser declarada de oficio por el juez. No así la inoponibilidad.

2. Casos de inoponibilidad

Ante la inexistencia de una teoría general de la inoponibilidad en el Código Civil, analizaremos algunos casos específicos en que el legislador ha sancionado un acto con inoponibilidad:

- a) Inoponibilidades de forma: Se sanciona con inoponibilidad la omisión de ciertas formalidades de publicidad. Ejemplos:
- i) Las contaescrituras públicas no surten efectos respecto a terceros si no se toma razón de ellas al margen de la escritura original (art. 1707 inc.2).
 - ii) Si no se inscribe la sentencia que declara la prescripción adquisitiva del dominio o de derechos reales sobre inmuebles, no vale respecto a terceros (art. 2513).
- b) Inoponibilidades por falta de concurrencia: Se sanciona con inoponibilidad ciertos actos cuando una persona no concurre con su consentimiento al otorgamiento de un acto que lo requería para producir efectos, Ejemplos:
- i) Venta de cosa ajena (art.1815).
 - ii) Los actos realizados por un mandatario excedido en el ejercicio de sus funciones son inoponibles al mandante (art. 2160, a contrario sensu).
- c) Inoponibilidades derivadas de la nulidad o revocación: determinadas situaciones jurídicas pueden afectar a terceros y ser posteriormente dejadas sin efecto, con grave daño a sus intereses. Al declararse judicialmente la nulidad, opera el efecto retroactivo afectando incluso a los terceros, muy excepcionalmente la ley no permite que la nulidad pueda ser invocada por ellas. Ejemplos:
- i. El matrimonio putativo. (art. 122) La filiación no se ve afectada (tampoco en caso de nulidad del matrimonio sin existir matrimonio putativo).
 - ii. Sociedad. (art. 2058) La nulidad de las sociedad no perjudica las acciones que tengan los terceros de buena fe contra todos y cada uno de los asociados.

3. Efectos de la inoponibilidad:

Entre las partes, el acto es plenamente válido, produciendo todos sus efectos. Respecto a terceros, el acto no produce efectos. Los terceros pueden hacer valer la inoponibilidad como acción o como excepción,

4. Extinción de la inoponibilidad:

Termina por la renuncia a ella, que afecta únicamente a quien la efectúa. También puede terminar por la reparación del vicio de forma que la originó. Otra forma de extinción de la inoponibilidad es por prescripción extintiva cuando se hace valer como acción, (al no tener un plazo especial, serán 5 años).

CAPÍTULO 8. LA REPRESENTACIÓN EN LOS AJ.

8.1 CONCEPTOS GENERALES SOBRE LA REPRESENTACIÓN.

Lo más frecuente es que las partes en un contrato intervengan personalmente en su celebración. Pero es posible que el autor o una de las partes estén impedida para concurrir personalmente.

Por ello, es corriente que una persona dé a otra poder para que contrate a nombre y en lugar suyo. Los efectos del acto que concluye una persona a nombre de otra se radican directamente en esta última.

Entonces, las personas que intervienen en un AJ pueden hacerlo de 2 maneras:

1. A nombre propio: regulan personal y directamente sus intereses.
2. A nombre ajeno: regulan los intereses de terceros, en virtud de una expresa autorización.

Representación: institución jurídica en virtud de la cual los efectos de un acto que celebra una persona que actúa a nombre o en lugar de otra, se radican en forma inmediata y directa en esta última, como si ella personalmente lo hubiera celebrado.

Intervienen 2 personas:

1. Representante: es quien celebra el AJ a nombre o en lugar de otra.
2. Representado: persona en quien se radican los efectos del acto ejecutado por el representante.

Art. 1448 CC. Lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo.

8.2 PODER DE REPRESENTACIÓN.

Poder de representación: autorización que tiene una persona para concertar negocios por cuenta de otra, obligando exclusiva y directamente al representado.

En doctrina, “poder” y “facultad” son distintos.

- Facultad: toda acción lícita que una persona puede ejecutar en la órbita de sus propios intereses.
- Poder: potestad que tiene una persona para ejecutar con éxito AJ que dicen relación con los intereses de terceros.

Por regla general, las personas están facultadas para disponer por sí solas de los intereses que se encuentran dentro de su órbita jurídica. Excepcionalmente, cuando tienen capacidad restringida, requieren autorización de otras personas. Pero nadie está facultado para disponer de intereses ajenos, a menos que tenga el poder para ello, el cual puede emanar de la ley o de la voluntad del interesado.

Apoderamiento: acto por el cual se atribuye a una persona el poder de representar a otra.

8.3 CLASES DE REPRESENTACIÓN.

A) Legal:

Por regla general, supone que una persona se encuentra en la imposibilidad jurídica de ejercer por sí sola la autonomía privada. En este sentido, la ley sustrae al incapaz la facultad de proveer por sí mismo a sus propios intereses, y al juicio del interesado sustituye el juicio y decisión de otro sujeto. La persona que es representada legalmente carece de libertad para decidir quien la represente. Su representante es el que determina la ley.

El representante legal debe ser plenamente capaz.

Ejemplos:

- Padre o madre del hijo,
- tutor o curador del pupilo,

Ahora bien, la excepción a esta regla general dice relación con aquellos casos en los que, por razones diversas, la ley somete a una persona plenamente capaz a la representación legal.

Ejemplos:

- juez del ejecutado, en relación al contrato de compraventa de sus bienes por pública subasta
- el liquidador respecto de la persona sometida a procedimiento concursal
- el curador de bienes respecto del ausente

B) Voluntaria:

Surge como consecuencia de un acto voluntario del interesado, que otorga poder a otra persona para que actúe a su nombre. Supone la libertad del interesado para decidir si actúa o no personalmente y para escoger la persona del representante, que puede incluso ser un incapaz.

8.4 MANDATO Y REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA.

La doctrina tradicional no concibe la existencia de representación voluntaria sin mandato. Vial opina que el mandato y la representación voluntaria son 2 cosas muy distintas.

La diferencia más importante es que:

- El mandato es un contrato y, como tal, requiere del acuerdo de voluntades de las dos partes para perfeccionarse.
- El apoderamiento, en cambio, es un AJ unilateral que adquiere existencia por la sola manifestación de voluntad del poderdante.

Además, cumplen roles jurídicos distintos.

- El mandato da lugar a una obligación para el mandatario, el cual se ve por esta razón en la necesidad jurídica de obrar.
- El apoderamiento es sólo consentimiento en la representación, y sus efectos un poder jurídico: el poder de representación.

Por último, la representación no es de la esencia del mandato. En cambio, el apoderado tiene siempre la calidad de representante.

Conclusión:

a) La representación voluntaria no supone necesariamente un mandato. Pero Vial cree que cada vez que se otorga a una persona poder de representar, se le ofrece al mismo tiempo, al menos tácitamente, la celebración de un mandato que se perfecciona con la ejecución del acto para el cual se otorgó el poder.

b) Si bien el apoderamiento puede existir antes del mandato y constituir un acto separado, no se puede concebir el ejercicio del poder de representación desligado del cumplimiento del mandato.

c) La potestad de representar no es de la esencia del mandato; es posible que el mandatario no represente al mandante, lo que ocurre cuando el mandatario contrata a su propio nombre, aunque sea en interés del mandante.

8.5 NATURALEZA JURÍDICA DE LA REPRESENTACIÓN.

Es discutida, distinguiéndose las siguientes teorías que explican la naturaleza jurídica de la representación:

1) Teoría de la ficción de la ley: Para Pothier, los efectos del AJ ejecutado por una persona que actúa a nombre de otra, se radican directamente en el representado porque a través de una ficción de la ley se supone que es él quien manifiesta su voluntad.

2) Teoría del nuncio o mensajero: Para Savigny, el verdadero sujeto del AJ es el representado; el representante no es más que un simple mensajero del representado, un portador de una declaración ajena de voluntad.

Crítica para ambas teorías: no explica la representación legal ni la representación sin poder. Además, se llegaría a consecuencias poco satisfactorias si se sostiene que la voluntad y el conocimiento del representado son lo único decisivo, eliminándose del nexo contractual la voluntad y conocimiento del representante.

3) Teoría del doble contrato de Thol: El representante no comunica simplemente la voluntad contractual del representado, sino que, por medio de su voluntad, hace la de aquel concreta. Los derechos y obligaciones se radican directamente en el representado como consecuencia de la celebración de 2 contratos con el tercero:

- Representante/tercero, haciendo referencia a la voluntad del representado y al poder de representación.
- Representado/tercero, y que aquel concluye en virtud de esa referencia y como consecuencia del contrato anterior.

Crítica a esta teoría:

1º. Parte de la base de que el representante tiene una cierta autonomía para concretar la voluntad general del representado. En el caso de que el poder fijase todos los puntos del negocio, no quedaría margen alguno para la voluntad del representante.

2º. Parte del supuesto de que en el poder existe una voluntad dirigida hacia la conclusión inmediata de un AJ concreto. El poder no es la voluntad acabada ni la declaración contractual todavía imperfecta. Es una AJ perfecta, con contenido volitivo propio y distinto del negocio principal.

4) Teoría de la cooperación de voluntades: Para Mitteis, en la representación existe un solo AJ que el representado y el representante celebran conjuntamente. La voluntad contractual está repartida entre ambos. El apoderamiento no es un AJ independiente sino una parte integrante del negocio principal mismo.

Crítica: cuando el apoderamiento se concibe en términos extraordinariamente acabados y precisos, no cabe prácticamente al representante ninguna participación.

5) Teoría que considera relevante la actuación del representante: Para Hupka, la manifestación de voluntad necesaria para la existencia del AJ proviene siempre del representante.

La actividad jurídica del representante no consiste en completar la voluntad del apoderamiento ni en transmitirla sin alteración, sino en concebir y formular siempre la inmediata disposición voluntaria en su totalidad. El principal tiene solamente la voluntad de que el representante cree el AJ mediante su propia decisión. El poder es solamente la condición y el límite para la eficacia de la voluntad del representante.

6) Teoría de la modalidad: Quien manifiesta su voluntad en el AJ es directamente el representante, no obstante lo cual, por ser la representación una modalidad de los AJ, los efectos del acto no se radican en el representante, sino que en la persona del representado.

8.6 INFLUENCIA DE LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL REPRESENTANTE O DEL REPRESENTADO EN EL ACTO JURÍDICO.

Las teorías se preguntan quien es la persona que manifiesta su voluntad en el AJ. Esto tiene importancia práctica, pues de la posición que se adopte surgen consecuencias jurídicas.

Hupka propone el siguiente criterio orientador: el conocimiento del representante no perjudica al representado más que cuando un interés preferente de la otra parte o de un tercero lo exige; el conocimiento del representado sólo deja de perjudicarlo cuando por razones de hecho o de derecho no esté en condiciones de impedir al representante la conclusión del negocio.

1) En relación con la capacidad.

¿Quién debe ser capaz? Para Savigny, sólo el representado. Pero si estimamos que es el representante quien manifiesta su voluntad, éste debe ser capaz. Hay que distinguir:

a) Capacidad del representado:

1. Representación legal: el representado es normalmente un incapaz absoluto o relativo.
2. Representación voluntaria: el representado es una persona capaz, pues la capacidad es un requisito para la plena eficacia del apoderamiento.

b) Capacidad del representante:

1. Representación legal: el representante debe ser capaz.
2. Representación voluntaria: el representante que tiene calidad de mandatario puede ser incapaz; basta con que tenga juicio y discernimiento suficiente para que obligue al mandante respecto de terceros. El Art. 2128 CC faculta al menor adulto para ser mandatario sin autorización de su representante legal, y sus actos son válidos respecto de terceros en cuanto obliguen a éstos y al mandante. Pero en cuanto a las obligaciones que el mandatario incapaz contraiga con el mandante o con terceros, se siguen las reglas generales de capacidad.

2) En relación con las formalidades que exige la ley para los actos de ciertas personas.

Si las formas tienen como misión dificultar los actos de disposición de las personas sometidas a ellas y asegurar su contenido, deben ajustarse a ellas también los negocios celebrados por un representante en nombre de esas personas, mientras que los negocios que esas personas celebren como representantes de otras no sujetas a las formas, no necesitan ajustarse a ellas.

Ej. Formalidad habilitante de protección constituida por la autorización judicial para la enajenación de los bienes raíces del hijo. Esta formalidad es necesaria siempre, sea que la enajenación la realiza el padre o un tercero. Pero el hijo, en calidad de mandatario y representante de otra persona, no requiere autorización para enajenar bienes raíces, pues no son propios de él.

3) En relación con los vicios del consentimiento.

1. El error del representante vicia el consentimiento siempre que dicho error sea también relevante para el representado.
2. La fuerza o dolo determinante que se ejerza sobre el representante vicia el consentimiento.
3. El error relevante del representado o la fuerza o dolo que se ejerza sobre él hace anulable el poder y, a través de éste, el acto.

¿Qué pasa si el representado o representante ejercen fuerza o dolo contra el otro contratante? En el caso de la fuerza, es indiferente quién la emplee, pues si es determinante, de todos modos vicia el consentimiento. Pero en el dolo es importante, porque para viciar el consentimiento tiene que ser obra de la contraparte.

Vial cree que vicia el consentimiento en cualquiera de los dos casos. El dolo o mala fe del representante afecta al representado, y si existen en el representado, deberá soportar sus consecuencias, pues en él se radican los efectos del acto y no puede valerse de un tercero para escapar a las sanciones de la mala fe.

4) En relación con la buena o mala fe del sujeto.

Ejemplo en que es relevante: la ley permite que se adquiera la posesión por representante.

Vial cree que la mala fe del representado hace imposible que adquiera la posesión regular, aunque se haya valido para ello de un representante de buena fe.

El problema se da con la mala fe del representante que no es compartida con el representado. La regla general es que la mala fe del representante afecta al representado aunque este se encuentre de buena fe.

5) En relación con la disposición legal que impide demandar la nulidad absoluta al que sabía o debía saber el vicio que invalidaba al acto y con aquella que impide repetir lo pagado por objeto o causa ilícita a sabiendas.

Si el representado sabía o debía saber el vicio, o contrató a sabiendas del objeto o causa ilícita, no podrá alegar la nulidad o repetir lo pagado.

El problema surge cuando la mala fe es del representante. La doctrina extranjera resta relevancia a esta mala fe. En Chile, la jurisprudencia es

contradictoria. Hay un fallo que permite al representado alegar la nulidad absoluta porque el dolo, que es lo que la ley castiga, es un acto personalísimo.

6) En relación con las impugnaciones de las enajenaciones del deudor.

Si existe fraude pauliano en el deudor representado, los acreedores pueden deducir acción pauliana para revocar la enajenación efectuada por el representante, aunque éste no tenga conocimiento del mal estado de los negocios del representado.

Si el deudor representado no comparte el fraude pauliano que sí existe en el representante, debe perjudicar al representado, pues se protege más a los acreedores.

8.7 REQUISITOS DE LA REPRESENTACIÓN.

1) El representante debe declarar su propia voluntad.

Es el representante quien da vida al AJ con su voluntad, en todo caso, aunque haya de atenerse a las instrucciones recibidas.

2) El representante debe actuar a nombre del representado: *contemplatio domini*.

El representante tiene que manifestar, de alguna manera, que su declaración se refiere a otra persona, a nombre de la cual está obrando. Si falta esta referencia, el AJ va a surtir efectos para el representante y no para el representado.

La manifestación no está sujeta a formalidades especiales; debe aplicarse las reglas generales sobre la manifestación de voluntad.

Esta manifestación, que es requisito esencial de la representación, no existe en el mandato sin representación. El mandatario sin representación, si bien actúa en interés de otra persona, lo hace a nombre propio.

3) El representante debe tener poder de representación.

La autorización para actuar a nombre del representado, que es lo que constituye en esencia el poder de representación, debe ser anterior a la celebración del acto en que se ejerce dicho poder.

☐☐ Pero si no existe este poder, hay dos casos en que es posible que los efectos de un acto ejecutado por una persona se radiquen en otra:

- Cuando el AJ ha sido celebrado por un agente oficioso, se entiende que si la gestión ha sido útil para el interesado, éste la ha autorizado en el momento mismo en que se realizó.
- Cuando con posterioridad a la celebración del acto, el interesado lo ratifica.

8.8 CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL PODER DE REPRESENTACIÓN.

1. Revocación del poder.
2. Muerte del representado.
3. Muerte del representante.
4. Incapacidad sobreviniente del representante.

8.9 EXCESO O DEFECTO DE PODER DE REPRESENTACIÓN.

Ocurre cuando la actividad en nombre de otro no es conforme al poder de representación, porque, respectivamente, el poder sea más reducido o falte completamente.

El CC da reglas para el caso del mandatario que actúa excediendo los límites del poder o faltando el mismo:

a) El mandante cumplirá las obligaciones que a su nombre ha contraído el mandatario dentro de los límites del mandato (Art. 2160 inc. 1º CC). Límites del mandato equivale al contenido del poder de representación. En consecuencia, lo realizado en exceso o defecto del poder no obliga al representado, el AJ le es inoponible.

b) Teoría de los poderes aparentes: (Art. 2173 CC)

- Cuando el mandato expira por una causa ignorada por el mandatario, lo que éste haya hecho en ejecución del mandato es válido y da derecho a terceros de buena fe contra el mandante.
- Si el mandatario sabía la causa, el mandante también queda obligado ante terceros de buena fe, pero tiene derecho a que el mandatario le indemnice
- En consecuencia, el acto le será oponible siempre que la otra parte esté de buena fe.

c) El mandatario que excede los límites del mandato es sólo responsable al mandante, y no a terceros sino cuando:

- no les da suficiente conocimiento de sus poderes y
- se obliga personalmente (Art. 2154 CC).

Esta es la regla general en lo relativo a la representación con exceso o defecto de poder.

d) El mandante es obligado por lo ejecutado fuera de los límites del mandato si ratifica expresa o tácitamente cualquier obligación contraída a su nombre (Art. 2160 inc. 2º CC).

8.10 LA RATIFICACIÓN.

El AJ celebrado en exceso o defecto de poder no tiene un vicio de nulidad, pero es un negocio con eficacia suspendida: será ineficaz si la persona a cuyo nombre se realiza no lo ratifica, y será eficaz en caso contrario.

Ratificación: acto mediante el cual el interesado por sí hace eficaz el acto que ha sido concluido en su nombre.

- Es un AJ unilateral que debe emanar del interesado o sus herederos.
- Es un AJ irrevocable una vez que la persona ante quién se otorga toma conocimiento de ella.
- Se discute ante quién debe darse la ratificación: frente al que actuó como representante o frente al que contrató con él. Vial opina que les interesa a los dos, por lo tanto, conocida por cualquiera, la ratificación se vuelve irrevocable.
- La ratificación no se sujeta a formalidades especiales. Puede manifestarse expresa o tácitamente. Para algunos, si el acto que se ratifica es solemne, la ratificación debe ajustarse a la misma solemnidad.

CAPÍTULO 9. ANEXOS

ANEXO 1: Art 1444

Se entiende que el art. 1444 CC dice cosas, a fin de encontrar un factor común entre los tres elementos, de la esencia, de la naturaleza y accidentales. De esta manera el término doctrinal de elementos solo se aplicaría a los de la esencia, entendiéndose como requisitos necesarios para que el acto jurídico nazca a la vida del derecho.

Así las "cosas" de la naturaleza y accidentales no serían en verdad elementos del acto jurídico entendido de esta manera, sino más bien efectos del acto jurídico, es decir, derechos u obligaciones que el acto ya nacido produce

ANEXO 2: Explicación acerca de la venta de las cosas enumeradas en el artículo 1464 del Código Civil:

Se recomienda dividir la respuesta en **3 etapas**:

- 1ª etapa: a la sola luz del 1464 Código Civil, se puede afirmar que la venta se puede realizar, ya que ésta sólo constituye un título, sin generar el efecto de trasladar el dominio (**importante**: señalar que la venta no constituye enajenación)
- 2ª etapa: a la luz de los artículos 1464, 1810 a contrario sensu, 1466, 1682 y 10, todos del Código Civil, se puede afirmar que la venta adolecería de objeto ilícito (**importante**: concordar los artículos 1810 a contrario sensu, 1464 y 1466, todos del Código Civil)
De esta manera la compraventa de una de las cosas enumeradas en el art. 1464 sería un contrario prohibido en virtud de lo dispuesto en el art. 1810, y por lo tanto será sancionado con objeto ilícito por lo dispuesto en el art. 1466.
- 3ª etapa: tesis de don Eugenio Velasco Letelier: distinguir conforme a la clasificación de las normas, armando "2 grupos": el primero con los números 1 y 2 (normas prohibitivas); y el segundo con los números 3 y 4 (normas imperativas de requisitos) (**importante**: distinguir tipos de normas)

ANEXO 3: Error de derecho excusable

Por regla general, el error de derecho en el Código Civil se considera inexcusable (art 1452 CC), en virtud del art 8 CC (ficción de conocimiento de la ley), y debido a que algunos hacen extensiva la presunción de mala fe del art 706 CC incluso fuera de materias posesorias.

La jurisprudencia ha señalado, sin embargo, que no es suficiente la presunción (ficción) de conocimiento de la ley. En este caso, se entiende que el error es excusable cuando la causal era imposible de ser pasada por alto, es decir, cuando actuando con la diligencia media, no ha sido posible superar la falsa representación de la realidad en la que ha incurrido.

Esta clasificación es importante, puesto que quien actúe en forma culposa o negligente, no tendrá legitimación para demandar la nulidad del negocio viciado con error. Se dirá entonces que deberá asumir los costos de su imprudencia.

La doctrina más contemporánea modera esta "pena del infierno" establecida en el artículo 706 CC a quien padece de un error de derecho. Para ser fiel intérprete del precepto que se invoca para aplicar tan grave sanción al error de derecho, no se pretende "presumir conocimiento de las normas jurídicas por todas las personas. Sólo quiere decir que nadie puede, bajo pretexto de ignorancia, apartarse de la aplicación de la ley. Pero cuando una persona alega el error de derecho como vicio del consentimiento, no está tratando de vulnerar la ley, de quedar fuera de sus normas. Lo que pretende es que, porque no conocía bien las reglas del derecho, prestó su consentimiento o dio su voluntad, de modo que, de haber sabido cuál era la verdadera situación, no habría celebrado el negocio jurídico".

Por ende, los requisitos para que un error pueda viciar el consentimiento y ser causa para la invalidación del acto serán siempre: que sea determinante, y que sea **excusable**.

Ej: Legitimación para alegar la nulidad:

El principio aparece en el artículo 1683 del Código en términos que no podrá alegarse la nulidad absoluta por aquella parte que teniendo interés en su declaración haya "sabido o debido saber el vicio que lo invalidaba".

Adelantemos que esta cuestión será relevante desde el momento que el error esencial, tiene como sanción la nulidad absoluta del negocio, según alguna correcta doctrina nacional y jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema. Así entonces, será necesario que quien padece el error esencial -in negotio o in corpore-, no haya sabido o debido saber el vicio que afectaba a su conocimiento y posterior declaración de voluntad o haya estado en situación de impedir dicha falsa representación de la realidad haya afectado su conocimiento, y posterior declaración de voluntad.

Otros Ejemplos: el pago de lo no debido art 2297 - 2299, la casación en el fondo y nulidad, cuando el juez cometió un error de derecho.